

الصفحة	السؤال
ص:٣	س ١ : عرف الاوراق التجارية مبينا خصائصها؟
ص:٤	س ٢ : بين الكفاية الذاتية للورقة التجارية ؟
ص:٥	س ٣ : هل يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة " ليست لامر " ؟
ص:٥	س ٤ : ماهو حكم تقسيط الدين في سند تحت الاذن ؟
ص:٦	س ٥ : الاوراق التجارية اعمال تجارية مطلقة وشكلية ؟
ص:٧	س ٦ : وضع الفرق بين الشيك والسند لامر ؟
ص:٧	س ٧ : الورقة التجارية أداة وفاء وضع ذلك ؟
ص:٨	س ٨ : ماهي خصائص الالتزام الصرفي ؟
ص:١٠	س ٩ : ماحكم نقص اهليه الضامن والمستفيد في الكمبيالة ؟
ص:١١	س ١٠ : من البيانات الالزامية للكمبيالة ان تشمل على امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ؟ وضع ذلك ؟
ص:١٢	س ١١ : هل يجوز للساحب ان يسحب كمبيالة علي نفسه ؟
ص:١٣	س ١٢ : اكتب في ميعاد الاستحقاق مبينا اهميته وحكم خلو الكمبيالة ؟
ص:١٤	س ١٣ : ماهو حكم خلو الكمبيالة من بيان مكان الوفاء ؟
ص:١٤	س ١٤ : ماهي اهمية تاريخ اصدار الكمبيالة ؟
ص:١٥	س ١٥ : هل يجوز سحب الكمبيالة بواسطة الوكيل ؟
ص:١٦	س ١٦ : ماهو حكم القانون في سحب الكمبيالة لذمة الغير ؟
ص:١٦	س ١٧ : ماهو حكم تعدد نسخ الكمبيالة ؟
ص:١٧	س ١٨ : ما هو جزاء الإخلال بالشروط الشكلية للكمبيالة ؟
ص:١٨	س ١٩ : ماهو حكم اصدار الكمبيالة علي بياض ؟
ص:١٩	س ٢٠ : ماهو حكم التحريف في الكمبيالة ؟
ص:٢٠	س ٢١ : ماهو حكم الصورية في الكمبيالة ؟
ص:٢٠	س ٢٢ : اذكر مع الشرح ثلاثة من البيانات الاختيارية للكمبيالة ؟

ص: ٢٢	س ٢٣: ما الذي يترتب علي شرط عدم القبول في الكمبيالة ؟
ص: ٢٣	س ٢٤: ما المقصود بالتظهير التام مبينا الشروط الموضوعية الخاصة بطبيعة التظهير ؟
ص: ٢٥	س ٢٥: ماهو حكم التظهير الذي يقع بعد ميعاد الاستحقاق ؟
ص: ٢٦	س ٢٦: هل يجوز توقيع المظهر علي الكمبيالة دون ذكر بيانات اخري ؟
ص: ٢٧	س ٢٧: ماهي اهمية تاريخ التظهير ؟
ص: ٣٠	س ٢٨: اكتب في قاعدة تطهير الدفع ؟
ص: ٣٢	س ٢٩: ماهي الاثار المترتبة علي التظهير التوكيلي ؟
ص: ٣٤	س ٣٠: ماهي الاثار المترتبة علي التظهير التأميني ؟
ص: ٣٦	س ٣١: اشرح شروط وجود مقابل الوفاء ؟
ص: ٣٨	س ٣٢: اكتب في ملكية مقابل الوفاء مبينا الحالات التي يمتلك فيها الحامل للكمبيالة مقابل الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق ؟
ص: ٣٩	س ٣٣: ما حكم التزام علي مقابل الوفاء ؟
ص: ٣٩	س ٣٤: عرف القبول في الكمبيالة مبينا الحالات التي يلتزم والحالات التي يمتنع على الحامل تقديم الكمبيالة للقبول ؟
ص: ٤٥	س ٣٥: اشرح خصائص التضامن الصرفي ؟
ص: ٤٦	س ٣٦: الضمان الاحتياطي الصادر ممن وقعوا الكمبيالة ضمانه جديدة للحامل ؟
ص: ٤٦	س ٣٧: وضع العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزم المضمون ؟
ص: ٤٩	س ٣٨: ماهو حكم افلاس الحامل للكمبيالة ؟
ص: ٤٦	س ٣٩: ماهو حكم ضياع الكمبيالة ؟
ص: ٥٠	س ٤٠: اشرح بالتفصيل احتجاج عدم الوفاء ؟
ص: ٥٢	س ٤١: اذكر حالات رجوع الحامل على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين قبل ميعاد الاستحقاق ؟

أولاً: قانون الصرف:

المقصود بقانون الصرف مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحكام الأوراق التجارية، وتوضح الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الأوراق. وتهدف قواعد قانون الصرف إلى تحقيق شرعية تداول الورقة التجارية، وإلى بعث الثقة في نفس الدائن حتى يقبل على قبول الورقة التجارية كأداة للوفاء بدلا من النقود، وأداة ائتمان.

س ١: عرف الأوراق التجارية مبينا خصائصها؟

ثانياً: المقصود بالأوراق التجارية:

المقصود بالأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى، ورغم أن المشرع لم ينظم سوى أحكام الكمبيالة، إلا أن المشرع راعي ما يستجد من أوراق تجارية قد تظهر في الواقع العملي ويقرها العرف. حيث ذهب رأى إلى أن الأوراق التجارية مذكورة على سبيل الحصر. في حين يرى الرأي الغالب في الفقه عكس ذلك حيث أنه لا مانع من إضافة أوراق تجارية أخرى إذا ما توافرت فيها خصائص ومميزات الأوراق التجارية. بالفعل ظهرت شهادات الإيداع القابلة للتداول وهي تعتبر من قبيل الأوراق التجارية لأنها تحمل خصائصها. قد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى تأييد الرأي الغالب في الفقه فقالت "أن إحصاء الأوراق التجارية المذكورة في القانون لم يتناول الأوراق التجارية كافة. كما سبق حسم المشرع في القانون التجاري هذا الخلاف وجاء ليؤكد بشكل صريح وقاطع في المادة ٣٧٨ أن الكمبيالة والسند لأمر والشيك إنما جاءت على سبيل المثال ولا يوجد ما يمنع من وجود أوراق تجارية أخرى. على ضوء ذلك يمكن تعريف الأوراق التجارية بأنها صكوك مكتوبة وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون موضوعها الالتزام بدفع مبلغ من النقود مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين وقابلة للتداول بالطرق التجارية.

ثالثاً: الخصائص العامة للأوراق التجارية:

١ - الورقة التجارية صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة:

قرر المشرع بيانات محددة يجب أن تتضمنها الورقة التجارية يترتب على إغفالها كلها أو بعضها أن تفقد قيمتها كورقة تجارية أو تتحول إلى ورقة معيبة تكون بمثابة سند عادي للمديونية لا يخضع لأحكام قانون الصرف. ولا يكفي الإقرار بمضمون الحق لاعتبارها ورقة تجارية ما لم يندرج هذا الإقرار في ورقة مكتوبة وفقاً لبيانات محددة يضاف إليها كلمة كمبيالة أو سند إذن أو شيك- في متن الصك وباللغة التي كتب بها. فالورقة التجارية ما هي إلا عقد شكلي يتضمن التزام من الساحب بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد أو قابل للتحديد إلى المستفيد. فالمشرع أوجب أن تتضمن الورقة التجارية بيانات إلزامية محددة أحصاها توقيع مصدر هذه الورقة.

س ٢: بين الكفاية الذاتية للورقة التجارية ؟

٢- الكفاية الذاتية للورقة التجارية:

قرر المشرع هذه البيانات الإلزامية حتى تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت بها وإثباته بدون الاعتماد أو الإحالة على أي مظاهر خارجية، ويجب أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها بمعنى أنه تكفي مجرد النظرة إليها لتحديد الحقوق التي تتضمنها الورقة ومداها.

نظراً لأن أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإنه يلزم لذلك أن تكون **الورقة مستقلة بذاتها** فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي، ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجية عنها، وذلك حتى يسهل على المتنازل إليه معرفة الحق الذي يؤول إليه فلا يتردد في قبول التنازل في الحال، وبذلك تكون الورقة التجارية أداة سريعة - تتطلبها المعاملات التجارية - لتسوية عدد كبير من الديون بقدر عدد مرات التظهير على الورقة.

على ذلك إذا ذكر في الورقة التجارية **جميع البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً** فإن هذا يعطيها الكفاية الذاتية ما دام لم يذكر فيها أن وجود الدين نفسه أو تحديد المبلغ الواجب دفعه أو ميعاد الوفاء يخضع لشروط عقد خاص محرر بين الساحب والمستفيد حيث تفقد الورقة هنا ذاتيتها نظراً لأن مضمون الالتزام الصرفي يتم الرجوع فيه إلى وقائع أو اتفاقات خارجية هو العقد الخاص المبرم بين الساحب والمستفيد.

هذا وينتج عن الكفاية الذاتية للورقة التجارية مبدئين:

المبدأ الأول: استقلال الالتزام الصرفي عن العلاقة الأصلية:

طالماً أن الورقة يجب أن يكون لها الكفاية الذاتية لوجود الحق الثابت بها وإثباته، فإنه ينتج عن ذلك أن هذا الالتزام الناشئ عن الورقة مستقل في ذاته ولا يتوقف وجوده وتقريره على مناقشة العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد، فالورقة كافية لذاتها لتقرير الحق الثابت بها بصرف النظر عن العلاقة الأصلية وما يشوبها من دفع.

المبدأ الثاني: استقلال التوقيعات التي تحملها الورقة التجارية:

هذا المبدأ يعني أنه إذا شاب عيب في أحد التوقيعات الموجودة على الورقة التجارية فإن هذا لا يمنع من الرجوع على أصحاب التوقيعات الأخرى نظراً لاستقلال كل منهما.

إذا تمكن أحد الموقعين على الورقة من التمسك في مواجهة الحامل بانقضاء التزامه في الورقة لأي سبب - كالمقاصة مثلاً - فإن ذلك لا يعفى الموقعين الآخرين من الوفاء ولا يمنع الحامل من الرجوع عليهم للوفاء بقيمة الورقة، فالورقة التجارية تكتسب قوة إضافية كلما دخل عليها توقيعاً جديداً بالتظهير.

٣- موضوع الورقة الالتزام بدفع مبلغ من النقود:

تعتبر الأوراق التجارية أداة وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، لذلك يجب أن يكون محل الورقة التجارية الالتزام بدفع مبلغ من النقود في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

المشرع في القانون التجاري أكد هذه الخصية حيث نص في المادة ٣٧٩ على أن، **تشتمل الكمبيالة على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود**.

لا يكفي أن يكون موضوع الورقة التجارية مبلغ من النقود كما لو كان موضوعها الاعتراف بالدين فقط، وإنما أن يكون موضوعها هو الالتزام بدفع مبلغ نقدي أي التعهد بدفع مبلغ نقدي في تاريخ معين، لذلك لا تعتبر الأسهم أوراقاً تجارية لأنه لا يمثل دين على الشركة تتعهد بدفعه في ميعاد معين.

يشترط أيضا أن يكون مبلغ النقود موضوع الحق الثابت في الورقة التجارية معين المقدار بكل دقة وغير متنازع على تحديده. أما إذا كان موضوع الورقة التجارية شيئا آخر غير النقود كتسليم بضاعة مثلاً فإنها لا تعتبر ورقة تجارية، فمثلاً سندات الشحن وتذاكر النقل البرية والجوية فهذه الأوراق لا تعتبر أوراقا تجارية لأنها تثبت فقط وجود البضائع المذكورة بها لدى أمين النقل، كما أن هذه البضائع، والأشياء الواردة بها لا تتمتع بقيمة ثابتة كما هو الحال بالنسبة للنقود.

أننا وإن كنا لا نعتبر سندات الشحن وتذاكر النقل أوراقاً تجارية إلا أننا لا نرى ما ذهب إليه فريق من الفقه من أن الأوراق التي يكون موضوعها تسليم بضاعة لا تعتبر أوراقا تجارية لأن البضاعة لا تتمتع بقيمة ثابتة كما هو الحال بالنسبة للنقود، أننا لا نرى ذلك لأن النقود أيضا لا تتمتع بثبات كما هو الحال بالنسبة للبضائع، حيث أن تغيير سعر البضائع إنما هو تغيير لقيمة النقود أيضا، فالقوة الشرائية للنقود مرتبطة بالتغيير في الأسعار والخدمات، وإنما نرى أن عدم اعتبار الأوراق التي يكون موضوعها تسليم بضاعة أوراقا تجارية إنما راجع إلى ما قرره المشرع من اعتبار الأوراق التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات.

س ٣: هل يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة " ليست للامر " ؟

٤- الورقة قابلة للتداول بالطرق التجارية:

من أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول بالطرق التجارية وهي التظهير والمناولة، وتداول الورقة بالتظهير إذا تضمنت شرط الأمر أو الإذن وينتقل الحق الثابت فيها بناء على هذا التظهير دون حاجة إلى الحصول على موافقة المدين أو إعلانه، ويكون تداول الورقة بالتسليم من يد إلى يد أي بالمناولة إذا كانت هذه الورقة لحمالها.

لذلك نص المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٩١ على "أن كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير، ولكن لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني على ما يترتب عليها من آثار حيث تتطلب حوالة الحق قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها على يد محضر، وحوالة الحق تنقل ذات الحق بكل دفعه إلى المحال له، في حين أن المظهر إليه أو حامل الورقة التجارية يكون بمأمن من الاحتجاج عليه بهذه الدفع و يوفر له المشرع ضمانات كافية لاستيفاء حقه.

س ٤: ماهو حكم تقسيط الدين في سند تحت الاذن ؟

٥- الأوراق التجارية مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين:

لا أهمية لاعتبار الورقة التجارية مستحقة الوفاء بعد أجل طويل أو قصير. إنما الذي يهمنا في هذه الخاصية أن تكون الورقة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين حتى يكون الالتزام الوارد بها محددا، لأنه لو لم يكن هناك ميعاد للدفع لكان الالتزام الوارد في الورقة التجارية غير محددا ووقع باطلا.

يلزم أيضا ألا يكون مواعيد استحقاق الورقة التجارية متعاقبة وإلا كانت باطلة، لذلك يجب أن يكون المبلغ المحدد في الورقة التجارية وحيدا غير مقسما أي يستحق الوفاء في ميعاد واحد.

قد حكم بأن تقسيط الدين في سند تحت الإذن يخرج عن كونه سندا لهذا الوصف بالمعنى المقصود في القانون التجاري، وذلك لأن وحدة الاستحقاق ووحدة الدين هما من الأركان الأساسية والجوهرية للورقة التجارية.

يذهب بعض الفقهاء إلى أن الورقة التجارية نشأت من العرف التجاري لكي تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات، لذلك يجب أن يقبلها العرف التجاري كورقة تجارية. لكننا لا نرى ذلك لأن الكمبيالة والسند الإذني والشيك أوراق تجارية قدر المشرع أن تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات، وأساسها في ذلك وسندها هو نص المشرع، لذلك فإننا لسنا في حاجة لأن يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء بالالتزامات محل النقود.

س ٥: الأوراق التجارية اعمال تجارية مطلقه وشككية ؟

رابعاً: أنواع الأوراق التجارية:

١- الكمبيالة:

تعرف الكمبيالة ← بأنها صك مكتوب وفقاً لبيانات حددها القانون تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي لاسم من يجب الوفاء له أو لأمره ويسمى المستفيد، في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو لدى الاطلاع.

يتضح أن الكمبيالة تتضمن ثلاثة أطراف، هم **الساحب** وهو الشخص الذي يأمر بالدفع، والمسحوب عليه وهو الشخص الذي يتلقى الأمر بدفع قيمة الكمبيالة **والمستفيد** وهو الشخص الذي يصدر الأمر لصالحه. وينتج عن ذلك ثلاث علاقات.

١. **علاقات الساحب والمستفيد الأول** ← وهذه العلاقة هي سبب سحب الكمبيالة من الساحب، فالمفروض أن يكون الساحب مدين لهذا المستفيد، وهذا هو المبرر لسحب الكمبيالة وفاء لهذا الدين، والمفروض في سبب الكمبيالة أنه مشروع وموجود حتى يتم إثبات العكس.

٢. **علاقة الساحب والمسحوب عليه** ← المفروض في هذه العلاقة أن المسحوب عليه مدين للساحب بقيمة الكمبيالة عليه، والمفروض أيضاً أن المسحوب عليه حصل على مقابل وفائه بقيمة الكمبيالة لذلك يعبر عن هذه العلاقة بمقابل الوفاء.

٣. **علاقة المسحوب عليه والمستفيد** ← هذه العلاقة تنشأ من الكمبيالة ذاتها عندما بوقع المسحوب عليه بقبولها، أما قبل ذلك فليس هناك ثمة علاقة بينهما، فالقبول وحده وهو سبب نشأة هذه العلاقة.

الغالب ألا يحتفظ المستفيد الأول بالكمبيالة حتى ميعاد الاستحقاق، وإنما يقوم هو الآخر بدوره في التنازل عنها بالتظهير لمصلحة شخص آخر.

٢- السند لأمر:

لم يصرح المشرع في القانون التجاري بالسند لحامله.

السند لأمر ← هو صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن تعهداً من محرراً بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة أو قابلة للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد.

يختلف السند لأمر عن الكمبيالة في أن السند لأمر يتضمن شخصين فقط عند إنشائه وبالتالي توجه علاقة واحدة سابقة بين المحرر والمستفيد والتي تعتبر سبب تحرير السند لأمر، أما الكمبيالة تتضمن عند إنشائها ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وينتج عنها ثلاثة علاقات بينهما.

س ٦: وضع الفرق بين الشيك والسند لامر ؟

٣- الشيك:

المقصود بالشيك ← بأنه صك مكتوب وفقا لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن أمرا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه باداء مبلغ معين من النقود من حساب لديه لأمر شخص آخر يسمى المستفيد أو لحامله بمجرد الاطلاع.

يعتبر الشيك عملا تجاريا في جميع الأحوال. ويختلف الشيك عن السند لأمر في أن الشيك يتضمن ثلاثة أطراف هم الساحب والبنك المسحوب عليه والمستفيد، بينما يتضمن السند لأمر شخصين فقط هم الساحب والمستفيد.

كما يتفق الشيك مع الكمبيالة في أن الكمبيالة ممكن أن تكون أداة وفاء إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو أداة ائتمان إذا كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة أو قابلة للتعيين، بينما يعتبر الشيك أداة وفاء فقط أي مستحق الدفع بمجرد الاطلاع كما أن المسحوب عليه في الشيك يجب أن يكون بنكا وإلا كان باطلا. بينما يجوز في الكمبيالة أن يكون المسحوب عليه بنكا أو شخصا آخر.

خامسا: وظائف الاوراق التجارية:

١- الأوراق التجارية تغني عن نقل النقود من مكان إلى مكان:

كان الإنسان يتعرض لمشكلتين أساسيتين عندما يسافر من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر،
المشكلة الأولى: هي أن نوع النقود التي يحملها قد تكون مختلفة عن نوع النقود في المكان المتجه إليه،
المشكلة الثانية هي أن حمله للنقود قد يعرضه لمخاطر ضياعها أو سرقتها في أثناء الطريق.
قد قامت الاوراق التجارية بحل هذه المشاكل حيث أن الإنسان استعاض بها عن نقل النقود وبالتالي تجنب مخاطر الضياع والسرقة.

س ٧: الورقة التجارية أداة وفاء وضع ذلك ؟

٢- الورقة التجارية أداة وفاء:

الورقة التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، فهي تعتبر أداة وفاء خاصة إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع، حيث يستطيع حاملها الحصول على قيمتها في أي وقت، وأيضا إذا كان الحق ثابت بها مستحق الوفاء بعد أجل معين أو قابل للتعيين، حيث يستطيع حامل الورقة أن يخصصها لدى أحد البنوك ويتحصل على قيمتها دون انتظار ميعاد الاستحقاق في مقابل خصم عمولة هي عبارة عن الفائدة التي يحصل عليها البنك بسبب التعجيل بالوفاء.

تعتبر الأوراق التجارية جميعا أداة وفاء، إلا أن الشيك يعتبر أكثر ملائمة لهذه الوظيفة حيث أنه دائما واجب الدفع بمجرد الاطلاع، أما الكمبيالة والسند لأمر فقد يقوموا أداة ائتمان إذا كان مستحقا الدفع بعد أجل معين أو قابل للتعيين.

قد ذهب محكمة النقض في حكم لها إلى أن "الشيك الأصل أنه أداة وفاء و من يدعي خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل على ما يدعيه".

بذلك يتضح أن الشيك وفقا لأحكام القانون التجاري لن يكون أداة ائتماننا وفقا لما كان يجري عليه العرف، فقد عمل المشرع على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على اعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في التعامل.

٣- الورقة التجارية أداة ائتمان:

غالبا ما يكون التعامل بين التجار قائما على الأجل، لذلك تقوم الأوراق التجارية بدورها في هذا الخصوص، فالغالب أن تتضمن الورقة التجارية أجلا للوفاء وهو ما يعرف بميعاد الاستحقاق فيما عدا الشيك حيث أنه يستحق الدفع بمجرد الاطلاع. مما لا شك فيه أن الأجل يعتبر من دعائم المعاملات التجارية نظرا لطبيعة هذه المعاملات. والمقصود بالأجل هنا الفرق بين تاريخ تحرير الورقة التجارية وتاريخ استحقاقها.

س ٨: ماهي خصائص الالتزام الصرفي ؟

سادسا: خصائص الالتزام الصرفي:

١- الالتزام الصرفي التزام شكلي أو حرفي:

بمعنى أنه لا بد أن تتوافر في الورقة التجارية بيانات محددة تستمد الورقة قوتها الملزمة من توافر هذه البيانات، فالالتزام الصرفي التزام شكلي مكتوب. معنى أن الالتزام الصرفي التزام حرفي أو شكلي أن الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان ما يترتب عليها من التزامات وحقوق، وهذا هو مبدأ الكفاية الذاتية.

٢- الالتزام الصرفي التزام مستقل:

هو ما يعبر عنه بمبدأ استقلال التوقيعات وهو مبدأ ناتج عن الكفاية الذاتية للورقة، ومعناه أن التزام الموقع على الورقة التجارية التزام مستقل عن غيره من التوقيعات وذلك فيما يتعلق بصحته وبطلانه، فإذا كان أحد الموقعين على الورقة يستطيع أن يحتج بدفع ما في مواجهة الحامل - مثل الدفع بانعدام الرضا أو انعدام الأهلية - فإذا هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على الموقعين الآخرين.

٣- الالتزام الصرفي التزام مجرد:

معنى ذلك أن الالتزام الصرفي لمصلحة حامل الورقة التجارية مستقل عن العلاقة الأصلية التي كانت بين محرر الورقة والمستفيد الأول والتي كانت سببا في نشأة الورقة التجارية، وبالتالي فإن العيوب التي تشوب العلاقة الأصلية بين صاحب الورقة والمستفيد الأول لا يحتج بها في مواجهة حامل الورقة حسن النية.

٤- التشديد في معاملة المدين لحماية حقوق حامل حسن النية:

عامل المشرع الملزم بالورقة التجارية معاملة تختلف عن معاملة الالتزامات التجارية الأخرى، فهو يقسو على المدين في الورقة التجارية في أنه يلزمه بدفع الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق أيا كانت ظروفه المالية، حيث لا يجوز للمحاكم أن تمنح المدين مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في الأحوال وفي الحدود التي نص عليها القانون.

إذا امتنع المدين عن الوفاء بقيمة الورقة التجارية تعرض للتشهير بسمعته التجارية من خلال قيام الحامل بعمل احتجاج عدم الوفاء، وهو ورقة من أوراق المحضرين يقوم الحامل بإعلانها إلى الضامين وهو جميع الموقعين على الورقة التجارية.

الزم المشرع الحامل بعمل الاحتجاج خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم استحقاق الورقة وإلا سقط حقه في الرجوع على الموقعين على الورقة التجارية فيما عدا المدين الأصلي.

هذا ويلتزم الموقعين على الورقة التجارية بالتضامن فيما بينهم فيستطيع حامل الورقة بمجرد اتخاذ إجراءات الاحتجاج وفقا لما حدده القانون، الرجوع على هؤلاء الملزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.

يتعرض أيضا الملزم المصرفي للحجز التحفظي على منقولاته أن تخلف عن الوفاء.

الكمبيالة

إنشاء الكمبيالة

الشروط الموضوعية للكمبيالة

١- الرضا:

يشترط في الالتزام الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة ما يشترط في أي التزام إرادي من توافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب، وهذا ينطبق على توقيع الساحب أو المسحوب عليه القابل أو المظهر، فإذا شاب رضا أي منهما أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس كان التزامه قابلاً للإبطال لمصلحته.

يترتب على ذلك أنه إذا شاب رضا المدين في الكمبيالة - غلط أو إكراه أو تدليس - جاز له التمسك بالبطلان في علاقته بدائنه المباشر وفي علاقته بالحامل الأخير إذا كان سئ النية أي بعلم حقيقة العيب وقت انتقال الكمبيالة إليه.

٢- المد:

محل الكمبيالة يجب أن يكون دائماً مبلغ من النقود، حيث يجب أن تشتمل الكمبيالة على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود فإذا وردت الكمبيالة على شيء آخر غير النقود فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية التي ينطبق عليها قانون الصرف.

٣- السبب:

أما السبب فهو سبب التزام الساحب في الكمبيالة وسبب تحريره لها، ووفقاً للقواعد العامة يجب أن يكون هذا السبب مشروعاً وموجوداً وإذا كان سبب الالتزام غير موجود أو غير مشروع - أي مخالف للنظام العام والآداب - كان الالتزام باطلاً، غير أن هذا البطلان ينحصر في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر، وإذا تداولت الكمبيالة واستقرت في يد حامل سئ النية أي يعلم بعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته، استطاع أيضاً المحرر التمسك في مواجهته، بالبطلان، أما إذا كان الحامل حسن النية لا يعلم بذلك فإن المحرر لا يستطيع التمسك بالبطلان لأن التظهير تظهر الورقة من هذا الدفع.

أيضاً إذا قام أحد المظهرين بتظهير الكمبيالة لشخص آخر وكان هذا التظهير بسبب غير موجود أو غير مشروع كدين قمار مثلاً استطاع هذا المظهر أن يتمسك في مواجهة المظهر إليه المباشر بالبطلان في حالة رجوع هذا المظهر إليه عليه.

كمبيالة المجاملة:

إذا لم يكن هناك سبب يقوم عليه قيام المحرر بتوجيه الأمر للمسحوب عليه بالدفع للمستفيد فإن يعتبر مجاملة للمستفيد، وتسمى الكمبيالة في هذه الحالة بكمبيالة المجاملة، حيث يستطيع المستفيد من هذه الكمبيالة تظهيرها والحصول على قيمتها وبالتالي يقوم ائتمان زائف وهمي عن طريق إيهام الغير بصحة هذه الكمبيالة، في حين نجد هذه الكمبيالة تتعرض لمخاطر عدم الوفاء بقيمتها من قبل المسحوب عليه.

الجدير بالذكر أن التعامل بهذه الكمبيالة الوهمية يؤدي إلى إشاعة الاضطراب في الحياة التجارية ويخل بالثقة بين التجار، لذلك أجمعت التشريعات الحديثة على بطلان هذه الكمبيالة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها للنظام العام فضلاً عن عدم مشروعية السبب، حيث أن سبب تحريرها هو خلق ائتمان زائف وهذا يخل بالحياة التجارية.

الأهلية:

الكمبيالة تعتبر تصرفاً قانونياً، لذلك تطبق عليها القواعد العامة في الأهلية حيث يشترط أن يكون الملتزم في الورقة التجارية متمتعاً بالأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية، أي بالغاً من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية دون أن يصيبه عارضا من عوارض الأهلية، أي غير محجوز عليه لعته أو سفه أو غفلة أو جنون وإذا بلغ الشخص ثمانية عشر عاماً وأذنت له المحكمة في مباشرة التجارة واحترافها فإنه يعتبر اهلاً للالتزام بالكمبيالة المتعلقة بتجارته التي أذنت المحكمة بموازلتها.

غير أن المشرع راعي أن أحكام الالتزام الصرفي أشد قسوة من الأحكام العامة للالتزامات لذلك أورد نصاً يتعلق بالأهلية اللازمة للتوقيع على الكمبيالات حيث نصت المادة ٣٨٥ من القانون التجاري على أن "تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة على توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

يتضمن نص المادة ٣٨٥ من قانون التجارة حكيمين:

الحكم الأول ← يتعلق بناقص الأهلية وهذا الحكم يحتوي على شقين أحدهما يتفق مع القواعد العامة والثاني يعتبر استثناء على أحكام قانون الصرف، فيما يتعلق،

الشق الأول ← فإنه يجوز طبقاً للقواعد العامة للقاصر إذا بلغ سن الثامنة عشر أن يزاول التجارة بعد الحصول على إذن من المحكمة ويعد القاصر في هذه الحالة كامل الأهلية في حدود هذا الإذن، إما إذا خرج عن حدود هذا الإذن فإنه يأخذ حكم القاصر غير المأذون له بمباشرة التجارة.

الشق الثاني ← فيما يتعلق بناقص الأهلية فإنه يتضمن استثناء على أحكام قانون الصرف حيث أن الأصل أن تظهير الورقة التجارية يترتب عليه تطهير الورقة من جميع أسباب البطلان وذلك حماية للحامل حسن النية الذي لا يعلم وقت تلقيه الورقة بهذه الدفع، ولكن المشرع خرج على هذا حماية لناقص الأهلية وأجاز له التمسك بالبطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية حماية له حيث أنه أولى بالرعاية من الحامل حسن النية.

الحكم الثاني ← فمن المعلوم أن تصرفات عديم الأهلية وفقاً للقواعد العامة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويستطيع أن يتمسك بهذا البطلان جميع أطراف التصرف القانوني وكل ذي مصلحة.

لكن جاء حكم المادة ٣٨٥ تجاري وخرج على هذه القواعد العامة، حيث ساوى المشرع بين تصرفات ناقص الأهلية وعديم الأهلية، وقرر بأن توقيع عديم الأهلية على الكمبيالة يكون قابلاً للبطلان بالنسبة له فقط، فله وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون غيره من ذوي المصلحة.

أهلية الأجنبي في التوقيع على الكمبيالة والالتزام بها:

إذا كان هناك شخصاً أجنبياً سوف يلتزم بموجب كمبيالة فإن قانون دولته هو الذي يحدد أهليته في ذلك وإذا كان قانون دولته لا يعتبره كامل الأهلية مثلاً إلا في سن ٢٣ سنة ووضع توقيعه على كمبيالة في سن ٢١ سنة في دولة مثل مصر يعتبره قانونها كامل الأهلية، لأنها تعتبر الشخص كامل الأهلية في سن ٢١ سنة فإن التزامه يبقى صحيحاً.

الشروط الشكلية البيانات الإلزامية

١- كلمة "كمبيالة" مكتوبة في من الصك وباللغة التي كتب بها:

القانون التجاري المصري اشترط أن يشتمل الصك على كلمة "كمبيالة". والهدف من ذلك تعيين ماهية الصك صراحة ولفت نظر الموقعين عليها على طبيعتها ومدى الالتزام الذي نشأ عن توقيعهم. وتبعاً لذلك فإن خلو الصك من كلمة "كمبيالة" يخرجها من نطاق تطبيق أحكام قانون الصرف.

س ١٠ / من البيانات الإلزامية للكمبيالة ان تشمل على امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود وضح ذلك ؟

٢- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود:

يجب أن تشتمل الكمبيالة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط سواء كان شرطاً فاسخاً أو وافقاً، حتى لا يعوق تداول الورقة التجارية ويفقدها شرط الكفاية الذاتية. ويجب أن يكون موضوع الكمبيالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود، فلا يجوز أن يكون موضوعها تسليم شئ مثل سند معين أو بوليصة شحن أو بضاعة ولا يجوز أن يكون موضوعها الالتزام بأداء عمل فإذا اشتملت الورقة على ذلك فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية. ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محددًا بطريقة واضحة ودقيقة لا لبس فيها حيث لا يدع مجالاً للشك حول تحديده أو مقداره.

لهذا قضت محكمة النقض بأنه "حيث أن أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول. ولازم كونها كذلك أن تكون مستقلة بنفسها وأن يبين بمجرد الاطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع مجالاً للمنازعة.

يشترط أغلب الفقهاء أن يكون مبلغ الكمبيالة واحداً، وهو ما يعبر عنه بوحدة المبلغ أو وحدة الدين في الكمبيالة، فلا يجوز أن يتضمن صك الكمبيالة الوفاء بعدة مبالغ متفرقة أو تتضمن ما يفيد تقسيط المبلغ حيث أن من شأن ذلك عرقلة تداول الكمبيالة.

يختلف حكم القانون الانجليزي في هذه المسألة إذ تنص المادة ٩ من قانون الكمبيالات الانجليزي الصادر سنة ١٨٨٢م على أن مبلغ الكمبيالة يجب أن يكون محددًا ومع ذلك يمكن أن يشترط أدائه على دفعات.

لم يشترط القانون التجاري طريقة معينة لكتابة المبلغ أو المكان الذي يذكر فيه، فيجوز أن يكتب بالأرقام أو الحروف أو الاثنين معاً، ويمكن كتابته أعلى الصك أو في صلبه، ولكن العرف جرى على كتابة مبلغ الكمبيالة مرتين أحدهما بالأرقام ويكتب أعلى الكمبيالة والأخر بالحروف ويكتب في صلب الكمبيالة.

قد نص القانون التجاري في المادة ٣٨٤ على أنه إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.

إما إذا كتب المبلغ مرتين بالحروف أو مرتين بالأرقام فالعبرة بالمبلغ الأقل إذا حدث اختلاف. وذلك على أساس أن هذا المبلغ هو المتفق عليه بين أطراف الكمبيالة على أقل تقدير.

يجب دفع قيمة الكمبيالة من صنف النقود المبينة فيها، لذلك يجب ذكر نوع العملة التي يتم الوفاء بها، إذ يجب ذكر ما إذا كانت العملة محل مبلغ الكمبيالة هي الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو عملة أجنبية أخرى.

قد ذهبت محكمة النقض بأن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود وأن يكون بالعملة الوطنية ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك.

قد أجاز المشرع التجاري "إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا.

اشتراط عائدا منفصلا عن مبلغ الكمبيالة:

في ظل المجموعة التجارية الملغاة ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان من الجائز اشتراط دفع فوائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة في الفترة بين تاريخ تحريرها وتاريخ استحقاقها.

قد حسم المشرع المصري هذا الموضوع وأخذ بما جاء به قانون جنيف الموحد، حيث نصت المادة ٤٨٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م على أنه يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها، ويجب بيان العائد في الكمبيالة فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.

معنى ذلك أن المشرع اقتصر وضع شرط العائد على الكمبيالات المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع دون الكمبيالات الأخرى التي تستحق بعد مدة معينة أو تاريخ محدد والسبب في ذلك أن ساحب الكمبيالة المستحقة في تاريخ محدد يعرف مقدما سعر الفائدة ويمكنه تحديد مقدار العائد المستحق عند سحب الكمبيالة وضمه إلى أصل مبلغ الكمبيالة دون حاجة إلى اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة.

٣- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه):

يجب أن تتضمن الكمبيالة اسم المسحوب عليه وإلا فقدت هذه الصفة ولا تعد كمبيالة، والمسحوب عليه هو الشخص الذي يوجه إليه الساحب أمره بدفع مبلغ نقدي لشخص ثالث.

المسحوب عليه يمكن أن يكون شخصا واحدا كما يمكن أن يكون متعددا، ففي حالة التعدد فإن الوفاء الحاصل من أحدهما يترتب عليه براءة ذمة الباقيين.

س ١١ : هل يجوز للساحب ان يسحب كمبيالة علي نفسه ؟

سحب الكمبيالة على الساحب نفسه:

ثار خلاف في ظل المجموعة التجارية الملغاة حول جواز سحب الكمبيالة على الساحب نفسه بحيث يجتمع في شخص واحدة صفة الساحب والمسحوب عليه، وكان الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أنه لا يجوز ذلك.

قد جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م ولم يعمل بما ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه وإنما أجاز سحب الكمبيالة على الساحب نفسه وتبقى كما هي كمبيالة لا تفقد صفتها.

يحدث عادة هذا عندما تكون هناك شركة لها مركزا رئيسياً وفروعا متعددة فيسحب المركز الرئيسي كمبيالة على أحد فروعها أو يحدث العكس ويسحب أحد الفروع كمبيالة على المركز الرئيسي.

قد أجاز قانون جنيف الموحد، سحب الكمبيالة على الساحب نفسه.

س ١٢ / اكتب في ميعاد الاستحقاق مينا اهميته وحكم خلو الكمبيالة ؟

٤- ميعاد الاستحقاق:

ذكرت المادة ٣٧٩ من القانون التجاري وجوب أن تشتمل الكمبيالة على بيان ميعاد الاستحقاق باعتباره من البيانات الأساسية الإلزامية في الكمبيالة.

أهمية ميعاد الاستحقاق:

- فهو الذي يعرف فيه الحامل الوقت الذي يجب عليه مطالبة المدين بالوفاء.
- وهو الذي يمكن على أساسه تحديد مواعيد الاحتجاج بعدم الدفع والرجوع على الموقعين، حيث يبدأ سريان هذه المواعيد من تاريخ الاستحقاق.
- هو الذي يبدأ منه سريان مدة تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة.

طرق تحديد ميعاد الاستحقاق:

أ) كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع:

قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع فيذكر فيها مثلاً ادفعوا لدى الإطلاع، أو ادفعوا لدى الطلب حيث أنها تحمل نفس المعنى، وقد نص المشرع في المادة ٤٢٢ من القانون التجاري على أن الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره.

ب) كمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع:

قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع فيذكر فيها مثلاً "ادفعوا بعد عشرة أيام من الإطلاع".

ج) كمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها:

قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها كأن يذكر فيها مثلاً ادفعوا بعد ستة أشهر من تاريخه معنى ذلك أن هذه الكمبيالة مستحقة الدفع بعد انقضاء الستة أشهر من تاريخ تحرير الكمبيالة.

د) كمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين:

قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين، كأن يذكر فيها مثلاً "ادفعوا في ١٥ يناير ٢٠٠٠" وهذه هي الطريقة المعتادة لتحديد ميعاد الاستحقاق.

قد اعتبر القانون التجاري ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية في الورقة التجارية ولكن إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق فإن القانون التجاري وضع حكماً مستحدثاً هو اعتبار الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها.

شروط ميعاد الاستحقاق:

- يشتترط في ميعاد الاستحقاق أن يكون معيناً على وجه التأكيد واليقين، فلا يجوز أن يرتبط تحديده بحصول واقعة معينة كزواج ابنه مثلاً أو بيع البضاعة.
- قد نص القانون التجاري أنه إذا وافق استحقاق التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالي.
- يشتترط في ميعاد الاستحقاق أن يكون واحداً، فلا يجوز أن تتضمن الكمبيالة مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ويعرف هذا بمبدأ وحدة الاستحقاق، ولا يجوز الخلط بين مبدأ وحدة الدين ومبدأ وحدة الاستحقاق، حيث أنه يجوز الوفاء الجزئي للكمبيالة، حيث أنه لا يوجد ما يمنع من دفع المبلغ على أقساط بعد حلول ميعاد الاستحقاق، وعلى ذلك إذا تضمنت الكمبيالة عدة مواعيد استحقاق متعاقبة فإنها تكون باطلة.

س ١٣ : ماهو حكم خلو الكمبيالة من بيان مكان الوفاء ؟

هـ- مكان الوفاء:

يجب أن تشتمل الكمبيالة على بيان مكان الوفاء أي المحل الذي يجب الدفع فيه، ويجب أن يكون هذا المكان معيناً بدقة في الكمبيالة ، ذلك حتى يعلم الحامل بالمكان الذي سوف يتوجه إليه لتحصيل قيمة الكمبيالة، والغالب أن يكون مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه أو محل إقامته أو مكان تجارته. وعند خلو الكمبيالة من هذا البيان فإنه لا يؤدي إلى بطلان الكمبيالة وإنما يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في نفس الوقت.

٦- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد):

يجب ذكر اسم من يجب الوفاء له وهو المستفيد لأنه الشخص الذي تحرر الكمبيالة لمصلحته، والكمبيالة وفقاً لأحكام القانون التجاري قد تصدر اسمية أي باسم شخص المستفيد دون أن تتضمن شرط الأمر، وقد تصدر الكمبيالة لأمر المستفيد حيث يلحق شرط الأمر بجانب اسم المستفيد كأن يقال ادفعوا "لأمر فلان" والمشرع قرر في المادة ٣٩١ بأن كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها بأنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير، أي أن الكمبيالة ولو لم يصرح فيها بأنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير، أي أن الكمبيالة التي تصدر باسم المستفيد دون أن تتضمن شرط الأمر فإنها تتداول أيضاً بالتظهير كأنها صادرة لأمر المستفيد. لكن يجب ملاحظة أنه لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة.

س ١٤ : ماهي أهمية تاريخ اصدار الكمبيالة ؟

٧- تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة:

أ) تاريخ إصدار الكمبيالة:

يجب كتابة تاريخ تحرير الكمبيالة بذكر اليوم والشهر والسنة التي صدرت فيها والحكمة من ذلك هي قطع كل نزاع حول تحديد تاريخ سحب الكمبيالة. يجب أن يكون للكمبيالة تاريخاً واحداً ولو تعدد الساحبون. الأصل أن تاريخ المحرر العرفي والغالب أن تكون الكمبيالة عرفية لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ.

ب) تاريخ الإصدار له أهمية عملية في الأمور الآتية:

- ١- يفيد تاريخ الإصدار في تحديد تاريخ الاستحقاق إذا كان ميعاد الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الإصدار، كما إذا ذكر أن ميعاد الاستحقاق يكون بعد سنة من تاريخ الإصدار.
- ٢- يفيد تاريخ الإصدار في معرفة أهلية الساحب، وهل هو كامل الأهلية وبالغ سن الرشد أم ناقص الأهلية أو عديم الأهلية.
- ٣- يفيد تاريخ الإصدار في معرفة مدى سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضامنين الموقعين على الكمبيالة، حيث حدد المشرع مواعيد معينة لتقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه تحسب من تاريخ سحب الكمبيالة إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع، ويترتب على إهمال الحامل لهذه المواعيد أن يسقط حقه في الرجوع على الضامنين باعتباره حاملاً مهماً.
- ٤- يفيد تاريخ الإصدار في تطبيق قواعد فترة الرتبة بالنسبة للتاجر المفلس وتحديد ما إذا كانت الكمبيالة قد حررت في وقت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية.
- ٥- يفيد تاريخ الإصدار في حالة سحب عدة كمبيالات وكان مقابل الوفاء غير كافي، ففي هذه الحالة تكون الأولوية لمن كان تاريخ تحرير كمبيالته اسبق.

ب) مكان إصدار الكمبيالة:

تطلب المشرع ذكر مكان إصدار الكمبيالة، ويفيد هذا البيان إذا ما تضمنت الكمبيالة عنصرا أجنبيا حيث أنه في حالة تنازع القوانين يطبق قانون البلد الذي حررت فيه الكمبيالة. الجدير بالذكر أنه لا يترتب على عدم ذكر بيان مكان إصدار الكمبيالة بطلانها، حيث يعتبر المكان المبين بجانب اسم الساحب مكان إصدارها.

٨- نوقية الساحب:

نصت المادة ٣٧٩/ح على وجوب أن تشتمل الكمبيالة على توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء، فلا قيمة للكمبيالة إلا إذا كانت موقعة من مصدرها، والساحب هو الذي ينشئ الكمبيالة ويصدر أمره إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة لذلك يعتبر هذا البيان جوهريا في الكمبيالة حيث أنه يفصح عن إرادة الساحب. ويجب أن يكون التوقيع واضحا ومقروءا، ولا يلزم أن يكون التوقيع في مكان معين، وإنما يجوز أن يكون التوقيع في صلب المحرر وأن يكون دالا على شخصية الساحب، ولا يشترط أن يكون الاسم كاملا ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي يعرف به المدين، وإذا كان الساحب أميا فإنه يكفي بصمة الختم أو الإصبع. الجدير بالذكر أنه إذا كان توقيع الكمبيالة مزورا بطل الالتزام بين الساحب والمستفيد الاول، وإذا ظهرت الورقة بعد ذلك وخرجت من يد المستفيد الاول إلى شخص آخر لا يعلم بواقعة التزوير، فإن هذا الحامل الأخير لا يستطيع الرجوع على الساحب حيث أن التزامه باطلا، ويسري هذا البطلان في حق الحامل الآخر لأنه من الدفوع التي لا يطهرها التظهير، لكن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على المظهرين الآخرين حيث أن التزاماتهم تبقى مع ذلك صحيحة طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات.

س ١٥ : هل يجوز سحب الكمبيالة بواسطة الوكيل ؟

سحب الكمبيالة بواسطة الوكيل:

وفقا للقواعد العامة لا يوجد ما يمنع من أن يكلف الساحب أحد الأشخاص بسحب الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يدفع الكمبيالة عن الساحب وكيله وتنصرف آثار الكمبيالة في هذه الحالة إلى الأصيل وليس إلى الوكيل، ويجب على الوكيل أن يظهر صفته عند التوقيع وإلا التزم شخصا في مواجهة الحامل حسن النية، ويحدث ذلك عادة بالنسبة لوكلاء المحال التجارية أو الوكيل المفوض نيابة عن بنك أو مدير إحدى الشركات نيابة عن الشركة.

كان مفروضا أيضا وفقا للقواعد العامة أنه إذا وقع أحد الأشخاص كمبيالة نيابة عن الغير دون أن يكون مفوضا في ذلك فلا يلتزم هذا الغير بالوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل حتى لو كان حسن النية لأن هذا من الدفوع التي لا يطهرها التظهير.

قد جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ليقرر صراحة بأن من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

س ١٦ : ماهو حكم القانون في سحب الكمبيالة لذمة الغير ؟

سحب الكمبيالة لذمة الغير:

نص القانون التجاري في المادة ٣/٢٨١ على أن يجوز سحب الكمبيالة لحساب شخص آخر، حيث توجد أسباب كثيرة تدفع الساحب الحقيقي للكمبيالة بعدم ظهور اسمه كساحب للكمبيالة ويكلف شخص آخر- وكيل بالعمولة بسحب الكمبيالة لحسابه والتوقيع عليها، فلا يظهر اسم الساحب الحقيقي ولا يلتزم أمام الغير بهذه الصفة وإنما يعتبر الوكيل بالعمولة الساحب الظاهر هو الساحب الملتزم أمام الغير.

ينتج عن هذا الوضع خمس علاقات كما يلي:

١- علاقة الأمر بالسحب (الساحب الحقيقي) بالمسحوب عليه:

يلزم في هذه الحالة أن يقدم الأمر بالسحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه، ويكون لهذا الأخير الرجوع على الساحب الحقيقي في حالة سداد قيمة الكمبيالة لأنه من المفروض في هذه الحالة أن هناك تعامل بين الساحب الحقيقي والمسحوب عليه ويعمل كلا منهما الآخر.

٢- علاقة الساحب الظاهر (الوكيل بالعمولة) بالمسحوب عليه:

ليس هناك أي علاقة بين الساحب الظاهر والمسحوب عليه بل أن لكل منهما الحق في الرجوع على الساحب الحقيقي في حالة دفع أي مبالغ أو مصاريف.

٣- علاقة الساحب الحقيقي بالساحب الظاهر (الوكيل بالعمولة):

يعتبر الساحب الظاهر وكيلا بالعمولة عن الساحب الحقيقي لذلك تحكم العلاقة بينهما أحكام عقد الوكالة بالعمولة.

٤- علاقة الساحب الحقيقي بالمستفيد والمظهرين:

ليس هناك علاقة بينهما، لأنه من المفروض أن المستفيد والمظهرين لا يعلمون بالساحب الحقيقي وغير معروف لهم.

٥- علاقة الساحب الظاهر (الوكيل بالعمولة) بالمستفيد والمظهرين:

تخضع هذه العلاقة لإحكام قانون الصرف باعتبار أن الوكيل بالعمولة هو الساحب الملتزم بالكمبيالة فيضمن لهم قبول الكمبيالة وأداء قيمتها ويمكن الرجوع عليه في حالة امتناع المسحوب عليه عن الدفع.

س ١٧ : ماهو حكم تعدد نسخ الكمبيالة ؟

تعدد نسخ الكمبيالة:

الأصل أن الكمبيالة تحرر من نسخة واحدة غير أن هذه النسخة قد تكون عرضة لخطر الضياع أو السرقة لا سيما إذا كانت معدة للإرسال إلى الخارج، لذلك جرت العادة خاصة في المعاملات الدولية على تحرير الكمبيالة من عدة نسخ وإرسالها بطرق مختلفة لضمان وصول إحداها إلى الجهة المقصودة. لكن مما لا شك فيه أن تعدد النسخ لا يخلو من عيوب، إذ قد يتعرض المسحوب عليه لخطر المطالبة بالوفاء بكل نسخة من الكمبيالة.

قد أجاز المشرع في القانون التجاري سحب الكمبيالة من عدة نسخ يطابق بعضها بعضا، ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التي حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.

أضاف المشرع أن وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى النسخ مبري للذمة ولو لم يشترط فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى، وحسنا فعل المشرع ذلك حتى لا يتعرض من أوفى بها لخطر المطالبة بالوفاء بكل نسخة في حالة السهو عن وضع هذا الشرط.

أجاز المشرع لحامل الكميالة أن يحرر صورا منها، ويجب في هذه الحالة أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكميالة.

يبين في صورة الكميالة اسم الحائز الأصل، وعلى الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة حتى يستطيع الرجوع على الموقعين على الكميالة لاستيفاء قيمتها.

س ١٨ / ما هو جزء الإخلال بالشروط الشكلية للكميالة ؟

جزء الإخلال بالشروط الشكلية للكميالة

يتخذ الإخلال بالشروط الشكلية عدة صور، منها أن تصدر الكميالة ناقصة أحد البيانات الإلزامية وهذا ما يعرف بالترك، ومنها وقوع تحريف في متن الصك ذاته على أحد هذه البيانات، وهذا ما يعرف بالتحريف، ومنها أن يذكر في الكميالة بيان أو أكثر على غير الحقيقة وهذا ما يعرف بالصورية.

أولاً: الترك:

نصت المادة ٣٨٠ على أن "الصك الخالي من أحد البيانات لا يعد كميالة إلا في الحالات الآتية:

- إذا خلت الكميالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.
 - وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت.
 - وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب.
- يتضح من ذلك أن اغفال أحد البيانات الإلزامية يترتب عليه أن الصك يبطل الألفى الحدود المشار إليها .
- هذا البطلان من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته ويحتج به في مواجهة الحامل حتى ولو كان حسن النية.
- لكن هذا الصك الغير متضمن بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية وأن كان لا يعد كميالة ويبطل كميالة، إلا أنه قد يتحول إلى صك من طبيعة أخرى، فقد تتحول الكميالة الباطلة إلى تصرف عادي أو تعهد عادي يخضع لأحكام القانون المدني أو القانون التجاري.

١- تحول الكميالة الباطلة إلى سند مدني:

إذا توافرت في الورقة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد بياناتها الإلزامية ، مثل تخلف كلمة "كميالة" أو بيان تاريخ الإصدار، أو اسم من يلزمه الوفاء أو اسم من يجب الوفاء له، فإن الورقة وإن فقدت صفتها ككميالة وتخرج من نطاق أحكام قانون الصرف، إلا أنها تصبح تعهدا مدنيا عاديا خاضعا لأحكام القانون المدني، فلا ينتقل الحق الثابت في هذا التعهد أو هذا السند إلا عن طريق الحوالة المدنية، ولا تسري الفوائد القانونية إلا من تاريخ المطالبة القضائية، ويجوز منح المدين مهلة قضائية للوفاء.

٢- تحول الكميالة الباطلة إلى سند مدني يتداول بالطرق التجارية:

إذا تضمنت الكميالة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد البيانات الإلزامية وتضمنت أيضا شرط الأمر، فهي تتداول بالطرق التجارية وهي التظهير، دون إتباع إجراءات الحوالة المدنية.

قد جاء القانون التجاري، وقرر بأن كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضاعة يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة ان كان لحامله ويترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد.

٣- تحول الكمبيالة الباطلة إلى تعهد تجاري قابل للتداول بالطرق التجارية:

إذا توافرت في الورقة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد البيانات الإلزامية، فإن الورقة وإن كانت لا تعد كمبيالة وتصبح باطلة إلا أنها تتحول إلى التزام تجاري إذا كانت محررة بين تجار أو بمناسبة عملية تجارية، وبالتالي يسري العائد وفقاً للأحكام المقررة في القانون التجاري، كما يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. كما لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة ويشترط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.

٤- اعتبار الكمبيالة باطلة كتصرف قانوني:

قد تفقد الكمبيالة كل قيمة قانونية لها وتبطل كتصرف قانوني كلياً، وذلك إذا لم تتوافر في الكمبيالة الشروط اللازمة لصحة الالتزام، يتحقق في الكمبيالة ذلك إذا لم تتضمن توقيع الساحب أو بيان المبلغ.

س ١٩ : ماهو حكم اصدار الكمبيالة على بياض ؟

إصدار الكمبيالة على بياض:

قد يصدر الساحب كمبيالة خالية من جميع البيانات الإلزامية فيما عدا توقيع الساحب، حيث يترك تحديد وكتابة البيانات الواجب توافرها في الكمبيالة للحامل طبقاً لما هو متفق عليه بين الساحب والحامل فيقوم هذا الأخير بتحديد المبلغ الذي يلتزم به الساحب، كما يحدد اسم المستفيد بكتابة اسمه، ويحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التحرير.

والحامل في قيامه بهذا العمل إنما يتصرف لحساب الساحب، فإذا قام الحامل بملئ البيانات الإلزامية كاملة فإن الصك يعتبر سليماً.

أما إذا ظلت الكمبيالة خالية من جميع البيانات أو من بعضها فإنها لا تعد كمبيالة وتعتبر باطلة، أما إذا قام المستفيد بملئ البيانات على خلاف المتفق عليه كما إذا وضع مبلغ أكبر من المبلغ المتفق عليه مع الساحب أو حدد ميعاد استحقاق أقرب من المتفق عليه فإن هذا الصك لا يسري في مواجهة الساحب، ولكن لا أثر لهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية تطبيقاً لمبدأ تطهير الدفع.

لم يعالج المشرع في القانون التجاري موضوع إصدار الكمبيالة على بياض، ولكنه أشار إلى أنه.

إذا حملت الكمبيالة توقيعات غير ملزمة لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم لأسباب تتعلق بملئ بيانات كمبيالة صادرة على بياض، فإن التزامات غيرهم من الموقعين على الكمبيالة تبقى صحيحة طالما كان حامل الكمبيالة حسن النية.

ثانياً: التحريف:

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

المقصود بالتحريف ← تغيير بيان أو أكثر من بيانات الكمبيالة على خلاف الحقيقة في ذات الصك بعد سبق كتابته صحيحاً، حيث يقوم أحد الموقعين على الكمبيالة بالتغيير في مبلغ الكمبيالة فيجعله مثلاً ٢٠٠٠٠ جنية بدلاً من ١٠٠٠٠ جنية، أو التغيير في تاريخ الإصدار أو تاريخ الاستحقاق.

إذا حدث ذلك التزم الموقعون السابقون على التحريف بالمبلغ أو التاريخ وما ورد في الصك قبل تحريفه، أما الموقعون اللاحقون فيلتزمون بالبيان بعد تحريفه.

س ٢٠: ماهو حكم الصورية في الكمبيالة ؟

ثالثا: الصورية:

📌 **الصورية** ← هو تضمين الكمبيالة بيان أو أكثر على خلاف الحقيقة، فالكمبيالة متكاملة البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون لكن تذكر بعض هذه البيانات على غير الحقيقة.

📌 والفرق بين الصورية والتحريف هو أن الصورية تكون الكمبيالة فيها مستوفاة لجميع البيانات الشكلية إلا أن أحد هذه البيانات أو أكثر يذكر على غير الحقيقة كان يذكر اسم كاذب أو صفة غير حقيقية ليست متوفرة فيه أو يذكر تاريخ غير حقيقي أو يذكر مبلغ غير المتفق عليه بين أطرافها، أما التحريف فهو تغيير مادي في بيان أو أكثر من بيانات الكمبيالة على خلاف الحقيقة في ذات الصك بعد سبق كتابته صحيحاً.

📌 والصورية في ذكر البيانات المدونة بالكمبيالة لا أثر لها على صحة الكمبيالة، فالمفروض أن بيانات الكمبيالة صحيحة وعلى من يدعي الصورية إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن والدفاتر التجارية.

📌 ولا يجوز أن يتمسك المدين في الكمبيالة بالصورية في مواجهة الحامل حسن النية الذي لم يقصد وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، لأن الصورية ليست عيباً ظاهرياً في الكمبيالة حتى تفترض علم الحامل بها وهذا تطبيقاً لمبدأ تطهير الورقة من الدفوع.

صورة بيئت الكمبيالة

صورة الاسم والصفة:

📌 صورة الاسم تقع عندما يوقع الساحب على الكمبيالة باسم شخص آخر دون علمه بقصد الاعتماد على ثقة الناس فيه، أو باسم شخص وهمي بهدف التهرب من التزام ما، وقد تسحب الكمبيالة لمصلحة شخص غير موجود (المستفيد) أو تسحب على شخص غير موجود (المسحوب عليه).

📌 أما صورة الصفة فتقع إذا وصف الساحب نفسه بأنه تاجر أو صيرفي دون سند في الحقيقة بهدف الاعتماد على ائتمان الغير.

صورة تاريخ التحرير:

📌 صورة تاريخ التحرير لا يؤثر على صحة الكمبيالة وخضوعها لأحكام قانون الصرف طالما أنه لا يوجد غش، أما إذا كان المقصود من تغيير تاريخ التحرير هو إخفاء نقص أهلية القاصر بأن ذكر تاريخ لاحق على بلوغه سن الرشد، فهنا تنطبق أحكام المادة ٣٨٥ تجاري حيث تكون التزامات ناقصة الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم فقط ولهم الحق في التمسك بهذا البطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية.

صورة السبب:

📌 إذا حررت الكمبيالة لأسباب غير مشروعة - كدين قمار مثلاً - فهنا يبطل الالتزام، ولكن لا يستطيع التمسك بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية لأن الدفع الذي يستند إلى انعدام السبب أو عدم مشروعيته يظهر التطهير.

صورة مبلغ الكمبيالة:

📌 لا يؤثر صورة مبلغ الكمبيالة سواء بالزيادة أو النقصان على صحة الكمبيالة، وإنما يلتزم الموقعين على الكمبيالة بالمبلغ المدون بها، والمفروض أن بيانات الكمبيالة صحيحة حتى يقوم الدليل على صوريته وعلى من يدعي الصورية إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

س ٢١ / اذكر مع الشرح ثلاثة من البيانات الاختيارية للكمبيالة ؟

البيانات الاختيارية

١- شرط التقدم للقبول:

يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد محدد أو بغير تحديد ميعاد، ويجب على حامل الكمبيالة احترام هذا الشرط وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده.

يتضح من ذلك أن حق الحامل يسقط قبل الساحب بسبب عدم القبول وعدم الوفاء أيضا إذا تضمنت الكمبيالة شرط التقدم للقبول ولم يلتزم الحامل بذلك.

س ٢٢ : ما الذي يترتب على شرط عدم القبول في الكمبيالة ؟

٢- شرط عدم القبول:

يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، وله الحق أيضا أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل ميعاد معين، ويضع الساحب هذا الشرط عادة عندما لا يتوافر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق، فيخشى الساحب من رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة فيضع شرط عدم تقديمها للقبول، وقد يضع شرط عدم تقديمها للقبول قبل ميعاد معين حتى يتمكن من إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه قبل هذا الميعاد.

قد يلجأ الساحب إلى وضع هذا الشرط رغم وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، رغبة منه في استعمال مقابل الوفاء في سداد كمبيالات أخرى.

إذا قدم الحامل الكمبيالة للقبول رغم شرط عدم القبول، ورفض المسحوب عليه القبول، فإن الحامل لا يستطيع الاستناد إلى هذا الرفض للرجوع على الموقعين قبل حلول ميعاد الاستحقاق.

٣- شرط عدم الضمان:

قد يضع الساحب في الكمبيالة شرط عدم الضمان، أي أنه لا يضمن للحامل الوفاء بقيمة الكمبيالة، ولا يستفيد الساحب من هذا الشرط إلا إذا أثبت أنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق، وقد يضع هذا الشرط أحد المظهرين.

وإذا وضع الساحب هذا الشرط استفاد منه جميع المظهرين، أما إذا وضع هذا الشرط أحد المظهرين فإنه وحده الذي يستفيد من هذا الشرط دون غير من المظهرين.

٤- شرط الوفاء في محل مختار:

القاعدة أن مكان الوفاء هو محل المسحوب عليه، غير أنه يمكن أن يكون محل الوفاء مكانا آخر، فيجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.

فإذا وضع هذا الشرط فإن الحامل يلتزم بالتوجيه في ميعاد الاستحقاق لهذا المكان وعليه أن يعمل احتجاج عدم الدفع في هذا المكان المختار أيضا.

٥- شرط الوفاء أو القبول الإحتياطي:

قد يقوم الساحب أو أحد المظهرين بتعيين شخص آخر لقبول الكمبيالة أو الوفاء بقيمتها إذا رفض المسحوب عليه القبول أو الوفاء ويضع الساحب أو أحد المظهرين هذا الشرط إذا كان يخشى من رجوع الحامل عليه بسبب عدم قبول المسحوب عليه أو عدم وفائه بقيمة الكمبيالة.

قد قرر المشرع أنه "لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامناتها الاحتياطي أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الانقضاء".

لا يجوز في هذه الحالة للحامل أن يطالب القابل الاحتياطي أو الموفي الاحتياطي إلا بعد مطالبة المسحوب عليه وامتناع الأخير عن الوفاء أو القبول، وإذا طالب القابل الاحتياطي أو الموفي الاحتياطي بعد الرجوع على المسحوب عليه ولم يقبل أو يوفى هو أيضا، فإن الحامل يقوم بتحرير احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء - حسب الأحوال - في محل القابل أو الموفي الاحتياطي.

٦- شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه:

قد تتضمن الكمبيالة شرطا يقضي بعدم قيام المسحوب عليه بقبول الكمبيالة أو الوفاء بقيمتها إلا عندما يصله إخطار بذلك من الساحب.

لا يمكن قبول هذا الشرط في ظل أحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م، حيث أن هذا الشرط يصطدم بأحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة والذي نص عليه قانون التجارة وهو أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٧- شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج:

قد تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج أو عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، هذا الشرط يخفف من التزامات الحامل ويجعل رجوعه على الموقعين على الكمبيالة أكثر سهولة وسرعة وأقل تكلفة.

شرط الرجوع بلا مصاريف يجوز أن يضعه الساحب وفي هذه الحالة تسري آثار هذا الشرط على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.

إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.

رغم وجود شرط الرجوع بلا مصاريف إلا أن عمل الاحتجاج قد يكون ضروريا في حالة الامتناع عن الوفاء ورغبة الحامل في توقيع حجز تحفظي على أحد الملتزمين بالكمبيالة.

تداول الكمبيالة

يجوز التنازل عن الحق الثابت في الكمبيالة عن طريق الحوالة المدنية طبقا للقواعد العامة، كما يجوز انتقال الحق الثابت بها أيضا عن طريق الإرث أو الوصية.

لكي يتم التنازل بالحوالة المدنية لابد من قبول المدين لها أو إعلانه بها.

مما لا شك فيه أن هذه الإجراءات كثيرة. لذلك قرر المشرع في القانون التجاري أن تصدر الكمبيالة باسم من يجب الوفاء له أو لأمره، والكمبيالة التي لأمر تتداول بالتظهير.

التظهير يكتب على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها بما يفيد انتقالها إلى المظهر إليه وهذا الأخير ينقلها بدوره إلى مظهر إليه آخر ويتحول هو إلى مظهر وهكذا تنتقل الكمبيالة بالتظهير إلى أن يحل ميعاد الاستحقاق فيتقدم الحامل الأخير لأخذ قيمتها.

التظهير قد يكون الغرض منه نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه ويسمى التظهير في هذه الحالة بالتظهير التام والناقل للملكية، وقد يكون الغرض من التظهير مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة ويسمى التظهير في هذه الحالة بالتظهير التوكيلي، وقد يكون التظهير بقصد رهن الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه ويسمى التظهير في هذه الحالة بالتظهير التأميني.

التظهير التام والناقل للملكية

المقصود بالتظهير الناقل للملكية، نقل الحق الثابت بالكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه.

التظهير يعتبر تصرفا قانونيا يترتب التزاما في ذمة المظهر، لذلك يجب أن تتوافر فيه شروط موضوعية تستخلص من القواعد العامة ومن طبيعة هذا الالتزام، وشروط شكلية نص عليها المشرع.

الشروط الموضوعية

أولاً: الشروط الموضوعية العامة:

١- الأهلية:

يجب أن تتوافر في المظهر الأهلية التي يتطلبها القانون في الساحب- أهلية التوقيع على الكمبيالة - أي أهلية القيام بالأعمال التجارية نظراً لأن المظهر إزاء المظهر إليه في نفس مركز الساحب إزاء المستفيد. نظراً لأن المشرع قدر أن الالتزام الصرفي يعرض المدين به لأحكام أشد مما تقضي به القواعد العامة، لذلك قرر أن تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم.

٢- الرضا:

يجب أن يصدر التظهير عن رضا صحيح خالي من العيوب القانونية، فيجب أن يكون التظهير منزهاً عن عيوب الرضا، فإذا وضع المظهر تحت تأثير غلط أو إكراه أو تدليس أو استغلال كان التظهير باطلاً بالنسبة إليه وجاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة المظهر إليه المباشر وفي مواجهة الحامل سئ النية.

٣- المحل:

محل التزام المظهر في الكمبيالة هو محل الورقة ذاتها، أي المبلغ الثابت فيها، لذلك فإن محل التظهير هو دائماً ممكن ومشروع.

٤- السبب:

سبب التزام المظهر هو العلاقة بين المظهر والمظهر إليه التي على أساسها تم تظهير الكمبيالة. يشترط في سبب التزام المظهر أن يكون مشروعاً وموجوداً، حيث يجب أن لا يكون سبب التظهير مخالفاً للنظام العام والآداب، فالتظهير الحاصل وفاء لدين قمار يقع باطلاً ولا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان على الحامل حسن النية، كما هو الشأن في الدفع الناشئ عن عيوب الرضا، ويجب أن يكون سبب التظهير حقيقياً وليس صورياً وإلا وقع باطلاً.

ثانياً: شروط موضوعية خاصة بطبيعة التظهير:

١- الصفة في التوقيع:

يشترط في التظهير أن يصدر عن شخص ذي سلطة وصفة في التوقيع، وذلك بأن يكون المظهر هو مالك الحق الثابت في الكمبيالة أو وكيلاً عنه. فالوكيل العام عن شخص في إدارة تجارته سلطة تظهير الكمبيالة ولمدير الشركة تظهير الكمبيالة التي تحملها الشركة ولكن إذا ظهرها بعد انقضاء الشركة فإنه يلتزم بها شخصياً لأن هذه السلطة تنتقل إلى المصطفى بعد انقضائها وفي مرحلة التصفية طالما كان ذلك في حدود احتياجات التصفية.

إذا صدر التظهير نيابة عن حامل الكمبيالة بغير تفويض منه، أو إذا تجاوز الوكيل حدود السلطة المخولة له، فإن من قام بهذا التوقيع يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه.

لا يجوز للمفلس تظهير الكمبيالة بعد صدور حكم الإفلاس فإن فعل ذلك فلا يحتج به على جماعة الدائنين، وتصرفات المفلس صحيحة في العلاقة بينه وبين المظهر إليه، ولكن لا تنفذ بالنسبة لجماعة الدائنين، لأن شهر الإفلاس لا يعتبر من قبيل نقص الأهلية أو أنعدامها وإنما هي رفع يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها لأن الذي يتولى ذلك هو السنديك.

قد قرر المشرع في المادة ٥٩٠ من القانون التجاري أنه "لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.

قد أضاف المشرع في المادة ٢/٥٩٠ أنه إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق إلا إذا عارض أمين التفليسة في هذا الوفاء.

لا يجوز للمدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس تظهير الكمبيالة وفاءا للديون قبل حلول أجلها، حيث لا يحتج بهذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين.

يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعية الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وإذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعية الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف.

٢- شرعية حق المظهر:

شرعية حق المظهر أو الحامل هي شرط لاستعمال جميع حقوقه المصرفية. وذهب رأي إلى أن المقصود بالحامل الشرعي هو المستفيد الأصلي أو من آلت إليه الورقة بمقتضى سلسلة متصلة غير منقطعة من التظهيرات.

المشرع اعتبر الحامل حائز شرعيا للكمبيالة إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من التظهيرات غير المنقطعة.

الواقع أن شرعية الحامل ليست قاصرة على هذه الفروض فقط، بل هناك من يكون مالكا للحق الثابت في الكمبيالة دون أن يكون هو المستفيد الأصلي ودون أن تصل إليه عن طريق التظهير الصحيح كما لو اكتسب ملكية الحق الثابت فيها بالميراث أو الوصية.

٣- أن يكون التظهير باتا غير معلق على شرط:

يعتبر التظهير المعلق على شرط فاسخ أو واقف باطلا باعتباره تظهيراً، فيشترط في التظهير أن يكون خاليا من كل شرط، وذلك حتى لا يكون التزام المظهر معلقا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع أو غير مؤكد وهو ما يعطل تداول الورقة التجارية فالتظهير يجب أن يكون باتا منجزا.

س ٢٤ : ماهو حكم التظهير الذي يقع بعد ميعاد الاستحقاق ؟

التظهير بعد ميعاد الاستحقاق:

الكمبيالة تظل محالا للتداول حتى ميعاد الاستحقاق حيث انها يمكن أن تكون محالا لسلسلة من التظهيرات في الفترة بين تحريرها وتاريخ استحقاقها حتى تستقر في يد الحامل الأخير الذي يجب عليه بدوره تقديم الورقة للمدين الأصلي للوفاء بقيمتها، فإذا قام المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة واستردادها انتهت حياة الورقة وانقضى الالتزام الصرفي.

لكن قد يحدث أن يحل الميعاد دون أن يطلب الحامل بقيمة الورقة التجارية ثم يقوم بتظهيرها بعد ميعاد الاستحقاق- سواء في يوم الاستحقاق نفسه أو قبل فوات مواعيد تحرير الاحتجاج.

هل يعتبر من الشروط الموضوعية أن يتم التظهير قبل ميعاد الاستحقاق؟

ما هو حكم التظهير الذي يقع بعد ميعاد الاستحقاق؟

هل يجوز مثل هذا التظهير وما هي الآثار التي تترتب عليه؟

أجاب القانون التجاري على هذا التساؤل وقرر في المادة ٤٠٠ بأن "التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق".

من ذلك يتضح أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ناقلا للملكية وتكون له نفس الآثار التي ينتجها التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق بشرط أن يقع التظهير قبل انقضاء الميعاد المحدد لتحرير احتجاج عدم الوفاء وهو خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق - أي قبل تحرير هذا الاحتجاج، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق وبالتالي لا تطبق قاعدة تظهير الدفع.

كان موضوع التظهير بعد ميعاد الاستحقاق مثار جدل كبير في الفقه.

فهناك فريق من الفقه والقضاء في فرنسا كان قد ذهب إلى أن ميعاد الاستحقاق هو نهاية حياة الورقة التجارية وبالتالي تتوقف أحكام قانون الصرف، فبعد هذا التاريخ تتحول الورقة إلى سند مدني يفقد قدرته على التداول بالطرق التجارية.

كان الرد على ذلك هو أن ميعاد الاستحقاق لا يعتبر نهاية لتطبيق أحكام قانون الصرف لأن هناك أحكام في قانون الصرف لا يعمل بها إلا بعد ميعاد الاستحقاق منها احتجاج عدم الوفاء والتقادم الصرفي.

كان هناك فريقا آخر في الفقه تؤيده محكمة النقض الفرنسية ذهب إلى أنه ليس ثمة تفرقة بين التظهير قبل ميعاد الاستحقاق والتظهير بعده.

قد استقر القضاء الفرنسي على هذا الرأي الأخير ورتب على التظهير بعد ميعاد الاستحقاق ذات آثار التظهير الذي يقع قبل ميعاد الاستحقاق فهو ينقل الحق الثابت في الكمبيالة.

قد تعرضت محكمة النقض المصرية لهذا الموضوع في حكم لها قالت فيه: "لا وجه للتفرقة بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الاستحقاق والتظهير الحاصل بعد هذا الميعاد. إذ يكون لكل منهما ذات الآثار القانونية من حيث نقل ملكية السند وتظهير الدفع.

أما موقف الفقه المصري في ذلك الوقت فقد استقر على أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق جائز ويرتب نفس آثار التظهير الذي تم قبل ميعاد الاستحقاق.

قد قرر قانون جنيف الموحد في المادة ٢٠ منه أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ناقلا للملكية وتكون له نفس الآثار التي ينتجها التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق وذلك بشرط أن يقع التظهير قبل تحرير البروتستو او قبل انقضاء الميعاد المحدد لتحريره.

كما سبق ان ذكرنا فإننا نرى على الرغم من نص القانون التجاري أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق والحاصل بعد تحرير احتجاج عدم الوفاء تظهير ناقلا للملكية يرتب نفس آثار التظهير السابق لميعاد الاستحقاق لان تحرير احتجاج عدم الوفاء ضمانا لحامل الكمبيالة حيث لا يعتبر حاملا مهما مما يعطى له الحق في الرجوع على الموقعين على الكمبيالة ويطهره من الدفع.

التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق بعد سقوط عمل الاحتجاج، لانقطاع ميعاد الاحتجاج دون عمله، فهذا هو التظهير الذي لا يعتبر مثل التظهير السابق على ميعاد الاستحقاق ولا يرتب نفس آثاره وانما هو حوالة حق ينتج آثارها.

٤- أن يكون التظهير كليا:

يشترط في التظهير أن يرد على مبلغ الكمبيالة بالكامل، فالتظهير يجب أن يكون كليا، والتظهير الذي لم يرد على مبلغ الكمبيالة بأكمله يكون تظهير باطلا.

قد نص القانون التجاري على ذلك حيث قرر بأن "ويكون التظهير الجزئي باطلا". والحجة في ذلك أن التظهير الجزئي من شأنه أن يعرقل تداول الكمبيالة.

رأينا الخاص في التظهير الجزئي:

التظهير الجزئي يذهب بنا إلى معنيين، إما أن يرد التظهير على جزء من مبلغ الكمبيالة، وإما أن يتم التظهير من بعض المالكين للحق الثابت بها دون البعض الآخر، فما حكم التظهير الجزئي في الحالتين؟

(أ) بالنسبة للتظهير الجزئي الذي يرد على جزء من مبلغ الكمبيالة:

كنا نرى قبل صدور قانون التجارة أن هذا التظهير صحيحا ناقلا للملكية بالنسبة لجزء المبلغ المظهر من أجله، أما باقي المبلغ فإنني أعتبر التظهير بالنسبة له تظهيراً توكيلياً في قبض الباقي.

(ب) بالنسبة للتظهير الذي لا يتم من جميع المالكين للكمبيالة:

الغرض هنا أن الحق الثابت في الكمبيالة مملوك لأكثر من شخص، ولكن التظهير وقع من البعض دون البعض الآخر.

كنا نرى قبل صدور قانون التجارة أن التظهير الحاصل من البعض دون البعض الآخر يعد تظهيراً صحيحاً في مواجهة الموقعين فقط.

الشروط الشكلية

١- أن يتم التظهير بالكتابة:

يجب أن يتم التظهير بالكتابة، وعلى ذلك لا يعتد بالتظهير الذي يتم شفاهة، بل أنه غير متصور أن يتم كذلك نظراً لطبيعة الورقة التجارية في التداول والضمانات التي تحملها، حيث يجب على الحامل معرفة جميع المظهرين السابقين ولا سبيل إلى ذلك إلى بالكتابة على الكمبيالة.

وتعد الكمبيالة قابلة للتداول بالتظهير ولو لم يضع الساحب عبارة "لأمر" في متن الصك.

٢- أن يرد التظهير على الكمبيالة نفسها أو ورقة متصلة بها:

يجب أن يرد التظهير على ذات الكمبيالة حتى يتحقق لها الاستقلال والكفاية الذاتية وتنبئ عن مضمونها أما إذا استغرقت التظهيرات الكمبيالة كلها ففي هذه الحالة يمكن أن يرد التظهير على ورقة متصلة بالكمبيالة تسمى "وصلة" حيث جرت العادة على أنه إذا حدث وامتلاّت جميع فراغات الكمبيالة بحيث لا يوجد مكان لتظهير جديد فلا مانع من كتابة التظهير على ورقة متصلة بالكمبيالة يذكر فيها ملخص بيانات الكمبيالة.

أما إذا وقع التظهير على ورقة مستقلة غير متصلة بالكمبيالة فلا يعتبر تظهيراً بل حوالة مدنية.

س ٢٥: هل يجوز توقيع المظهر على الكمبيالة دون ذكر بيانات أخرى ؟

٣- توقيع المظهر:

يشترط المشرع أن يضع المظهر توقيعاً على التظهير وإلا اعتبر كأن لم يكن، حيث لا يحدث للتظهير أثره القانوني إذا خلا من توقيع المظهر بل أن المشرع أجاز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر دون ذكر بيانات أخرى، وفي هذه الحالة يسمى التظهير على بياض.

هذا التظهير على بياض لا يكون صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة وفي ذلك تنص المادة (٢/٣٩٣) على أنه: "ويجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

على أنه إذا اقتصر التظهير على توقيع المظهر ووضع هذا الأخير توقيعاً رغم ذلك على صدر متن الكمبيالة فإن هذا التظهير لا يعتبر صحيحاً وإنما يأخذ حكم الضمان الاحتياطي لصاحبه.

السبب في اشتراط المشرع وقوع التظهير على بياض على ظهر الكمبيالة هو عدم وقوع لبس أو غموض مع باقي التوقيعات التي تحملها الكمبيالة مثل التوقيع بالقبول أو الضمان الاحتياطي.

التظهير على وجه الكمبيالة ذاتها يكون صحيحاً إذا أشتمل على اسم المظهر إليه وتاريخ التظهير وتوقيع المظهر حيث لا يشير لبس أو غموض في هذه الحالة.

لكننا نرى أنه إذا اقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ووقع على صدر الكمبيالة واشتتمل على أي عبارة تفيد نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة فإنه يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وينتج أثره ولا يعتبر للضمان.

توقيع المظهر قد يكون بالإمضاء أو الختم أو البصمة.

إذا كان التظهير على بياض بأن اقتصر على توقيع المظهر على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر باعتباره مظهر إليه كما يجوز أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض بأن يكتفي بوضع توقيعاً على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

٤- اسم المظهر إليه:

في حالة وقوع التظهير على صدر الكمبيالة فإنه بالإضافة إلى توقيع المظهر يجب ذكر اسم المظهر إليه، وإلا اعتبر توقيع المظهر المظهر بمثابة ضمان احتياطي للساحب. ولكن يجوز ألا يذكر اسم المظهر إليه في التظهير ويقتصر على توقيع المظهر ولكن يشترط لصحة هذا التظهير أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة، ويسمى التظهير في هذه الحالة "التظهير على بياض".

س ٢٦: ماهي أهمية تاريخ التظهير ؟

هـ- تاريخ التظهير:

يتضمن التظهير عادة تاريخه، فلا شك في أهمية تاريخ التظهير حيث يفيد تاريخ التظهير في التحقق من أهلية المظهر وقت التظهير، وكذلك في معرفة ما إذا كان التظهير قد تم خلال فترة الرتبة أو بعد شهر الإفلاس إذا كان المظهر تاجرا أشهر إفلاسه. المفروض في التاريخ المذكور في التظهير أنه صحيح بغير إثبات آخر وعلى من يدعي عدم صحته إقامة الدليل على ذلك.

المشرع في القانون التجاري افترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج، وبالتالي التظهير الخالي من التاريخ ينتج آثار التظهير الحاصل قبل الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج حيث ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة ويظهر الورقة من الدفع، إلا إذا ثبت أن التظهير الخالي من التاريخ حصل بعد الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج حيث يعتبر حوالة حق ينتج آثارها. وقد نصت المادة ٢/٤٠٠ تجاري على أنه "يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك".

بيانات التظهير الاختيارية:

يجوز للمظهر أن يدون بيانات اختيارية في صيغة التظهير. بناء على ذلك يجوز للمظهر أن يضع شرط عدم الضمان أو شرط الوفاء الاحتياطي أو شرط الرجوع بلا مصاريف. كما يجوز له أن يشترط عدم قابلية الكمبيالة للتداول بأن يضع عبارة "ليست للأمر".

آثار التظهير التام الناقل للملكية

أولاً: نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة:

يترتب على التظهير التام نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه، وملكية الحق الثابت في الكمبيالة ينتقل إلى المظهر إليه دون حاجة إلى رضا الساحب أو المسحوب عليه. انتقال الملكية إلى المظهر إليه مشروط بأن يكون هو الحامل الشرعي للكمبيالة عن طريق سلسلة متصلة من التظهير حتى ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. نظراً لانتقال الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه بالتظهير الصحيح التام، فإنه يقع عليه أيضاً نفس الالتزامات التي كانت على المظهر، فيلتزم بتقديم الكمبيالة للقبول إلى المسحوب عليه إذا كانت الكمبيالة متضمنة شرط التقدم للقبول أو واجبة الدفع بعد مدة من الإطلاع. قد نص القانون التجاري في المادة ١/٣٩٤ على الأثر الناقل للملكية بالتظهير التام حيث قال "ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة".

ثانياً: الالتزام بالضمان:

الالتزام بالضمان الناشئ عن تظهير الكمبيالة تقرر بحكم القانون، ولا ضرورة للنص عليه في صيغة التظهير، حيث يترتب على تظهير الكمبيالة تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية أن يصبح المظهر، إلى جوار الموقعين السابقين، ضامناً لقبول الكمبيالة من المسحوب عليه وضامناً للوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق ما لم يشترط غير ذلك.

قد نص القانون التجاري في المادة ١/٣٩٥ على أن "يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك"، وعلى ذلك فإن المظهر يضمن للمظهر إليه ولكل حامل يليه ليس فقط وجود الحق وقت التظهير وإنما وفاؤه وقت الاستحقاق، على خلاف الحال في الحوالة المدنية حيث لا يضمن المحيل الوفاء وإنما يضمن فقط وجود الحق وقت الحوالة فهو لا يضمن يسار المحال عليه. ولكن في التظهير التام الناقل للملكية يضمن المظهر التنفيذ النهائي للكمبيالة، بحيث إذا رفض المسحوب عليه وفاء الحق عند المطالبة في ميعاد الاستحقاق كان للمظهر إليه الحامل للكمبيالة الرجوع على المظهر وعلى الموقعين السابقين جميعا بدعوى الضمان وذلك بعد تحرير الاحتجاج وإعلانه ورفع دعوى الضمان في المواعيد القانونية.

على ذلك فإن شرط رجوع الحامل على المظهرين بدعوى الضمان هو اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك، ويترتب على إهمال اتخاذ أي منها سقوط الحق في الرجوع عليهم دون المدين الأصلي. كما سبق أن ذكرنا، الالتزام بالضمان تقرر بحكم القانون ولا ضرورة للنص عليه في صيغة التظهير، ولكن يجوز للمظهر أن يشترط عند إجراء التظهير إعفاؤه من الضمان المقرر بحكم القانون. شرط عدم الضمان من الشروط الاختيارية التي يجوز للمظهر وضعها في الكمبيالة عند التظهير كما يجوز للمظهر وضع شرط عدم القبول أيضا. ويجب ذكر شرط عدم الضمان كتابة عند التظهير، واشترط المظهر عدم الضمان لا ينصرف إلى وجود الحق وقت التظهير حيث أنه يضمن ذلك وإنما لا يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة عند الاستحقاق لأنه لا يضمن يسار المدين. اشتراط المظهر حظر تظهير الكمبيالة من جديد يأخذ حكم عدم الضمان بالنسبة لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

لا يستفيد من هذا الشرط إلا المظهر الذي وضعه فقط، أما المظهرين السابقين أو اللاحقين لهذا التظهير فلا يستفيدون من شرط عدم الضمان ويظل التزامهم بالضمان قائما تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات. يجوز للساحب أيضا أن يشترط عدم الضمان بشرط أن يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأن يقبل هذا الأخير الكمبيالة. في هذه الحالة يفيد من الشرط جميع الموقعين على الكمبيالة، أما إذا تبين أن الساحب لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه ولم يقبل هذا الأخير الكمبيالة بناء على ذلك فإن الساحب يظل مسئولا عن الوفاء باعتباره هو المدين الأصلي ويظل جميع الموقعين مستفيدين من هذا الشرط.

س ٢٧: اكتب في قاعدة تظهير الدفع ؟

ثالثا: تظهير الكمبيالة من الدفع (قاعدة تظهير الدفع):

١ - المقصود بقاعدة تظهير الدفع:

يقصد بهذه القاعدة أن المدين بالكمبيالة سواء كان الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين ، لا يجوز له أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل حسن النية مستندا إلى دفع كان يستطيع أن يتمسك به في مواجهة دائئه المباشر. أي أن الحامل حسن النية الذي لا يقصد الإضرار بالمدين بالكمبيالة وقت تلقيه الحق يتلقى الحق خاليا من العيوب التي تشوبه، فلا يستطيع المدين التمسك في مواجهته بالدفع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة حامل سابق.

وقد جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ونص صراحة على هذه القاعدة في المادة ٣٩٧ بقولها "مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٣٨٥ من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن يقصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين".

وتعتبر قاعدة تظهير الورقة من الدفع من أهم قواعد قانون الصرف وأهم أثر من أثار التظهير التام الناقل للملكية.

وأساس قاعدة تظهير الدفع أن الحقوق المرتبطة بصك الكمبيالة تنفصل عن الدين الأصلي، فوجود الصفة المصرفية للالتزام في الورقة التجارية ناشئ عن صحة الورقة ككمبيالة وليس من وجود الالتزام الأصلي أو صحته.

هذا ولا أثر لإهمال حامل الكمبيالة في عمل احتجاج عدم الوفاء على قاعدة تطهير الدفع. فقد قضت محكمة النقض بأن "إهمال حامل الورقة التجارية في عمل بروتستو عدم الدفع وفي اتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التي حددها قانون التجارة لا يسقط حقه في الرجوع على المدين الأصلي".

كما أن قاعدة تطهير الدفع تطبق أيضا على الصكوك المدنية التي تتضمن شرط الأمر أو الإذن حيث نصت المادة ٦٥ من قانون التجارة في شأن هذه الصكوك على أن كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير. ولا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله- وقت حصوله على الصك- الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين".

ويتضح من نص هذه المادة أن المشرع في قانون التجارة عامل الصكوك المدنية معاملة الأوراق التجارية خاصة إذا تم إنشاء الصك بمناسبة عملية تجارية.

والحقيقة أن ما جاء به المشرع في المادة ٦٥ من قانون التجارة يخالف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. فالتظهير التام للكمبيالة له آثار ثلاثة، الضمان ونقل الملكية وتطهير الورقة من الدفع، أما تطهير الأوراق المدنية فهو لا يرتب إلا أثر نقل الحق الثابت في الورقة.

والحقيقة أن ما ذهب إليه المشرع في المادة ٦٥ من قانون التجارة يتفق مع ما ذهب إليه في المادة ٣٧٨ من أن الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك ليست واردة على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال ولا يمنع من تطبيق أحكام قانون الصرف على غيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها بشرط أن تحمل خصائص هذه الأوراق التجارية.

٢- شروط تطبيق القاعدة:

الشرط الأول: أن يكون التظهير تاما ناقلا للملكية:

لكي تطبق قاعدة تطهير الكمبيالة من الدفع لابد أن تكون الكمبيالة مظهرة تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية، فيجب أن يكتمل للتظهير بياناته حيث يجب أن يشتمل على توقيع المظهر واسم المظهر إليه إذا كان التظهير على وجه الورقة حتى يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية، أما التظهير التوكيلي فليس من شأنه تطهير الورقة من الدفع وكذلك انتقال الكمبيالة بطريق الحوالة المدنية أو إلى حاملها عن طريق الميراث أو الوصية.

أما التظهير التأميني، وهو عبارة عن تظهير الكمبيالة إلى الدائن المرتهن على سبيل الرهن أو على سبيل التأمين، فمثله في ذلك مثل التظهير الناقل للملكية حيث تطبق قاعدة تطهير الدفع كأثر من أثاره.

الشرط الثاني: أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية:

يجب أن يكون حامل الكمبيالة (المظهر إليه) حسن النية عند تلقيه الكمبيالة - وقت التظهير، فإذا كان سئ النية فإن هذه القاعدة لا تطبق وبالتالي يجوز للمدين بالكمبيالة التمسك في مواجهة الحامل بكل الدفع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المظهر.

مفهوم حسن النية في ظل المجموعة التجارية الملغاة:

اختلف الفقه في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة في تحديد المقصود بحسن النية فقد ذهب الرأي الراجح إلى أن المقصود بحسن النية هو عدم علم الحامل المظهر إليه بوجود العيب الذي يدفع به في مواجهته، ويعتبر سئ النية إذا كان يعلم وقت تلقيه الكمبيالة بوجود هذا العيب أو الدفع، فإذا تم إثبات هذا العلم فإنه لا يعتبر حسن النية ويمكن التمسك في مواجهته بالدفع الذي كان يعلم به ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر، أي ولو لم يثبت قصد الإضرار بالمدين وقت حصوله على الكمبيالة، لأن علة هذه القاعدة أنه لا يجوز مفاجأة المظهر المظهر إليه بدفع لم يكن يعلمه عندما تلقى الورقة بالتظهير.

موقف قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ عن مفهوم سوء النية:

أخذ قانون التجارة الجديد بالاتجاه الذي أخذ به قانون جنيف الموحد ولم يكتفي بمجرد علم الحامل بهذا الدفع وقت تلقيه الكمبيالة حتى يعتبر سئ النية وإنما اشترط أن يكون الحامل وقت حصوله على الكمبيالة قاصدا الإضرار بالمدين ويحدث ذلك إذا صدر غش أو تواطؤ أو اشتراك في تدليس بين المظهر وحامل الكمبيالة.

وقد قامت محكمة النقض الفرنسية بشرح ذلك وقضت بأن المقصود بسوء النية هو إدراك المظهر، عند تظهير الكمبيالة بالإضرار بالمظهر إليه بوضعه في مركز يحرمه من الافادة أو الانتصار في مواجهة الساحب أو موقع سابق بوسائل دفاع ناشئة عن علاقاته السابقة بهؤلاء".

والوقت الذي يعتد فيه بسوء النية وقصد الإضرار بالمدين هو وقت حصول الحامل على الكمبيالة.

وفقاً للقواعد العامة يعتبر حامل الكمبيالة حسن النية إلى أن يثبت العكس ولصاحب المصلحة إثبات سوء نية حامل بكافة طرق الإثبات ومما لا شك فيه أن إثبات قصد الحامل الإضرار بالمدين يمثل صعوبة كبيرة على خلاف إثبات علم الحامل بالدفع.

٣- نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفع:

هناك دفع يطهرها التطهير ودفع لا يطهرها التطهير.

الدفع التي لا يحتج بها على الحامل حسن النية (دفع يطهرها التطهير):

أ) الدفع بانعدام السبب أو عدم مشروعيته:

إذا استند سحب الكمبيالة أو تطهيرها إلى علاقة غير مشروعة أو نتيجة لعملية غير مشروعة بين الساحب والمستفيد أو بين المظهر والمظهر إليه، كأن يكون تحرير الكمبيالة أو تطهيرها تسوية لدين قمار، ففي هذه الحالات لا يجوز التمسك ببطان الالتزام في مواجهة الحامل حسن النية.

ب) الدفع بعيوب الإرادة:

لا يمكن التمسك في مواجهة الحامل حسن النية بالدفع بوجود عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه الذي لا يعدم الإرادة أو التدليس أو الاستغلال، فهذه العيوب وإن جاز التمسك بها في مواجهة من تلقى الكمبيالة مباشرة ممن شاب العيب رضاه فإنه لا يجوز التمسك بها أمام حاملين الذين تلقوا الكمبيالة وهم حسن النية بأن لم يكن لديهم قصد الإضرار بالمدين وقت حصولهم على الكمبيالة.

ج) الدفع بفسخ أو انقضاء العلاقة الأصلية:

لا يجوز التمسك في مواجهة الحامل حسن النية بفسخ العقد الذي من أجله حررت الكمبيالة بين الساحب والمستفيد، كذلك لا يجوز للمدين الاحتجاج بأنه أو في الدين لحامل آخر أو أن دينه انقضى بسبب مقاصة على حق له ضد حامل سابق، أو أن دينه انقضى بالسقوط بالتقادم في مواجهة المظهر إليه المباشر.

الدفع التي يحتج بها على الحامل ولو كان حسن النية (دفع لا يطهرها التطهير):

أ) الدفع الناشئ عن عيب شكلي:

الدفع الناشئ عن عيب ظاهر في الكمبيالة يحتج به على الحامل ولو كان حسن النية لأن ظهور العيب لا يفترض معه حسن نية الحامل، والظهور هنا يفترض لأنه ينبغي التأكيد من توافر البيانات الإلزامية قبل استلام الكمبيالة، فحامل الكمبيالة التي بها عيب شكلي لا يعتبر حسن النية حتى ولو كان يجهل هذا العيب، وبالتالي يستطيع المدين أن يدفع في مواجهة الحامل بطلان الكمبيالة.

ب) الدفع بانعدام الإرادة:

انعدام الإرادة ينشأ إذا حررت الكمبيالة أو ظهرت تحت تأثير إكراه مادي مطلق، أو صدر التوقيع من محررها أو مظهرها وهو في حالة غيبوبة ودون إهمال منه، فالتطهير المصاحب لانعدام الرضا لا يطهر الكمبيالة من الدفع لأن الالتزام الصرفي الذي تعتبر إرادة الموقع مصدره الأول لا يقوم ولا ينشأ، لذلك فإن انعدام الإرادة يحتج به على الحامل ولو كان حسن النية.

قد نص القانون التجاري في المادة ٢٨٦ على أنه "إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو أشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة".

ج) الدفع بانعدام أو نقص الأهلية:

رغم أن هذا العيب غير ظاهر في الكمبيالة إلا أن المشرع قدر أن مصلحة عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أولى بالرعاية من مصلحة الحامل حسن النية، لذلك يجوز لناقص الأهلية أو عديمها أن يحتج بنقص أهليته أو أنعدامها على الحامل ولو كان حسن النية، ولا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا عديم أو ناقص الأهلية فقط حيث أن هذا البطلان مقرر لمصلحته فقط.

(د) الدفع المستمد من علاقة شخصية بين المدين والحامل:

الدفع الناشئة عن العلاقة الشخصية بين المدين والحامل لا يظهرها تظهير الكمبيالة، فيجوز للمدين التمسك في مواجهة الحامل بأي دفع يكون ناشئا عن علاقة شخصية بينهما، فإذا كان المدين بالكمبيالة دائنا لحامل الصك بناء على علاقة خارجة عن نطاق الكمبيالة فإنه يستطيع مطالبة الحامل بالمقاصة بدينه.

(هـ) الدفع بتزوير التوقيع:

يستطيع المدين في الورقة التجارية الدفع بأن توقيعه مزورا، نظرا لأنه في هذه الحالة لا توجد إرادة بالالتزام على الإطلاق وهو يقوم بهذا الدفع حتى في مواجهة الحامل حسن النية، فالتظهير لا يظهر هذا الدفع.

(و) الدفع الناشئ عن التوقيع بلا تفويض:

يأخذ نفس الحكم السابق بحصول التوقيع على الكمبيالة من شخص غير مفوض في ذلك، فإذا حرر شخص كمبيالة للأمر أو ظهرها باسم غيره دون أن يكون مفوضا في ذلك منه بوكالة صريحة أو ضمنية فلا يلزم الموكل المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة حتى ولو كان الحامل حسن النية، ويأخذ نفس الحكم إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته.

(ي) الدفع المستمد من مضمون الكمبيالة:

إذا ورد في الكمبيالة شرط من الشروط الاختيارية التي يجوز للساحب أو أحد المظهرين وضعها في الكمبيالة لتعديل أحكام الالتزام الصرفي كشرط عدم الضمان، أو عدم الوفاء، وغيرها من الشروط، في هذه الحالات يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة الحامل بهذه الشروط ولو كان حسن النية.

التظهير التوكيلي

المقصود بالتظهير التوكيلي ← قيام المظهر بتوكيل المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها.

شروط التظهير التوكيلي

أولاً: الشروط الموضوعية:

في التظهير التوكيلي لا يشترط في المظهر أن تنوافر فيه أهلية الالتزام بالأعمال التجارية لأنه لا ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة، ولكن في التظهير الناقل للملكية يشترط أهلية القيام بالأعمال التجارية، أما أهلية المظهر إليه فيكفي أن يكون مميزاً، لأن الوكالة لا تفترض في الوكيل أهلية الالتزام حيث ينصرف آثار الالتزام الذي ينتج عن عمله إلى الموكل ولا ينصرف إلى الوكيل. يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يظهر الكمبيالة التي يملكها ناقص الأهلية لتحصيل قيمتها.

ثانياً: التظهير التوكيلي يجب أن يكون صريحاً:

يجب أن يكون التظهير التوكيلي صريحاً، بأن تدل عبارته بوضوح على أن المظهر موكل المظهر إليه في القبض، حيث يذكر في التظهير صراحة أن المقصود منه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة كان يقال مثلاً القيمة للتحصيل.

قد نص القانون التجاري على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو القيمة للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.

يتضح من النص المشار إليه أن المظهر إليه توكيلياً من حقه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة مثل تحصيل قيمتها أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لذلك حماية لمصالح وحقوق المظهر مثل عمل الاحتجاج وإعلانه للملتزمين بموجب الكمبيالة وإقامة دعوى الرجوع.

آثار التظهير التوكيلي

أولاً: آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للمظهر والمظهر إليه:

- ١- يلتزم المظهر إليه بتنفيذ تعليمات المظهر باعتباره وكيله عنه، فعليه أن يقدم الكمبيالة للقبول وأن يطالب بقيمتها وأن يطالب بقيمتها في ميعا الاستحقاق وإخطار المسحوب عليه إذا تطلب المظهر ذلك واشترط، ويكون المظهر إليه مسئولاً إذا لم تتبع هذه التعليمات حيث يعتبر ذلك إهمالاً منه في تنفيذ الوكالة إذا ترتب على ذلك ضرراً بالمظهر.
- ٢- يلتزم المظهر إليه بتقديم حساب للموكل (المظهر)، وبالتالي يوافي المظهر بقيمة الكمبيالة التي قام بتحصيلها، كما يلتزم المظهر أن يرد للمظهر إليه الوكيل كافة المصروفات التي أنفقها في سبيل تحصيل الكمبيالة.
- ٣- يجوز للمظهر أن يعزل المظهر إليه (الوكيل) في كل وقت ولو بعد حلول ميعاد الاستحقاق ما دام أن الوفاء بقيمتها لم يتم بعد، وإذا أفلس المظهر إليه (الوكيل)، يجوز للمظهر (الموكل) استرداد الكمبيالة إذا كانت لم تحصل بعد، فإذا كان المظهر إليه قد قبض قيمتها فإن المظهر ليس أمامه إلا الدخول في التفليسة كدائن عادي يخضع لقسمة الغرماء. ولكن إذا قام المدين بالكمبيالة بالوفاء بقيمتها للوكيل المظهر إليه دون أن يعلم بوفاء المظهر أو إفلاسه أو فقدانه لأهليته، هل يعتبر وفاءه الكمبيالة صحيحاً لم يجبر على الوفاء مرة أخرى؟ وضع قانون جنيف الموحد حلاً لهذا وقرر بأن الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا تنقضي بوفاء الموكل أو فقد أهليته.

ثانياً: آثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر إليه بالغير:

- ١- يجوز للمدين والضامن في الكمبيالة التمسك بالدفع التي كان يمكن التمسك بها في مواجهة المظهر.
- ٢- للمظهر إليه أن يتخذ في مواجهة الغير - المسحوب عليه أو الموقعين المظهرين - كافة الإجراءات التي تتطلبها قانون الصرف ومنها توقيع الحجز التحفظي على المدين بالكمبيالة وله أن يطلب شهر إفلاسه.
- ٣- لا يجوز للمظهر إليه تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل.
- ٤- في علاقة المظهر إليه بالغير يعتبر التظهير المعيب الناقص أو التظهير على بياض الصادر من المظهر إليه الوكيل في حكم التظهير التوكيلي لأنه لا يجوز له تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل.

التظهير التأميني

ماهية التظهير التأميني

-  **المقصود بالتظهير التأميني:** رهن الحق الثابت في الكمبيالة، والتظهير التأميني يجب أن يتضمن ما يفيد بأن التظهير للرهن أو التأمين أو لضمان أو أي بيان آخر يفيد الرهن.
-  يلجأ المظهر إلى تظهير الورقة تظهيراً تأمينياً عندما يكون بحاجة إلى نقود عاجلة وتكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة، فيلجأ المظهر إلى افتراض المبلغ الذي يحتاجه ويرهن الورقة أي الحق الثابت بها بتظهيرها بما يفيد ذلك ضماناً للقرض الذي أخذه، ويلجأ المظهر إلى ذلك عندما يكون بحاجة إلى مبلغ قليل عما هو مدون بالكمبيالة لأنه لو كان يحتاج إلى مبلغ مساوي للكمبيالة لكان في مقدوره أن يخصم الكمبيالة بتظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية إلى أحد البنوك فيحصل على قيمتها بعد خصم عمولة البنك.

شروط التظهير التأميني:

١- الشروط الموضوعية:

يشترط في التظهير التأميني أن يكون المدين الراهن مالكاً لمحل الرهن، ويجب أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة، ويجب أن تتوافر فيه أهلية القيام بالأعمال التجارية.

٢- الشروط الشكلية:

تطلب المشرع في التظهير التأميني أن يكون صريحا، وذلك بأن يشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان، أو القيمة للرهن.

س ٢٩: ماهي الآثار المترتبة على التظهير التأميني ؟

آثار التظهير التأميني:

أولاً: العلاقة بين المظهر والمظهر إليه:

- ١- يلتزم المظهر إليه بتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها، لأن تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة يكون بمعرفة الدائن المرتتهن لها.
- ٢- لا يجوز للمظهر إليه تظهيرا تأمينيا إعادة تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية، وإنما يجوز له تظهيرها تظهيرا توكيليا.
- ٣- للمظهر إليه القيام بكافة الإجراءات القانونية التي يطلبها قانون الصرف، من القيام بعمل الاحتجاج في حالة الامتناع عن دفع قيمة الكمبيالة، إلى إعلان الاحتجاج وإقامة الدعوى، ويجب أن يقوم بهذه الإجراءات في مواعيدها.
- ٤- إذا حل ميعاد الاستحقاق وكان ذلك موافقا لميعاد استحقاق الدين المضمون بالرهن، فإن المظهر إليه يحصل على قيمة الكمبيالة إذا كان مساويا لمبلغ الدين المرهون، أما إذا كان مبلغ الكمبيالة أكبر، فإن المظهر إليه برد إلى المظهر باقي قيمة الكمبيالة. أما إذا كان ميعاد الاستحقاق أسبق من ميعاد الدين المرهون فإن المظهر إليه يحصل قيمة الكمبيالة ويظل محتفظا بالمبلغ إلى حين حلول ميعاد الدين فيستوفي حقه ويرد الباقي إلى المظهر إن وجد.

ثانياً: أثر التظهير التأميني في العلاقة بين المظهر إليه والغير:

يعتبر التظهير التأميني بالنسبة للغير في حكم التظهير الناقل للملكية فيما يتعلق بتطبيق قاعدة تظهير الدفع، بحيث لا يجوز للمدين أو لأحد المظهرين أو الضامنين التمسك في مواجهة المظهر إليه (الدائن المرتتهن) متى كان حسن النية بالدفع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المظهر (الراهن). يتضح من ذلك أنه لا يحق للمدين بالكمبيالة التمسك في مواجهة الدائن المرتتهن (المظهر إليه) بالدفع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المظهر (المدين الراهن) وتطبيق قاعدة تظهير الدفع لحماية يقتصر على حدود دينه المضمون بالرهن فقط.

يفترض حسن النية في المظهر إليه (الدائن المرتتهن) حامل الكمبيالة الذي يتلقاها بمقتضى التظهير على سبيل الرهن، ويقع على عاتق المدين إثبات قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة

أمعن المشرع في تدعيم حق الحامل، وأحاطة بسياج من الضمانات التي تكفل له الحصول على حقه، فأعطى للحامل الحق في ملكية مقابل الوفاء- الموجود تحت يد المسحوب عليه - دون غيره من دائني الساحب بمجرد تحرير الكمبيالة.

أيضا من الضمانات التي قررها المشرع أنه أجاز للحامل ولكل حائز للكمبيالة تقديمها للقبول إلى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق.

جميع الموقعين على الكمبيالة ملتزمين بالتضامن فيما بينهما للوفاء بقيمتها مما يعطى للحامل ضمانا جديدة للحصول على حقه غير أن الحامل قد لا يكتفى بهذه الضمانات القانونية، فيطلب من مدينه ضمان احتياطي يتمثل في تقديم كفيل، وقد يطلب الحامل من مدينه تقديم ضمان عيني كرهن.

مقابل الوفاء

ماهية مقابل الوفاء وأهميته

ماهية مقابل الوفاء:

مقابل الوفاء ← هو دين نقدي مساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة يكون للساحب عند المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق والذي يدفع منه هذا الأخير قيمة الكمبيالة.

سحب الكمبيالة تفترض وجود علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه تجعل الأول دائما للثاني أيا كان طبيعة الدين تجاري أو مدني.

أهمية مقابل الوفاء:

لمقابل الوفاء دور هام في حياة الالتزام الصرفي، حيث له أهميته وتأثيره في مراكز أصحاب الشأن في الكمبيالة، ورغم أنه لا يعتبر شرطا لصحة إنشاء الكمبيالة إلا أن له أهمية في تداول الكمبيالة، وبالتالي القيام بوظائفها كأداة وفاء وأداة ائتمان.

أهمية مقابل الوفاء فيما يلي:

١- أهمية مقابل الوفاء للمسحوب عليه:

وجود مقابل الوفاء يجعل المسحوب عليه يقبل الكمبيالة، والمشرع قرر في المادة ٤٠٢ من قانون التجارة أن "يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل".

إذا أوفى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة نتيجة وجود مقابل الوفاء لديه فإن ذمته تبرأ من هذا الدين الذي يلتزم به تجاه الساحب، ولا يجوز نتيجة لهذا الوفاء الرجوع على الساحب بما أوفاه.

٢- أهمية مقابل الوفاء للحامل:

الحامل أيضا يهتم الوفاء لأن وجوده لدى المسحوب عليه يسهل من الحصول عليه، لأن المسحوب عليه عادة لا يقبل الكمبيالة إلا إذا تلقى مقابل الوفاء من الساحب، فإذا تلقى المسحوب عليه مقابل الوفاء فإنه في الغالب يقبل الكمبيالة ويتحول بهذا القبول إلى المدين الأصلي مما يسهل على الحامل الرجوع عليه.

٣- أهمية مقابل الوفاء للساحب:

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء، ويستفيد الساحب في حالة تقديمه مقابل الوفاء للمسحوب عليه وإثبات ذلك من إهمال الحامل في المطالبة بقيمة الكمبيالة واتخاذ إجراءات الرجوع في مواعيدها.

١٥ "وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته".

٤- أهمية قابل الوفاء للمظهرين:

١٥ لا أهمية لمقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين، لأن من حقهم دائماً الاستفادة من إهمال الحامل والتمسك في مواجهته بسقوط حقه في الرجوع عليهم نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم اتخاذها في مواعيدها.

س ٣٠: اشرح شروط وجود مقابل الوفاء ؟

شروط وجود مقابل الوفاء

أولاً: أن يكون محل دين مقابل الوفاء مبلغاً من النقود:

١٥ مقابل الوفاء لا يجوز أن يكون شيئاً آخر غير النقود.

١٥ قد ينشأ مقابل الوفاء منذ البداية في صورة مبلغ من النقود مستحق للساحب لدى المسحوب عليه، كأن يكون المسحوب عليه قد حصل على قرض من الساحب، أو أن هذا الأخير وضع مبلغاً من المال لدى المسحوب عليه على سبيل الوديعة أما الأشياء الأخرى المودعة فإنها لا تصلح لأن تكون مقابل الوفاء لأنها ليست مبلغاً من النقود.

١٥ قد ينشأ مقابل الوفاء في صورة بضائع يرسلها الساحب إلى المسحوب عليه ثم تتحول هذه البضائع إلى مبلغ من النقود قبل ميعاد الاستحقاق، مثال ذلك أن يكون المسحوب عليه وكيلًا بالعمولة ويتسلم من الساحب بضاعة لبيعها فيكون مقابل الوفاء هو الثمن الناتج عن هذا البيع، وقد ينشأ مقابل الوفاء في صورة أوراق ذات قيمة مثل الأوراق التجارية يسلمها الساحب إلى المسحوب عليه لتحصيل قيمتها، مثل قيام الساحب بتسليم هذه الأوراق لأحد البنوك لتحصيل قيمتها، كما قد ينشأ مقابل الوفاء نتيجة فتح اعتماد من جانب المسحوب عليه للساحب.

ثانياً: أن يكون دين مقابل الوفاء موجوداً وقت استحقاق الكمبيالة:

١٥ يشترط أن يكون مقابل الوفاء موجوداً في ذمة المسحوب عليه وقت استحقاق الكمبيالة حيث يستطيع أن يوفي قيمتها، ولا يشترط وجود مقابل الوفاء وقت تحرير الكمبيالة، وإنما المهم هو وجوده وقت استحقاقها.

١٥ قد نصت المادة ٤٠١ من قانون التجارة على أن "على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء".

١٥ يتضح من ذلك أن الساحب هو المسؤول عن إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، وإذا كانت الكمبيالة سحبت لحساب الغير كان الساحب الحقيقي مسئولاً عن إيجاد مقابل الوفاء قبل المسحوب عليه أي في علاقته بالمسحوب عليه بمعنى أنه إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة على المكشوف كان له الرجوع على الساحب الحقيقي وليس الساحب الظاهري، بينما يكون الساحب الظاهري مسئولاً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.

١٥ يختلف مقابل الوفاء في الكمبيالة عن الشيك، حيث أن مقابل الوفاء في الشيك لا بد أن يكون موجوداً وقت إصدار الشيك، لأن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع.

ثالثاً: أن يكون دين مقابل الوفاء محقق الوجود ومستحق الاداء في تاريخ استحقاق الكمبيالة:

يجب أن يكون مقابل الوفاء غير معلق على شرط وغير متنازع على وجوده، بين الساحب والمسحوب عليه، وكذلك يجب ألا يكون محجوزاً عليه تحت يد المسحوب عليه حتى يكون مقابل الوفاء محقق الوجود.

يشترط أيضاً في مقابل الوفاء أن يكون مستحق الاداء وقت استحقاق الكمبيالة، لأن وجود الدين في ذمة المسحوب عليه لا يعني أن مقابل الوفاء موجود طالما أن أجل هذا الدين سوف يحل بعد ميعاد الاستحقاق، لأنه لا يجوز إجبار المسحوب عليه على الوفاء في ميعاد الاستحقاق والتنازل عن الأجل المقرر له من الساحب.

رابعاً: أن يكون دين مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة:

يجب أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة، فإذا كان أقل اعتبر مقابل الوفاء ناقصاً ويأخذ حكم مقابل الوفاء غير الموجود أصلاً.

لا يجوز للساحب أن يتمسك بسقوط حق الحامل المهمل لأن ذلك قائماً في حالة وجود مقابل الوفاء الذي يغطي قيمة الكمبيالة بالكامل.

لكن مقابل الوفاء الناقص يؤدي بعض الأثر بالنسبة للحامل، يتضح من ذلك أن للحامل حق على مقابل الوفاء الناقص يعادل حقه على مقابل الوفاء الكامل حيث يكون له استيفاءه بالأولوية عن غيره من دائني الساحب وليس للحامل رفض الوفاء الجزئي، حيث أن ذلك يؤدي إلى التخفيف عن الضامين.

إثبات وجود مقابل الوفاء

١- القاعدة العامة: أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي وجود مقابل الوفاء:

مما لا شك فيه أن مقابل الوفاء يقوم بدور هام في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه والحامل، حيث يكون لأطراف الكمبيالة مصلحة في إثبات مقابل الوفاء.

قد يكون من مصلحة الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء في مواجهة المسحوب عليه، وذلك عندما يمتنع هذا الأخير عن قبول الكمبيالة أو دفع قيمتها، حيث يضطر الساحب إلى الوفاء للحامل ثم يرجع على المسحوب عليه لمطالبته بالدين مع التعويض إن كان هناك ضرر بسبب الإساءة إلى سمعته وأثمنانه التجاري، لأنه على الساحب وحده أن يثبت في حالة إنكار المسحوب عليه وجود مقابل الوفاء - سواء حصل قبول للكمبيالة أم لم يحصل - أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق لكي تبرأ ذمته.

قد يدفع المسحوب عليه قيمة الكمبيالة ثم يرجع على الساحب مدعياً أنه أوفى قيمة الكمبيالة على المكشوف بدون أن يحصل على مقابل الوفاء، فلا سبيل أمام الساحب إلا إثبات أنه أعطى مقابل الوفاء للمسحوب عليه.

قد يكون من مصلحة المسحوب عليه إثبات عدم وجود مقابل الوفاء في مواجهة الساحب لكي يبرر امتناعه عن قبول الكمبيالة أو عدم الوفاء بها.

قد يكون للحامل مصلحة في إثبات وجود مقابل لدى المسحوب عليه حينما يمتنع الأخير عن قبول أو وفاء الكمبيالة، فلا يكون أمام الحامل دعوى قبل المسحوب عليه إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء عنده في ميعاد استحقاق الكمبيالة.

٢- القرينة على وجود مقابل الوفاء:

"يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل".

(أ) العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه:

تكون لهذه القرينة قيمتها في هذه العلاقة، حيث يعتبر قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه، وأنه تلقاه من الساحب، غير أن هذه القرينة بسيطة ويجوز إثبات عكسها، وعلى ذلك فإنه يجوز للمسحوب عليه رغم قبوله للكمبيالة إثبات عدم وجود مقابل الوفاء لديه وأنه وفي قيمة الكمبيالة على المكشوف.

(ب) العلاقة بين المسحوب عليه والحامل:

يعتبر قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة على تلقيه مقابل الوفاء وهذه القرينة مطلقة في علاقة المسحوب عليه بالحامل، فلا يستطيع المسحوب عليه إثبات عكسها.

(ج) العلاقة بين الساحب والحامل:

لا يستطيع الساحب أن يستفيد من قرينة قبول المسحوب عليه كدليل على وجود الوفاء، فلا محل لأعمال هذه القرينة في العلاقة بين الساحب والحامل أو بين الساحب والمظهرين.

س ٣١ / اكتب في ملكية مقابل الوفاء مبينا الحالات التي يمتلك فيها الحامل للكمبيالة مقابل الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق ؟

ملكية مقابل الوفاء

انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى حامل الكمبيالة.

أقر المشرع في قانون التجارة بحق الحامل في تملك مقابل الوفاء، فقد نصت المادة ٤٠٤/١ على أن "تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقدين".

مبدأ تملك الحامل لمقابل الوفاء يتقرر أيضا إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة ٤٠٤ على أنه "إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل".

يتملك الحامل أيضا مقابل الوفاء حتى ولو كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

على الساحب أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء حتى ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا، وهذا ما نصت عليه المادة (٤٠٥) من قانون التجارة الجديد كما ألزم المشرع أمين التفليسة في حالة إفلاس الساحب بتسليم الحامل المستندات التي تثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.

حتى في حالة إفلاس الساحب فإن المشرع أعطى للحامل دون غيره من دائني الساحب الحق في استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه، حتى ولو أفلس الساحب قبل حلول ميعاد الاستحقاق، وفي ذلك تنص المادة (٤٠٦) من قانون التجارة على أنه "إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه".

الوقت الذي يملك فيه الحامل مقابل الوفاء:

استقر الرأي على أن ملكية الحامل لمقابل الوفاء لا تثبت إلا وقت استحقاق الكمبيالة، أما قبل ذلك فإن الساحب يظل مالكا لكل حقوقه عند المسحوب عليه.

على ذلك فإن حق الحامل على مقابل الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق ليس إلّا حقا احتماليا، وبالتالي لا يفقد الساحب حقه في التصرف في مقابل الوفاء بمجرد سحب الكمبيالة وذلك للأسباب الآتية:

- ١- أن المسحوب عليه قد لا يعلم بسحب الكمبيالة وبالتالي لا يعلم عن ملكية الحامل شيئا.
- ٢- القول بملكية الحامل لمقابل الوفاء وقت إنشاء الكمبيالة معناه تجميد المبالغ التي تكون للساحب عند المسحوب عليه وقت إنشاء الكمبيالة وبقاؤها معطلة إلى حين حلول ميعاد الاستحقاق.
- ٣- أن مقابل الوفاء يعتبر ضمانا للحامل وليس شرطا لصحة الكمبيالة، وبالتالي لا أهمية لوجوده عند إنشاء الكمبيالة ولكن المهم وجوده وقت الاستحقاق. على أن حق الحامل على مقابل الوفاء يتأكد قبل حلول ميعاد الاستحقاق في الحالات الآتية:

١- قبول المسحوب عليه الكمبيالة قبل حلول ميعاد الاستحقاق:

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة يملك الحامل مقابل الوفاء منذ لحظة التوقيع بالقبول ويمتنع على الساحب استرداد المقابل أو التصرف فيه.

وإذا وضع الساحب شرط عدم القبول في الكمبيالة فإن هذا يعني احتفاظه بحق التصرف في مقابل الوفاء حتى حلول ميعاد الاستحقاق، فلا يملك الحامل مقابل الوفاء إلا في هذا الميعاد.

٢- تخصيص مقابل الوفاء للحامل:

قد يتفق الحامل مع الساحب صراحة أو ضمنا على تخصيص دين معين للساحب عند المسحوب عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة، ولكن هذا التخصيص لا يحتج به على المسحوب عليه إلا بإخطاره به، ويترتب على هذا التخصيص المصاحب بإخطار المسحوب عليه تجميد الحق عند هذا الأخير ووقفه على الوفاء بقيمة هذه الكمبيالة حيث يعتبر التخصيص بمثابة رهن مقرر للحامل على مقابل الوفاء فتكون له الأولوية عليه إذا اضطر للتزاحم مع غيره من دائني الساحب.

على أن قد يكون مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ديناً نقدياً في ذمته للساحب، فإذا أفلس المسحوب عليه في هذه الحالة، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة أما إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه ديناً نقدياً في ذمته للساحب، فإذا أفلس المسحوب عليه في هذه الحالة، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة أما إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وتم تخصيص هذا المقابل صراحة أو ضمناً للوفاء بقيمة الكمبيالة فإنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من هذا المقابل.

قد نصت المادة (٤٠٧) من قانون التجارة على أنه "إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته للساحب دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها".

٣- إخطار الحامل للمسحوب عليه بإنشاء الكمبيالة وتجميد الحق الموجود عنده:

إذا أخطر الحامل للمسحوب عليه بإنشاء الكمبيالة وطلب منه تجميد الحق الموجود عنده للساحب لكي يستعمله في الوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد الاستحقاق، حيث يعتبر هذا الإخطار بمثابة القبول فيما يتعلق بتثبيت ملكية الحامل على مقابل الوفاء، وبمجرد هذا الإخطار يمتنع على المسحوب عليه التصرف في مقابل الوفاء.

س ٣٢: اكتب في ملكية مقابل الوفاء مبينا الحالات التي يمتلك فيها الحامل للكمبيالة

آثار ملكية الحامل لمقابل الوفاء:

١- يترتب على ملكية الحامل لمقابل الوفاء النتائج الآتية:

١- حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء سواء قبل المسحوب عليه الكمبيالة أم لم يقبلها، فإذا قبل الكمبيالة كان للحامل الرجوع عليه بإحدى دعويين، دعوى ملكية مقابل الوفاء وهي دعوى عادية، ودعوى الصرف الناشئة عن توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة فإذا اختار الحامل الرجوع بدعوى الصرف، فإن المسحوب عليه لا يستطيع التمسك في مواجهة الحامل بالدفع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة الساحب وتسقط الدعوى بالتقادم الصرفي وهو مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولكن إلى جانب ذلك لا يتمتع الحامل بأي امتياز في تفليسه المسحوب عليه القابل.

٢- أما إذا اختار الرجوع بدعوى ملكية مقابل الوفاء، فإنها تكون دعوى عادية وبالتالي يجوز الاحتجاج عليه بالدفع التي كان يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الساحب، ويستطيع الحامل مطالبة المسحوب عليه بمقابل الوفاء حتى بعد انقضاء مدة التقادم الصرفي، ولكن من ناحية أخرى للحامل حق التمتع بالرهن أو الامتياز الضامن لدين مقابل الوفاء.

٣- لا يجوز لدائني الساحب توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على دين مقابل الوفاء من تاريخ تحرير الكمبيالة سواء قبلها المسحوب عليه أو لم يقبلها، لأنه بقبول المسحوب عليه يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء ويتملكه، أما إذا لم يقبلها المسحوب عليه فإنه رغم أن حق الحامل ما زال احتماليا على مقابل الوفاء إلا أن ذلك كافيا لمنع توقيع حجز على دين مقابل الوفاء.

٤- لا يجوز للمسحوب عليه بعد أن يتأكد حق الحامل في ملكية مقابل الوفاء - أن يرد مقابل الوفاء للساحب، وإلا كان مسئولا قبل الحامل.

٥- يجب على الساحب أن يمكن الحامل من مباشرة حقه على مقابل الوفاء بتسليمه المستندات اللازمة لحصوله على هذا المقابل، وفي حالة إفلاس الساحب يلتزم بذلك أمين التفليسة.

٦- إذا أفلس الساحب أصبحت الكمبيالة مستحقة الأداء حتى لو كان ميعاد الاستحقاق لم يحل بعد، لأن الإفلاس يؤدي إلى سقوط الاجل.

٦- إذا أفلس المسحوب عليه فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كان مقابل الوفاء ديناً نقدياً أم أنه لا يزال بضاعة أو أوراق تجارية أو أوراق مالية ولم يصبح بعد ديناً نقدياً، فإذا كان مقابل الوفاء ديناً نقدياً فإنه يختلط بذمة المسحوب عليه.

لا يتميز عن سائر أمواله، وبالتالي يتمتع على الحامل استرداده من التفليسة لأنه مجرد دائن عادي يتزاحم مع دائني المسحوب عليه المفلس ويخضع لقسمة غرماء، أما إذا كان مقابل الوفاء لا يزال بضاعة أو أوراق تجارية أو أوراق مالية فإنه لا تختلط بأموال المسحوب عليه المفلس ويحق للحامل استرداده من التفليسة إذا كان مخصصاً صراحة أو ضمناً لوفاء الكميالة.

س ٣٣: ما حكم التزام علي مقابل الوفاء ؟

الزام علي مقابل الوفاء:

سحبت عدة كميالات على المسحوب عليه ولم يكن مقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً، وجب تفضيل حامل الكميالة الأسبق في تاريخ السحب ثم الذي يليه وهكذا، والساحب لا يملك التصرف في مقابل الوفاء لحامل كميالة أخرى بعد إنشاء كميالة سابقة إلا في حدود ما يتبقى من دين مقابل الوفاء. إذا كانت إحدى الكميالات مقبولة فإنها تقدم على سائر الكميالات الأخرى ولو كانت هذه الكميالة لها تاريخ سحب لاحق لتاريخ سحب الكميالات الأخرى، ومن باب أولى إذا سحبت الكميالات في تاريخ واحد قدمت الكميالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.

تنص المادة (٣/٤٠٨) على أنه "إذا لم تحمل أية كميالة قبول المسحوب عليه قدمت الكميالة التي خصص لها مقابل الوفاء". تأتي في المرتبة الأخيرة الكميالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.

القبول

يلجأ الحامل إلى المسحوب عليه للتوقيع على الكميالة للتعهد بدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق، فإذا استجاب المسحوب عليه لذلك فهذا هو القبول مما لا شك فيه أن توقيع الساحب يجعل المظهرين والحامل مطمئنين إلى وجود مدين أصلي في الكميالة يتم الرجوع إليه، إلا أن الحامل يفضل إضافة ملتزم جديد للوفاء بقيمة الكميالة، ويعتبر قبول المسحوب عليه من الضمانات الجوهرية التي يتمتع بها الحامل. وبمجرد توقيع المسحوب عليه بالقبول يدخل في العلاقة المصرفية ويصبح ملتزماً بأحكام قانون الصرف.

س ٣٤: عرف القبول في الكميالة مبينا الحالات التي يلتزم والحالات التي يمتنع على الحامل تقديم الكميالة للقبول ؟

تعريف القبول وشروطه

تعريف القبول:

المقصود بالقبول : هو توقيع من المسحوب عليه على الكميالة يفيد تعهده بالوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق، ويعتبر القبول بمثابة إفصاح من المسحوب عليه عن رضائه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمة الكميالة عند حلول ميعاد الاستحقاق.

أولاً: الشروط الموضوعية:

١- الرضا:

يجب أن يصدر القبول عن رضا صحيح خالي من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه الذي لا يعدم الإرادة أو التدليس أو الاستغلال.

٢- **العقل:** محل التزام القابل المسحوب عليه هو مبلغ الكمبيالة.

٣- **السبب:** سبب التزام القابل هو غالباً مقابل الوفاء.

٤- الأهلية:

يجب أن يصدر القبول عن شخص يتمتع بأهلية الالتزام الصرفي، والأهلية المقصود هي أهلية القيام بالتصرفات التجارية، فلا يجوز لغيره وناقص الأهلية قبول الكمبيالة المسحوبة عليه، أما القاصر المأذون له بالأتجار لبلوغه من العمر ثمانية عشر سنة فيجوز له قبول الكمبيالة.

٥- القبول يجب أن يكون باتاً:

هذا شرط موضوعي خاص بالقبول، حيث يجب أن يكون القبول منجزاً وباتاً غير معلق على شرط اقف أو فاسخ. مما لا شك فيه أن الشرط يجعل التزام القابل معلقاً على واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع، كما أن القبول المعلق على شرط يعرقل تداول الكمبيالة، ولا يعتبر ضماناً جديدة للحامل، ويعتبر القبول المعلق على شرط في حكم عدم القبول، مما يعطي الحامل الحق في سقوط الأجل بعد عمل احتجاج عدم القبول والرجوع على الضامين ومطالبتهم أما بالوفاء بقيمة الكمبيالة أو تقديم كفيل موسر.

٦- القبول المؤجل:

ذهب رأي إلى أنه لا يجوز أن يقترن القبول بأجل يتجاوز ميعاد الاستحقاق لعدم جدوى القبول في هذه الحالة، ولا يجوز أن يكون القبول مؤجلاً لوقت غير معلوم - كوفاة شخص مثلاً - لا احتمال أن يكون هذا الأجل بعد ميعاد الاستحقاق.

٧- يشترط في القبول ألا يكون معدلاً لبيانات الكمبيالة:

يشترط في القبول ألا يكون معدلاً لبيانات الكمبيالة التي تحدد مضمون الالتزام الثابت بها، أو وصف من أوصافه، كتغير ميعاد الاستحقاق، أو التعهد بدفع قيمة الكمبيالة بضائع بدلاً من النقود.

قد أجاز المشرع للمسحوب عليه تعديل محل المختار لدفع قيمة الكمبيالة إذا كان الساحب قد قام بتحديد.

قد أجاز المشرع أيضاً القبول الجزئي لمبلغ الكمبيالة، رغم أن الأصل أن يشتمل القبول مبلغ الكمبيالة، إلا أن المشرع أجاز للمسحوب عليه أن يقصر قبوله على جزء من مبلغ الكمبيالة. ونص في المادة ١/٤١٤ على أنه "يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

في غير الحالات السابق ذكرها فإن كل تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول.

ثانياً: الشروط الشكلية:

١- يجب أن يكون القبول مكتوباً:

وهذا هو الحكم الساري في كل الالتزامات الصرفية، فقبول المسحوب عليه يجب أن يتم كتابة وعلى الكمبيالة نفسها، أما إذا كان القبول شفويًا فإنه لا يلزم إلا طرفيه فقط، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.

٢- البيانات التي يجب أن يتضمنها القبول:

- يجب أن يوضع على صيغة القبول توقيع المسحوب عليه أو إمضاه أو ختمه.
- يجب على المسحوب عليه أن يذكر تاريخ القبول إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها.

٣- أن يرد القبول على الكمبيالة ذاتها:

- يجب أن يرد القبول على الكمبيالة نفسها، تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية الذي يتطلب أن تكون بيانات الكمبيالة معبرة عن طبيعة الالتزام الصرفي ومضمونه ولا يعتمد في ذلك على وقائع خارجية.

تقديم الكمبيالة للقبول

أولاً: القبول حق اختياري للحامل:

- الأصل أن طلب القبول حق اختياري للحامل وليس إلزاماً عليه، فقد يكفي الحامل بتوقيع الساحب وتوقيع المظهرين.
- غير أن هذا الأصل ترد عليه استثناءات أخرى يكون فيها الحامل مجبراً وملزماً بأن يقدم الكمبيالة للقبول واستثناءات أخرى يمتنع فيها على الحامل تقديم الكمبيالة للقبول.

١- الحالات التي يلتزم فيها الحامل بتقديم الكمبيالة للقبول:

أ) إذا تضمنت الكمبيالة شرط التقدم للقبول:

- قد يشترط الساحب في الكمبيالة تقديمها للقبول، وذلك إذا أراد الاطمئنان على موقف المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق وقد يكون هذا الشرط مقترن بميعاد معين تقدم الكمبيالة فيه للقبول، كان يقول مثلاً "تقدم للقبول خلال شهر من تاريخه".
- بالإضافة إلى ذلك يعتبر الحامل مهماً ويسقط حقوقه وفقاً للشخص الذي يرجع عليه، فقد نص قانون التجارة في المادة ٣/٤٤٧ على أنه "إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده".

ب) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع:

- الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع يتعين تقديمها للمسحوب عليه للإطلاع عليها حتى يتحدد ميعاد الاستحقاق.

- الميعاد المقرر لتقديم هذه الكمبيالة للقبول هو سنة من تاريخ تحريرها، فقد نص قانون التجارة في المادة ٤١١ على أن "الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللصاحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد".

٢- الحالات التي يمتنع فيها على الحامل تقديم الكمبيالة للقبول:

أ) إذا تضمنت الكمبيالة شرط عدم القبول:

- هو شرط يضعه الساحب في الغالب دون المظهرين، لأنه ليس من مصلحة المظهرين وضع هذا الشرط، والساحب يضع هذا الشرط إما لأن مبلغ الكمبيالة قليل لا يتناسب مع مصاريف احتجاج عدم القبول وانتقال الحامل إلى المسحوب عليه، وإما لأن الساحب يرغب في الاحتفاظ بحق التصرف في مقابل الوفاء حتى يحين ميعاد مقابل الوفاء.

- إذا خالف الحامل هذا الشرط وقدم الكمبيالة للقبول إلى المسحوب عليه وقبلها فعلاً هذا الأخير رغم وجود هذا الشرط كان قبوله صحيحاً ولكن يتحمل المسحوب عليه مسؤوليته عن ذلك، حيث يحق للساحب رغم قبول المسحوب عليه التصرف في مقابل الوفاء حتى حلول ميعاد الاستحقاق لأن المسحوب عليه كان عليه أن يستجيب إلى أوامر الساحب في هذا الشأن.

🏠 اما اذا رفض المسحوب عليه القبول وهذا هو الغالب والطبيعى فى حالة تضمين الكمبيالة هذا الشرط فإنه لا يجوز للحامل اجراء احتجاج عدم القبول او الرجوع على الضامنين ولكن اذا قام الحامل بعمل هذا الاحتجاج كان للمسحوب عليه نتيجة التشهير به ، والساحب المظهرين الرجوع على الحامل بالتعويض للضرر .

ب) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع:

🏠 الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع، تقديمها للمسحوب عليه يعنى الوفاء بقيمتها والمطالبة بدفعها فوراً.

🏠 لذلك يمتنع على الحامل تقديم الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع للقبول، لأن هذه الكمبيالة إذا قدمت للمسحوب عليه فإنها تقدم للوفاء لا للقبول، فإذا رفض المسحوب عليه الكمبيالة فإنه يكون ممتنعاً عن الوفاء بقيمتها ويحق للحامل أن يعمل احتجاج عدم الوفاء والرجوع على الساحب والضامنين، وإلا كان حاملاً مهملاً.

ثانياً: القبول حق اختياري للمسحوب عليه:

🏠 الأصل أن القبول حق اختياري للمسحوب عليه، له حرية قبول الكمبيالة أو عدم قبولها.

رغم حرية المسحوب عليه في قبول الكمبيالة إلا أنه استقر على إلزامه بالقبول في حالتين:

🏠 **الحالة الأولى:** إذا كان هناك اتفاق سابق بين المسحوب عليه والساحب على قبول الكمبيالات التي تسحب عليه، وهذا الاتفاق يجري عادة بين أحد عملاء البنوك التي يفتح له البنك اعتماد وبين البنك. وأساس إلزام المسحوب عليه في هذه الحالة هو العقد بين الساحب والمسحوب عليه، فإذا أخل المسحوب عليه بهذا الاتفاق كان للساحب الرجوع عليه بالتعويض.

🏠 **الحالة الثانية:** إذا كان هناك عرف تجاري يلزم المسحوب عليه بقبول الكمبيالة، ويكون عادة هذا العرف متواجداً إذا كان كل من الساحب والمسحوب عليه تاجراً وكانت العلاقة بينهما تجارية أو ارتبطت الكمبيالة بهذه العلاقة حيث يستطيع التاجر سحب كمبيالة على مدينة التاجر لتحصيل هذا الدين التجاري، ويكون المسحوب عليه مسؤولاً عن التعويض إذا رفض القبول وسبب ذلك ضرراً للساحب.

ثالثاً: إجراءات تقديم الكمبيالة للقبول:

١- من له التقدم بطلب القبول:

🏠 يجوز التقدم بطلب قبول الكمبيالة من الحامل أو نائبه كما يجوز تقديمها من كل حائز لها.

٢- ممن يصدر القبول:

🏠 يصدر القبول من المسحوب عليه أو وكيله، وإذا توفى المسحوب عليه أو القابل الاحتياطي جاز أن يصدر القبول من الورثة.

٣- وقت تقديم الكمبيالة للقبول:

🏠 للحامل أو الحائز تقديم الكمبيالة للقبول في أي وقت بين إنشائها وتاريخ الاستحقاق، ولكن إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع فإنه يجب على الحامل تقديمها خلال سنة من تاريخها والا سقط حقه في الرجوع على الضامنين.

آثار القبول

أولاً: العلاقة بين المسحوب عليه والحامل:

🏠 بمجرد قبول المسحوب عليه الكمبيالة يصبح مسؤولاً قبل الحامل مسؤولية صرفية عن أداء قيمتها، ويصير هو المدين الأصلي بها، وبالتالي يكون أول المطالب بقيمتها، فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء رغم قبوله الكمبيالة كان للحامل عمل احتجاج عدم الوفاء ثم الرجوع على الموقعين على الكمبيالة بالدعوى للمطالبة بقيمتها حسب أحكام قانون الصرف.

ينشئ عن القبول علاقة مباشرة بين الحامل والمسحوب عليه، وهي علاقة مستقلة عن علاقة المسحوب عليه بالساحب، لذلك لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك بالدفع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة الساحب في مواجهة الحامل حسن النية.

ثانياً: في العلاقة بين الحامل وبين الساحب والمظهرين:

ساحب الكمبيالة والمظهرين لها يسألون بالتضامن عن قبول الكمبيالة من المسحوب عليه. لذلك تبرأ بالقبول التزام الساحب والمظهرين من ضمان القبول وبالتالي لا يحق للحامل الرجوع عليهم قبل حلول ميعاد الاستحقاق.

إذا أفلس المسحوب عليه بعد القبول وقبل حلول ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الكمبيالة أن يرجع على الساحب والمظهرين بعد عمل الاحتجاج لأن إفلاس المسحوب عليه يجعل قبوله كأن لم يكن.

ثالثاً: في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه:

يعتبر قبول المسحوب عليه قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه، غير أن هذه القرينة بسيطة في علاقة الساحب والمسحوب عليه، حيث يجوز للمسحوب عليه رغم قبوله الكمبيالة إثبات أنه لم يتلق مقابل الوفاء.

آثار الامتناع عن القبول

قد يمتنع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة، أما لأنه غير مدين للساحب وبالتالي لا يوجد لديه مقابل الوفاء، أو أن الساحب وعده بتقديم الوفاء ولم يفعل.

غير أنه إذا رفض المسحوب عليه القبول بدون أسباب حقيقية قائمة كأن للساحب الرجوع عليه بالتعويض إذا تسبب ذلك في ضرر، وغالباً يحدث هذا الضرر إذا كان الساحب تاجراً ويعتمد على اسمه وسمعته.

في ذلك تنص المادة ٢/٤٣٨ من قانون التجارة على أن يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:

الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول وأضفت المادة ١/٤٣٩ على أن "يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وقائها باحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء".

احتجاج عدم القبول:

حتى يتمكن الحامل من الرجوع على الموقعين في حالة رفض القبول، يجب عليه إثبات هذا الرفض أو هذا الامتناع في ورقة رسمية تسمى باحتجاج عدم القبول.

احتجاج عدم القبول ورقة من أوراق المحضرين يثبت فيها المحضر امتناع المسحوب عليه عن القبول والهدف من إثبات الاحتجاج في ورقة من أوراق المحضرين هو قطع كل شك أو أي منازعة حول هذا الامتناع.

الرجوع على الموقعين قبل ميعاد الاستحقاق:

بمجرد قيام الحامل بعمل احتجاج عدم القبول يجوز له الرجوع على الساحب أو المظهرين بعد إعلانهم بالاحتجاج، حيث يحق للحامل مطالبتهم دفعة واحدة، أما إذا أراد الحامل الرجوع على الساحب فقط أو أحد المظهرين فعليه القيام بإعلانه فقط.

يجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق - في حالة إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد، وأيضا حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول، أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عريضة يطلب منحة مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضي مبرراً لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون هذا الأمر نهائياً.

القبول بالتدخل

ماهية القبول بالتدخل:

📌 **القبول بالتدخل:** هو تدخل شخص ليقبل الكمبيالة لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.

شروط القبول بالتدخل:

١- **يجوز أن يتم القبول بالتدخل من أحد المتلتزمين بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل، كما يحق للغير قبول الكمبيالة بالتدخل لصالح أحد الموقعين عليها:**

📌 أجاز المشرع قبول الكمبيالة بالتدخل من أي شخص ملتزم بالكمبيالة حيث يجوز ذلك من قبل الساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي، وبطبيعة الحال لا يجوز أن يكون المتدخل هو المسحوب عليه القابل، لأنه بالفعل قد قبل الكمبيالة وأصبح هو المدين الأصلي بها.

٢- **أن يكون القبول بالتدخل عن شخص ملتزم بضمان الكمبيالة:**

📌 يشترط أن يكون القابل بالتدخل قد تدخل عن شخص ملتزم أصلاً في الكمبيالة مثل الساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي، ولا يجوز أن يقع القبول بالتدخل عن المسحوب عليه الممتنع عن القبول، لأنه برفض القبول يظل غير ملتزم بالكمبيالة، فهو بعيدا عن الالتزام الصرفي طالما لم يوقع بالقبول.

٣- **لا يجوز القبول بالتدخل إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو متضمنة شرط عدم القبول:**

📌 القبول بالتدخل يجوز في جميع الحالات التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، وبالتالي لا يجوز القبول بالتدخل في الكمبيالة غير حائزة القبول وهي الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو المتضمنة شرط عدم القبول.

٤- **أن يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها ويوقعه المتدخل:**

📌 يجب ذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها، ويتم بالتوقيع على صك الكمبيالة من المتدخل.

٥- **إعلان القابل بالتدخل تدخله لمن توسط عنه:**

📌 يلزم المشرع التجاري القابل بالتدخل بإخطار من وقع لصالحه خلال يومي العمل التاليين لتوقيع قبول التدخل.

٦- **رجوع الحامل أولاً على من عين في الكمبيالة ليقبلها قبل الرجوع على من صدر عنه هذا التعيين أو الموقعين اللاحقين له:**

📌 إذا عين في الكمبيالة من يقبلها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين - سواء كان الساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي - ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.

أنشأ القبول بالتدخل:

١- **في علاقة القابل بالتدخل بالحامل:**

📌 يلتزم القابل بالتدخل تجاه الحامل بنفس التزامات من تدخل لمصلحته.

٢- **في علاقة القابل بالتدخل والشخص الذي تدخل لمصلحته:**

📌 إذا قام القابل بالتدخل بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد الاستحقاق كان له حق الرجوع بدعوى الصرف على المتلتزم الذي تدخل لمصلحته وعلى ضامني هذا الأخير أي الموقعين السابقين عليه دون الموقعين اللاحقين له.

٣- **في علاقة الحامل والمتلتزمين في الكمبيالة:**

📌 يحق للحامل رفض القبول بالتدخل - أما إذا قبل القبول بالتدخل فإنه يفقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.

تضامن الموقعين بالوفاء بقيمة الكمبيالة

📌 يلتزم الساحب بمجرد تحرير الكمبيالة بضمان الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق للمستفيد الأول ولكل مظهر يليه وللحامل الأخير، والمسحوب عليه القابل يلتزم أيضاً بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وكل مظهر يلتزم بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة للمظهر إليه المباشر وكل حامل للكمبيالة يليه، وكلما زاد عدد المظهرين الموقعين على الكمبيالة كلما زاد عدد الضامنين للوفاء بقيمتها.

📌 في ذلك تنص المادة (١/٤٤٢) من قانون التجارة على أن "الأشخاص المتلتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها".

س ٣٥: اشرح خصائص التضامن الصرفي ؟

خصائص التضامن الصرفي:

يشارك التضامن الصرفي مع التضامن المدني في أسس معينة، ويختلف معه في أسس أخرى:
أولاً: يشترك التضامن الصرفي مع التضامن المدني في الأسس الآتية:

١- وحدة الدين:

يقوم التضامن المدني على مبدأ وحدة الدين وهذا مستفاد من المادة ٢١٥ مدني والمقصود به عدم قابلية الدين للانقسام في علاقة المدينين بالدائن حيث يحق للدائن الرجوع على المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين، أو يطالب أحدهما منفرداً بكل الدين، ومما لا شك فيه أن التضامن الصرفي يقوم على هذا المبدأ أيضاً فمن حق الحامل مطالبة كل الملتزمين بالكميالة، ومن حقه أن يطالب أحداً منهم بكل قيمة الكميالة.

٢- تعدد الروابط القانونية:

يقوم التضامن المدني على مبدأ تعدد الروابط القانونية، بمعنى أنه على الرغم من وحدة الدين إلا أن كل مدين يلتزم بشكل مستقل كأن لم يكن هناك مدين غيره، أي أن المدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة عن الروابط الأخرى، ومما لا شك فيه أن التضامن الصرفي يقوم على هذا المبدأ حيث أن هناك روابط متعددة تجمع الحامل بكل موقع على الكميالة تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقعيات.

٣- النيابة التبادلية:

يقوم التضامن المدني على فكرة النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر وعبرت عن ذلك المادة ٢/٢٩٢ مدني، أي أنه إذا قام أحد الموقعين بأي عمل يعود بالنفع على المدينين الآخرين فإنهم يستفيدون منه، أما إذا كان هناك عمل يضرهم فلا يلتزم به غير من قام به، ولا يسري في حق الآخرين، وبالتالي إذا انقطعت مدة التقادم أو وقفت بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين أو إذا صدر حكم عليه فلا يضر من ذلك باقي المدينين ولا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين، لأن قطع تقدم الدين أو وقفه أو صدور حكم على أحدهما يضرهم بلا شك، فلا يسري عليه، ومما لا شك فيه أن هذه القاعدة تسري على الالتزام الصرفي أي تسري على الموقعين على الكميالة.

ثانياً: يختلف التضامن الصرفي عن التضامن المدني في الأسس الآتية:

- ١- الدائن وفقاً لأحكام القانون المدني (المادة ٢٨٥) حر في اختيار المدين المتضامن الذي يبدأ بمطالبته دون أن يكون مقيداً بأن يبدأ بمطالبة مديناً معيناً، أما قانون الصرف فإنه يفرض على الحامل الرجوع أولاً على المسحوب عليه وإثبات امتناعه باحتجاج عدم الوفاء ثم بعد ذلك يرجع على الموقعين على الكميالة دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
- ٢- وفقاً لأحكام القانون المدني (مادة ٢٩٧)، أنه إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقيين إلا بقدر حصته في الدين، أما قانون الصرف فقد أعطى للملتزم الذي أوفى بقيمة الكميالة للحامل الحق في الرجوع على الملتزمين بكل الدين، وذلك لأن كل موقع على الكميالة مضمون من الموقع السابق عليه وضامن للموقع اللاحق له.

المركز القانوني للملتزمين في التضامن الصرفي:

- ١- لا صعوبة فيما يتعلق بمركز الضامن الاحتياطي أو القابل بالتدخل، حيث أن الرأي مستقر على اعتبارهم كفلاء متضامنين مع من تدخلوا لمصلحتهم.
- ٢- أما المسحوب عليه فإنه لا صعوبة بالنسبة له أيضاً حيث أنه قبل القبول يعتبر أجنبياً عن الكميالة وعن الالتزام الصرفي، أما بعد القبول فإنه يصير ملزماً بوفاء قيمة الكميالة في ميعاد الاستحقاق وفي حالة عدم وفاؤه يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكميالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب أحكام قانون الصرف.
- ٣- أما الساحب قبل القبول فإنه يعتبر المدين الأصلي في الكميالة، أما بعد القبول فقد اختلفت الآراء.

والراجع أن الساحب بعد قبول المسحوب عليه يعتبر كفيلاً متضامناً ولكن بدرجة أشد من المظهرين. ٤- أما مركز المظهرين فإنهم لا يعتبرون كفلاء متضامنين للمسحوب عليه القابل أو الساحب قبل القبول. لذلك فإن مركز المظهرين يعتبر مركزاً قانونياً خاصاً خاضعاً لأحكام قانون الصرف لذلك يمكن أم نقول عليهم بأنهم كفلاء صرفيين.

الضمان الاحتياطي ماهية الضمان الاحتياطي:

يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة الكمبيالة، فقد يقدم أحد الملتزمين بالكمبيالة كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمتها. وعلى ذلك يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة لالتزام ثابت في الكمبيالة يقدمها شخص يضمن بمقتضاها دفع مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه.

شروط الضمان الاحتياطي:

أولاً: الشروط الموضوعية:

١- الملتزمون الذين يجوز ضمانهم احتياطياً:

يجوز أن يكون الضمان الاحتياطي عن أي ملتزم بالكمبيالة كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه القابل أو ضامن احتياطي آخر. ويعتبر الضامن الاحتياطي في مركز المضمون. لذلك يجب أن يحدد الضامن الاحتياطي شخص من يضمنه على وجه الدقة.

س ٣٦: الضمان الاحتياطي الصادر ممن وقعوا الكمبيالة ضمانه جديدة للحامل ؟

٢- شخص الضامن الاحتياطي:

يشترط فيمن يتدخل كضامن احتياطي أن يكون أهلاً للالتزام الصرفي. والضمان الاحتياطي جائز من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة. وقد اعتبر المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الضمان الاحتياطي الصادر ممن وقعوا الكمبيالة ضماناً جديدة للحامل.

ثانياً: الشروط الشكلية:

الضمان الاحتياطي يجب أن يتم كتابة على ذات الكمبيالة أو وصلة متصلة بها.

آثار الضمان الاحتياطي:

س ٣٧: وضع العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزم المضمون ؟

١- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزم المضمون:

- للضامن الاحتياطي ذات الحقوق المقررة للملتزم المضمون وعليه التزاماته، وإذا أو في الضامن الاحتياطي بقيمة الكمبيالة كان من حقه الرجوع على المضمون بإحدى دعويين، أما بالدعوى الشخصية الناشئة عن الكفالة، وإما بدعوى الحلول وهي دعوى صرفية يحل فيها الضامن الاحتياطي محل الحامل الذي تلقى منه قيمة الكمبيالة.
- من المفروض أن يكون التزام الضامن الاحتياطي التزاماً تابعاً لالتزام المضمون في الصحة والبطان، فإن التزام الضامن الاحتياطي يكون صحيحاً ولو كان التزام المضمون باطلاً لنقص أهليته أو انعدام إرادته أو غير ذلك ما عدا البطان لعيب في الشكل تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات.

٢- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والحامل:

- أ- لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يحتج على الحامل إلا بالدفع التي يجوز للمضون توجيهها إليه.
- ب- الضامن الاحتياطي للمظهر يستطيع أن يتمسك بإهمال الحامل إذا لم يخطر، بالاحتجاج شخصياً، حتى ولو كان قد أخطر المظهر المضمون.
- ج- لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يتمسك في مواجهة الحامل بالدفع بالتجريد.

٣- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والمتزمين الآخرين:

- 📌 إذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الكمبيالة للحامل، كان له الرجوع على الموقعين على الكمبيالة على النحو التالي:
- 📌 إذا كان ضامناً للساحب فلا رجوع للضامن الاحتياطي إلا على الساحب أو المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.
- 📌 إذا كان ضامناً لأحد المظهرين كان له الرجوع على هذا المظهر وغيره من المظهرين السابقين الضامين لهذا المظهر دون المظهرين اللاحقين، ويرجع على الساحب والمسحوب عليه القابل.
- 📌 إذا كان ضامناً للمسحوب عليه القابل فليس له الرجوع الرجوع إلا على الساحب في حالة عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.

الوفاء بالكمبيالة

أحكام الوفاء بالكمبيالة

ميعاد الاستحقاق ومدة التقدم للوفاء

- 📌 **ميعاد الاستحقاق:** هو الميعاد الذي يستحق فيه الوفاء بقيمة الكمبيالة وهو من البيانات الإلزامية التي يجب ذكرها في الكمبيالة وإلا أصبحت مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع.

١- استحقاق الكمبيالة بمجرد الإطلاع:

- 📌 والكمبيالة المستحقة الدفع لدى الإطلاع هي التي تكون واجبة الدفع بمجرد تقديمها للمسحوب عليه، وهي لا تقدم للوفاء مباشرة.
- 📌 ومما لا شك أن تعيين تاريخ الاستحقاق بمجرد الإطلاع يقتضي تدخل من الحامل، لأنه هو الذي يختار الوقت الذي يتقدم فيه للمسحوب عليه، ولكن الحامل قد يترأخي لأجل قد يضر بالساحب أو المسحوب أو المسحوب عليه أو المظهرين، لذلك لم يترك المشرع حرية الحامل في هذا الغرض مطلقة وإنما قيدها بمدة معينة يجب على الحامل أن يقدم الكمبيالة خلالها للمسحوب عليه وإلا سقط حقه في الرجوع على الضامين، هذه المدة هي سنة من تاريخ إصدار الكمبيالة.

٢- استحقاق الكمبيالة بعد مدة معينة من الإطلاع:

- 📌 قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع، كأن يقال مثلاً: ادفعوا بعد عشرة أيام من الإطلاع" أو "ادفعوا بعد عشرين يوماً من التقديم".
- 📌 ويجب على الساحب تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المسحوب عليه لقبولها خلال سنة من تاريخها، وإلا أصبح حاملاً مهماً وسقط حقه في الرجوع على الضامين.

٣- استحقاق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها:

- 📌 في هذه الحالة يتحدد تاريخ استحقاق الكمبيالة على وجه الدقة بدون حاجة إلى تدخل من الحامل لتحديد ذلك، فمثلاً يقال "ادفعوا بعد عشرة أيام من تاريخه".

٤- استحقاق الكمبيالة في تاريخ معين:

- 📌 قد يكون ميعاد استحقاق الكمبيالة محددًا في تاريخ معين، وهذه هي الطريقة المعتادة في تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة والشائعة.

الاستحقاق في يوم عطلة رسمية:

إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالي ولا يجوز القيام بأي إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل.

التأجيل القانوني لميعاد الاستحقاق:

قد يضطر المشرع في حالة الحرب أو الأزمات الاقتصادية التدخل لإصدار قانون يؤجل دفع قيمة الديون، وذلك مراعاة للمدنيين من التشهير بهم نتيجة عدم الوفاء وعمل الاحتجاج في هذه الظروف، وقد يتم شهر إفلاسهم.

الوفاء

أولاً: تقديم الكمبيالة للوفاء:

إذا حل ميعاد الاستحقاق يجب على حامل تقديم الكمبيالة للوفاء بقيمتها إلى المسحوب عليه ولا يسعى هذا الأخير غالباً إلى الحامل لكي يوفى بقيمة الدين، لأنه غالباً لا يعرف في أي يد تستقر الكمبيالة عند ميعاد الاستحقاق.

ثانياً: مكان الوفاء:

يجب على الحامل أن يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه في مكان الوفاء المعين بها. حيث أنه من البيانات الإلزامية، فإذا لم يذكر بيان مكان الوفاء فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان الكمبيالة وإنما اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في نفس الوقت وعلى الحامل أن يتقدم إلى هذا المكان للوفاء بقيمة الكمبيالة.

ثالثاً: زمن الوفاء:

على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم، والكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها.

رابعاً: موضوع الوفاء:

موضوع الوفاء هو المبلغ النقدي الموضح بالكمبيالة، لذلك يجب أن يرد الوفاء على نوع النقود الموضحة بالكمبيالة، ويلزم المسحوب عليه بدفع المبلغ المحدد بالكمبيالة دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر وذلك تطبيقاً للقواعد العامة.

خامساً: شروط صحة الوفاء:

١- يجب أن يفع الوفاء في ميعاد الاستحقاق:

لا يكون الوفاء صحيحاً إلا إذا تم في ميعاد الاستحقاق، لأن هذا الميعاد وضع لمصلحة كلا من الساحب والمسحوب عليه والحامل والمظهرين نظراً للدور الهام الذي تقوم به الكمبيالة كأداة ائتمان.

٢- الوفاء للحامل الشرعي للكمبيالة:

قرر قانون التجارة أن وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبيري ذمة الموفى ويعتبر وفاء صحيحاً، لأن المدين ليس لديه متسع من الوقت عند حلول ميعاد الاستحقاق للقيام بالتحريات اللازمة والتحقق من صفة من يطلب الوفاء ومن أهليته حتى لا يتم تحرير الاحتجاج في مواجهته.

٣- يجب أن يتم الوفاء بدون غش أو خطأ جسيم:

🏠 إذا دفع المسحوب عليه إلى حامل يعلم أنه ليس مالكا للكمبيالة - لأنه عثر عليها أو سرفها - وأضر ذلك بالمالك الحقيقي، فإن المسحوب عليه يكون بذلك قد ارتكب غشا ويتعرض لدفع قيمة الكمبيالة مرة ثانية على سبيل التعويض.

٤- أن يتم الوفاء دون معارضة صحيحة:

🏠 "لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجز عليه". فإذا جاءت المعارض بناء على إحدى هذه الحالات فإنه لا يجوز للمدين الوفاء بقيمة الكمبيالة وإلا كان مسئولا عن ذلك.

سادساً: آثار الوفاء:

🏠 بمجرد قيام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة برئت ذمة جميع الموقعين عليه، وينقضي التزام الموقعين بضمان الوفاء وتنتهي حياة الكمبيالة.

سابعاً: إثبات الوفاء:

🏠 إثبات الوفاء يتم بتسليم الكمبيالة إلى المسحوب عليه الموفى بعد التوقيع عليها بما يفيد الوفاء.

ثامناً: المطعنة في الوفاء:

🏠 "لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجز عليه"، لذلك يمتنع على دائن الحامل أن يحجز تحت يد المسحوب عليه عن مبالغ مستحقة للحامل، لأن حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر معارضة في الوفاء منعها المشرع التجاري إلا في حالة ضياع الكمبيالة وإفلاس الحامل أو الحجز عليه.

س ٣٨: ماهو حكم افلاس الحامل للكمبيالة ؟

الحالة الأولى: إفلاس الحامل أو الحجز عليه:

أ) إفلاس الحامل:

🏠 يترتب على إفلاس الحامل غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها، فيمتنع عليه استيفاء حقوقه، ويحل أمين التفليسة محل المدين المفلس في إدارة أموال المفلس وتحصيل حقوقه لدى الغير والتصرف في الأموال أيضاً.

ب) الحجز على الحامل:

🏠 يأخذ حكم إفلاس الحامل صدور قرار بالحجز عليه سواء في حالة نقص الأهلية أو إنعدامها.

س ٣٩: ماهو حكم ضياع الكمبيالة ؟

الحالة الثانية: ضياع الكمبيالة:

🏠 من المتفق عليه أن ضياع الكمبيالة يعني فقدانها أو سرقتها أو هلاكها أو تلفها أو أي حالة يفقد فيها الحامل صك الكمبيالة دون إرادته.

🏠 نفرق في ذلك بين علاقة مالك الكمبيالة الحقيقي والحامل الجديد وعلاقة مالك الكمبيالة الحقيقي والمسحوب عليه.

١- علاقة مالك الكمبيالة بالحائز لها:

إذا تعرف مالك الكمبيالة الحقيقي على حائزها الذي سرقها أو عثر عليها أو انتقلت إليه من هؤلاء - كان له حق استردادها، ولم ينظم المشرع التجاري كيفية الاسترداد لذلك نعود للقواعد العامة. في هذه الحالة نفرق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية فإذا كان الحائز سئ النية بأن عثر عليها أو سرقها أو انتقلت إليه وهو يعلم بضياعها أو سرقها، كان من حق مالك الكمبيالة الحقيقي استردادها، أما إذا كان الحائز حسن النية فإن أغلب الفقه يفضل مصلحة الحائز حسن النية عن المالك الشرعي للكمبيالة حماية لاستقرار التعامل بالأوراق التجارية ولأن الكمبيالة تتداول بالتظهير حتى ولو لم تتضمن شرط الأمر في ظل أحكام القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

٢- علاقة مالك الكمبيالة بالمسحوب عليه:

في هذه العلاقة نظم المشرع التجاري إجراءات حصول المالك على حقه وذلك على النحو التالي:

(أ) إذا كانت الكمبيالة محررة من نسخة واحدة:

إذا كانت الكمبيالة محررة من نسخة واحدة وتم فقدانها، يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، "ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص وبشرط تقديم كفيل"، "وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة". ويجوز لمن ضاعت منه كمبيالة ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمراً من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيتها لها وأن يقدم كفيلًا.

(ب) إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ:

أحيانا تحرر كمبيالة من عدة نسخ تفاديا لمخاطر الضياع أو السرقة أو التلف في هذه الحالة يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ الأخرى التي حررت من أجلها وإلا اعتبرت كل نسخة قائمة بذاتها، كما أن الوفاء بمتقضى إحدى نسخها مبرر للذمة. إذا صدرت الكمبيالة من عدة نسخ وضاعت إحداها، فيجب هنا التمييز بين ما إذا كانت الكمبيالة الضائعة تحمل قبول المسحوب عليه أم أنها لا تحمل قبوله. إذا كانت النسخة الضائعة تحمل صيغة قبول المسحوب عليه فإنه يمتنع عليه الوفاء لأي نسخة أخرى، لأن المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمتقضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها. أما إذا كانت النسخة المفقودة لا تحمل قبول المسحوب عليه وكان مع المالك نسخة أخرى جاز له أن يطالب المسحوب عليه بالوفاء بقيمتها.

الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة

إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة فإن المشرع نظم إجراءات معينة على الحامل اتباعها للمحافظة على حقوقه وإمكان الرجوع على الموقعين الذين يضمنون هذا الوفاء على وجه التضامن وإلا أصبح حاملا مهما لا يحق له الرجوع إلا على المدين الأصلي في الكمبيالة، لذلك أمر المشرع الحامل بإثبات الامتناع عن الوفاء في ورقة رسمية تسمى "احتياج عدم الوفاء"، ثم إخطار هذه الورقة إلى الملتزمين الذين يريد مطالبتهم ثم إقامة الدعوى عليهم، كل ذلك وفقا لمواعيد محددة.

س ٤٠ / اشرح بالتفصيل احتياج عدم الوفاء ؟

احتياج عدم الوفاء

تعريف احتياج عدم الوفاء وفائدته:

احتياج عدم الوفاء هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يثبت فيها امتناع المسحوب عليه في الكمبيالة عن الدفع في ميعاد الاستحقاق.

ضرورة تحرير احتجاج عدم الوفاء:

📌 تحرير احتجاج عدم الوفاء إجراء لابد منه إذا أراد الحامل الرجوع على الموقعين على الكمبيالة في حالة عدم الوفاء، وهو أول إجراءات الرجوع.

📌 تحرير احتجاج عدم الوفاء شرط للرجوع على المظهرين وضمائمهم الاحتياطين ولكنه ليس شرطاً للرجوع على المدين الأصلي في الكمبيالة.

ميعاد تحرير احتجاج عدم الوفاء:

يستخلص من نص المادة ٣٩٤/٢، ٣ الأحكام الآتية:

- ١- حدد المشرع مدة عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها.
- ٢- إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع فإنه يجب عمل احتجاج عدم الوفاء خلال المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول.
- ٣- لا يجوز عمل احتجاج عدم الوفاء في يوم الاستحقاق ذاته، لأن هذا اليوم متروك للمدين لتدبير حالة ويعتبر الاحتجاج المعمول في يوم الاستحقاق باطلاً.
- ٤- لا يجوز عمل احتجاج عدم الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق وإلا كان باطلاً.
- ٥- لا يجوز القيام بعمل احتجاج عدم الوفاء إلا في يوم عمل.
- ٦- إذا حالت قوة القاهرة دون عمل احتجاج عدم الوفاء في الميعاد القانوني امتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة.

مكان عمل الاحتجاج:

📌 يعمل احتجاج عدم الوفاء في محل من كان عليه دفع قيمة الكمبيالة ومن تعهد بدفع قيمتها عند الاقتضاء.

📌 وإذا تضمنت الكمبيالة شرط الوفاء في محل مختار تعين تحرير احتجاج عدم الوفاء في هذا المحل.

شكل الاحتجاج وإجراءات تحريره:

📌 الاحتجاج ورقة من أوراق المحضرين، لذلك يجب أن يتبع في شأنه الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين.

وعلى ذلك يجب أن يشتمل الاحتجاج على ما يلي:

- ١- البيانات اللازمة لأوراق المحضرين.
- ٢- صورة حرفية للكمبيالة وكل ما ورد بها خاص بقبولها وتظهيرها وضمائمها احتياطياً.
- ٣- التنبيه الرسمي على المدين بقبول الورقة.
- ٤- إثبات حضور أو غياب المدين وقت عمل الاحتجاج.
- ٥- أسباب امتناع المدين عن الدفع.
- ٦- إمضاء المدين أو ختمه.
- ٧- بيان ما دفع من قيمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي.
- ٨- تسلم صورة من الاحتجاج للمدين.

قيد الاحتجاج وشهره:

📌 على المحضرين قيد أوراق الاحتجاج بتامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

📌 على فلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررها الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

بطان احتجاج عدم الوفاء.

📌 الاحتجاج ورقة من أوراق المحضرين لذلك يبطل بكل ما تبطل به هذه الأوراق.
📌 على ذلك يعتبر الاحتجاج باطلا إذا شابه عيب جوهري ووقع ضرر لطالب البطان ، أو كان ناقصا لأحد البيانات اللازمة مما يترتب عليه عدم أداء الاحتجاج للغرض منه مثل بيان التنبيه على المدين بالوفاء وبيان إثبات امتناعه عن الدفع.

آثار احتجاج عدم الوفاء:

- ١- إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق وبالتالي لا يسقط حق الحامل في الرجوع على الموقعين على الكمبيالة ولا يعتبر حاملا مهما.
- ٢- تتقدم دعاوي الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني.

شروط الرجوع بلا مصاريف وآثره على الاحتجاج:

📌 يجوز إضافة شرط الرجوع بلا مصاريف إلى الكمبيالة وفي هذه الحالة يعفى الحامل من تحرير الاحتجاج دون أن يترتب على ذلك سقوط حقه في الرجوع على الضامنين ودون أن يعتبر حاملا مهما.

الرجوع بالكمبيالة

أولاً: رجوع الحامل على الملتزمين الضامنين للوفاء بقيمة الكمبيالة:

📌 لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها، ولا يحق للحامل التوجه إلى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق لاستيفاء قيمة الكمبيالة، وبالتالي لا يحق الحامل الرجوع على الملتزمين قبل ميعاد الاستحقاق كقاعدة عامة، ولكن استثناء من ذلك أجاز المشرع للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في حالات معينة.

س ١٤ : اذكر حالات رجوع الحامل على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين قبل ميعاد الاستحقاق ؟

حالات رجوع الحامل على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين قبل ميعاد الاستحقاق.

الحالة الأولى : الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول :

📌 امتناع المسحوب عليه عن القبول الكلي للكمبيالة في الحالات التي يتمتع فيها الحامل بحرية تقديم الكمبيالة للقبول وتقدم بها فعلا للقبول للتأكد من وفاء المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق وأيضا الحالات التي يجب على الحامل عرض الكمبيالة للقبول، وإنما يدل على نية المسحوب عليه في عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة، وكذلك قيام المسحوب عليه بالقبول الجزئي إنما يدل على عدم رغبته في دفع الجزء الباقي من مبلغ الكمبيالة.

الحالة الثانية: إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان أو غير قابل للكمبيالة، أو توقفه عن دفع ديونه أو حجز على أمواله :

مما لا شك فيه أن الحكم بشهر إفلاس المسحوب عليه يترتب عليه أن تغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وبالتالي لن يستطيع الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق. لذلك أعطى المشرع للحامل الحق في الرجوع على الملتزمين الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق حتى لا يتعرض لقسمة الغرماء مع باقي دائني المسحوب عليه، كذلك توقف المسحوب عليه من دفع ديونه يعرض الحامل لخطر عدم وفاء المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ويأخذ نفس الحكم توقيع حجزاً على أموال المسحوب عليه .

الحالة الثالثة: إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول :

اشتراط الساحب عدم تقديم الكمبيالة للقبول تجعله هو المدين الأصيل في الكمبيالة، وهذه الكمبيالة لا تمثل أي ضمانات للحامل في مواجهة المسحوب عليه، وبالتالي فإن إفلاس الساحب قبل ميعاد استحقاق هذه الكمبيالة يعرض الحامل للخطر ويضعف ضماناته، لذلك أعطى له الحق في الرجوع على الملتزمين الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق.

حق الحامل في الرجوع على الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون اتباع ترتيب معين:

قرر المشرع أن الملتزمين بالكمبيالة مسئولين بالتضامن قبل حاملها كما أعطى للحامل حرية الرجوع على الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون اتباع ترتيب معين.

طريقة الرجوع:

رجوع الحامل على الموقعين على الكمبيالة يكون إما من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة طبقاً لأحكام القانون التجاري، أو من خلال نظام أوامر الاداء الذي أخذ به في قانون المرافعات المصري.

رجوع الحامل على باقي الملتزمين أو على جميع الملتزمين:

إذا تقدم الحامل لاستيفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، ولم يتمكن من ذلك وأراد الرجوع على الموقعين على الكمبيالة، أو أراد الجمع بين الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو المسحوب عليه القابل وأحد المظهرين الموقعين على الكمبيالة فعليه اتباع الآتي:

- أ) تحرير احتجاج عدم الوفاء في المواعيد التي نص عليها قانون الصرف.
- ب) إخطار الاحتجاج إلى من أراد الرجوع عليه خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء.
- ت) تكاليف الملتزم بالحضور أمام المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً.

موضوع الرجوع:

- أصل قيمة الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه، ويقصد بأصل قيمة الكمبيالة مبلغ الكمبيالة المحدد على وجه الدقة أو القابل للتحديد والموجود بصلب الكمبيالة، ويقصد بالعائد المتفق عليه بالفوائد الاتفاقية المشروطة والتي لا تدمج بأصل المبلغ.
- العائد المستحق على الكمبيالة (الفوائد التأجيرية أو القانونية) محسوباً وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق.
- مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة ورسوم الدعوى أو أمر الأداء وغيرها.
- وإذا كان الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق وجب أن يستنزل من موضوع الرجوع - ما يساوي سعر الخصم الرسمي من تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

ثانياً: رجوع من قام بالوفاء على الملتزمين الضامنين له:

إذا رجع الحامل على أحد الملتزمين بقيمة الكمبيالة وقام بالوفاء له، كان لهذا الأخير حق الرجوع على الموقعين الضامنين له وهم الموقعين السابقين عليه، وإذا أوفى من رجع عليه هذا الملتزم كان له هو أيضاً بدوره الرجوع على الموقعين السابقين عليه الضامنين.

مما لا شك فيه أن حق الرجوع يختلف نطاقه بحسب مركز من قام بالوفاء بقيمة الكمبيالة، وذلك وفق ما يلي:

رجوع الساحب:

إذا تم الرجوع على الساحب ولم يكن قد قدم مقابل إلى المسحوب عليه وقام بالوفاء بقيمة الكمبيالة فإنه لا يحق له الرجوع على أحد لأنه هو المدين الأصلي بها، والوفاء الحاصل من الساحب يبرئ جميع الملتزمين الموقعين على الكمبيالة قبل الحامل وقبل بعضهم على بعض.

رجوع المسحوب عليه:

إذا تم الرجوع على المسحوب عليه القابل الذي تلقى مقابل الوفاء وقام بالوفاء بقيمة الكمبيالة، فإنه لا يحق له الرجوع بعد ذلك على أحد لأنه هو المدين الأصلي بقيمة الكمبيالة بقبوله وحصوله على مقابل الوفاء، أما إذا قام المسحوب عليه بالوفاء، رغم عدم حصوله على مقابل الوفاء، كان له الحق في الرجوع على الساحب فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة.

رجوع المظهر:

إذا اختار الحامل الرجوع على أحد المظهرين عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق كان لهذا المظهر بدوره الرجوع على المظهرين الضامين له هم المظهر والسابقون عليه، أما الموقعين اللاحقون عليه فليس له حق الرجوع عليهم لأنه الضامن لهم وليس ضامين له.

رجوع الكفيل الصرفي:

الكفيل الصرفي هو الذي يتدخل لضمان أحد الموقعين على الكمبيالة مثل الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل والموفي بالتدخل ويتحدد مركز كل منهم بمركز من تدخل لضمانه. فإذا قام بالوفاء للحامل كان له الرجوع على المضمون وعلى ضامني هذا المضمون تماما كما لو كان الرجوع يتم من الملتزم الذي تدخل لضمانه.

موضوع رجوع من قام بالوفاء على الملتزمين الضامين له:

يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يلي:

- أ) المبلغ الذي أوفاه. ب) عائد هذا المبلغ. ج) المصاريف التي يتحملها.

ثالثا: توقيع الحجز التحفظي على منقولات أحد الموقعين:

شروط توقيع الحجز التحفظي:

١- أن يكون طالب الحجز هو الحامل للكمبيالة:

ولا يقصد بذلك الحامل الأصلي للكمبيالة فحسب بل أيضا كل ضامن دفع قيمة الكمبيالة للحامل وثبت له بذلك حق الرجوع على الملتزمين الآخرين.

٢- أن يكون الدين ثابتا في كمبيالة صحيحة شكلا:

أي كمبيالة تتضمن جميع البيانات الإلزامية التي نص عليها القانون التجاري.

٣- القيام بإجراء احتجاج عدم الوفاء:

يجب أن تكون الكمبيالة قد حرر عنها احتجاج عدم الوفاء، ويلزم تحرير الاحتجاج لتوقيع الحجز التحفظي ولو تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف ويتحمل الحامل في هذه الحالة مصاريف الاحتجاج وحده.

٤- أن يكون المحجوز عليه ملتزما بالوفاء بقيمة الكمبيالة:

يجب أن يكون المحجوز عليه مدينا في الكمبيالة، أي أحد الموقعين عليها، والملتزم التزاما صرفيا فيها كالساحب والمسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين.

٥- أن تنبئ في إجراءات الحجز أحكام قانون المرافعات:

يجب أن تتبع إجراءات الحجز التحفظي المنصوص عليها في قانون المرافعات، فيجب على الدائن أن يحصل على إذن من قاضي التنفيذ لتوقيع الحجز.

الوفاء بالتدخل

ماهية الوفاء بالتدخل:

نظم القانون المدني أحكام الوفاء من غير المدين.

تدخل القانون التجاري ونظم أحكام الوفاء من غير المدين أي الوفاء بالتدخل، وقام بتشجيع هذا الوفاء.

١- أن يقع الوفاء بالتدخل من شخص غير ملتزم بدفع قيمة الكمبيالة:

🏠 يجب أن يصدر الوفاء بالتدخل من شخص غير موقع على الكمبيالة أي غير ملتزم التزاما صرفيا بها، وبالتالي لا يعتبر الوفاء الصادر من أحد الموقعين على الكمبيالة وفاء بالتدخل. 🏠
الموفى بالتدخل قد يتدخل من تلقاء نفسه بقصد معاونة أحد معارفه أثناء تحرير احتجاج عدم الدفع وحرصا منه على سمعته التجارية وقد يتدخل الموفى وهو الوضع الغالب - بتكليف من أحد الموقعين على الكمبيالة تفاديا لمباشرة، إجراءات الرجوع في مواجهته.

٢- أن يقع الوفاء بالتدخل على مبلغ الكمبيالة بالكامل:

🏠 يشترط على الموفى بالتدخل أن يقوم بدفع مبلغ الكمبيالة بالكامل. فلا يجبر الحامل على قبول الوفاء بالتدخل إذا كان جزئيا واقعا فقط على جزء من مبلغ الكمبيالة.

٣- يجب أن يقع الوفاء بالتدخل على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء:

🏠 لأنه حتى هذا التاريخ من الجائز أن يقوم المسحوب عليه بالدفع، لذلك يجب أن يقع الوفاء بالتدخل بعد استحقاق الكمبيالة، وحتى اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

٤- أن يجد الموفى بالتدخل الملتزم الذي تدخل لمصلحته:

🏠 لا يقع الوفاء بالتدخل إلا لمصلحة أحد الملتزمين بالكمبيالة، حيث يشترط أن يقع الوفاء بالتدخل لمصلحة الساحب أو أحد المظهرين، ويجب على الموفى بالتدخل بيان الشخص الذي تدخل لمصلحته بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته.

آثار الوفاء بالتدخل:

١- براءة ذمة الملتزمين بالكمبيالة قبل الحامل:

🏠 يترتب على الوفاء بالتدخل براءة ذمة جميع الملتزمين في الكمبيالة قبل الحامل ويحق للموفى بالتدخل الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة ولكن مركزه في الرجوع يتحدد بمركز الملتزم الذي تدخل لمصلحته.

٢- يحق للموفى بالتدخل الرجوع على من أوفى لمصلحته بدعوى شخصية قائمة على الوكالة إذا أوفى نيابة عنه أو الفضالة إذا كان غير ذلك:

🏠 تقام هذه الدعوى وفقا للقواعد العامة، هذا بالإضافة لحقه في الرجوع وفقا لدعوى الحلول الصرفية وفقا لأحكام قانون الصرف.

٣- تقدم أكثر من موفى للوفاء بالتدخل:

🏠 إذا فرض وتقدم عدة أشخاص للوفاء بالتدخل، فإنه يفضل من يترتب على تدخله براءة أكبر عدد من الملتزمين بالكمبيالة، وبالتالي يتقدم من يتدخل لمصلحة المسحوب عليه القابل ويلييه من يتدخل لمصلحة الساحب ثم المظهر الأول ثم المظهر الثاني.

انقضاء الالتزام الثابت في الكمبيالة بالسقوط أو التقادم

السقوط

السقوط يعتبر جزاء فرضه المشرع على حق الحامل في الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة إذا أهمل اتخاذ الإجراءات التي فرضها قانون الصرف عند الامتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة أو الامتناع عن قبولها.

حالات السقوط

١- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع:
(أ) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع:

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع يجب تقديمها خلال سنة من تاريخ إصدارها، وتحسب مدة السنة من تاريخ إصدار الكمبيالة، وتسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل.

(ب) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع:

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها حتى يتحدد ميعاد استحقاقها.

٢- مضي ميعاد عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء:

فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في ميعاد معين أو بعد مدة من تاريخ إصدارها فإنه يجوز للحامل تقديم الكمبيالة للقبول في هذه الحالة بداية من تاريخ إصدارها حتى تاريخ الاستحقاق وبالتالي يحق له عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة إذا تم تقديمها للقبول ورفض المسحوب عليه القبول، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع فإنه يجب تقديم الكمبيالة للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها ويجب عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة. أما الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع فإنه لا يعمل عنها احتجاج عدم القبول وإنما يعمل عنها احتجاج عدم الوفاء مباشرة خلال مدة السنة التي يجب تقديمها خلالها للوفاء.

٣- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتغالها على شرط الرجوع بلا مصاريف:

إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط بدون احتجاج فإن هذا لا يعفى الحامل من تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء في المواعيد المحددة لها، وإن كان يعفيه من عمل الاحتجاج فقط. بالتالي يسقط حق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتغالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.

٤- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للقبول إذا اشترط تقديمها في ميعاد معين:

للساحب أو أحد المظهرين اشتراط تقديم الكمبيالة للقبول في تاريخ معين فإذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين ولم يلتزم الحامل بتقديمها للقبول في هذا الميعاد سقط حقه في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء.

حالات عدم السقوط

١- عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق:

القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة، وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف.

ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة الحامل وأن عدم التقدم في الميعاد أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل- فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله وليس للحامل في هذه الحالة إلا الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء، أما إذا لم يقدم الساحب هذا المقابل أو أنه قدم مقابل الوفاء ولكن لم يستطيع إثبات ذلك فإنه يظل مسئول في مواجهة الحامل رغم إهماله في اتباع الإجراءات أو عدم مراعاة مواعيد القيام بها.

٢- شهر إفلاس المسحوب عليه أو شهر إفلاس الساحب:

لا يترتب على شهر إفلاس المسحوب عليه - وكذلك شهر إفلاس الساحب في الكمبيالة المتضمنة شرط عدم تقديمها للقبول بسقوط حق حامل الرجوع على الضامنين إذا لم يتم بالإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو لم يراعي مواعيد إجرائها لأن تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين حامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .

٣- عدم الإخطار في المواعيد التي حددها قانون الصرف:

يلتزم حامل الكمبيالة بإخطار من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.

ولا يترتب على عدم مراعاة الإخطار في المواعيد السابقة سقوط حق من وجب عليه الإخطار، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهمال الإخطار في الميعاد بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

٤- القوة القاهرة:

إذا كان عدم إمكان حامل القيام بالإجراءات القانونية راجعا إلى قوة القاهرة فإنه طبقا للقواعد العامة تمتد مواعيد القيام بهذه الإجراءات لحين انتهاء القوة القاهرة.

وعلى حامل في هذه الحالة إخطار من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة دون إبطاء وأن يثبت هذا الإخطار. ولكن إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتمزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج ولا يعتبر حامل في هذه الحالة مهملا. أما إذا زالت القوة القاهرة فإن حامل يعود إلى التزامه بتقديم الكمبيالة للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء.

نظام السقوط

السقوط لا يستفيد منه جميع الملتمزمين في الكمبيالة ويتبين ذلك من استعراض علاقة حامل بكل من هؤلاء الملتمزمين.

أولا: العلاقة بين الحامل المهمل والساحب:

القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على حامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات.

ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة حامل - أي أثبت أن مقابل الوفاء ظل موجود لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق وأن عدم التقدم في الميعاد وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل - فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة حامل بسقوط حقه نتيجة إهماله.

ثانيا: العلاقة بين الحامل المهمل والمسحوب عليه:

إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة فإنه لا يدخل ضمن أحكام الالتزام الصرفي ولا يعد مدينا صرفيا ولا تعنيه في هذه الحالة مسألة سقوط حق حامل المهمل.

ثالثا: العلاقة بين الحامل المهمل والمظهرين:

يجوز للمظهرين دائما وفي جميع الأحوال التمسك بسقوط حق حامل المهمل في الرجوع عليهم إذا لم يتم بالإجراءات التي قررها قانون الصرف أو قام بها في غير مواعيدها.

رابعا: العلاقة بين الحامل المهمل والضامن الاحتياطي والقابل بالدخ:

يلتزم الضامن الاحتياطي والقابل بنفس التزامات من تدخل لمصلحته وبالتالي فإن الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل عن الساحب ليس لهم التمسك بسقوط حق حامل المهمل إلا إذا كانت الساحب قد قدم مقابل الوفاء وتم إثبات ذلك.

- ١- أنه متعلق بدعوى الصرف فقط.
- ٢- يجوز التمسك بالسقوط في مواجهة الحامل ولو كان قاصرا.
- ٣- يجوز التمسك بالسقوط ولو لم يترتب على إهمال الحامل ضرر بمن يحتج عليه.
- ٤- لا يعتبر السقوط من النظام العام. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
- ٥- التمسك بالسقوط حق شخصي، فإذا تنازل أحد المظهرين عن التمسك بالسقوط فإن هذا لا يمنع الآخرين من التمسك به تجاه الحامل.
- ٦- يجوز التمسك بالسقوط في أي حالة كانت عليها الدعوى.

التقادم الصرفي

- ١- تتقادم الدعاوي الناشئة عن الكميالة تجاه قابليها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- ٢- وتتقادم دعاوي الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكميالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
- ٣- وتتقادم دعاوي المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي سنة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكميالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

نطاق التقادم الصرفي

أولاً: الأوراق الخاضعة للتقادم الصرفي:

التقادم الصرفي في يسري على الدعاوي الناشئة عن الكميالة، كما يسري هذا التقادم على الدعاوي الناشئة عن السند لأمر.

ثانياً: الدعاوي التي تخضع للتقادم الصرفي:

الدعاوي التي تخضع للتقادم الصرفي هي الدعوى الصرفية التي تنشأ عن الكميالة دون غيرها من الدعاوي.

أحكام التقادم الصرفي

أولاً: مدة التقادم الصرفي:

تتقادم الدعاوي الناشئة عن الكميالة تجاه المسحوب عليه القابل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الاستحقاق.

دعاوي الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب فإنها تتقادم بمضي سنة تبدأ من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني.

تتقادم دعاوي المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر تبدأ من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكميالة.

ينقضي التزام الكفيل بمضي ثلاثة سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

ثانياً: انقطاع التقادم:

ينطبق على التقادم الصرفي أسباب الانقطاع العامة وهي المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، والتنبه والحجز، والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع.

ويترتب على انقطاع التقادم زوال المدة السابقة على قيام سبب الانقطاع وسريان مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

وقد جاء القانون التجاري وأورد استثنائين لا يسري عليهما التقادم الصرفي وإنما تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة وفقاً للقواعد العامة، وهما حالة صدور حكم بالدين وحالة الإقرار بالدين بسند منفرد، وبيانها كما يلي:

صدور حكم بالدين:

إذا كان سبب الانقطاع صدور حكم بالدين وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي به فإن الصلة بين الدين والورقة التجارية تنقطع ويصبح الدين مستندا إلى الحكم ذاته فلا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة.

الإقرار بالدين بسند منفرد:

إذا تم الإقرار بالدين بمقتضى سند منفرد مستقل عن الورقة التجارية سري تقادم جديد، مدته خمس عشرة سنة من تاريخ الإقرار في السند المنفرد.

ثالثاً: وقف التقادم:

تطبق القواعد العامة، حيث يوقف التقادم إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، كالحرب مثلاً أو صلة الزوجية بين الدائن والمدين.

الدفع بالتقادم:

يتم التمسك بالتقادم من قبل المدين في صورة دفع يتمسك به المدين عند رفع الدعوى للمطالبة بقيمة الكمبيالة، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

قرينة الوفاء:

تقادم الالتزام الصرفي يقوم على قرينة الوفاء، حيث افترض المشرع أن سكوت الحامل مدة التقادم على أنه استوفى دينه.

السند لأمر

تعريف السند لأمر:

السند لأمر هو صك مكتوب وفقا لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن تعهدا من محرره بدفع مبلغ نقدي معين بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو في تاريخ معين.

تجارية السند لأمر:

السند لأمر من العمليات التجارية أيا كانت صفة ذوى الشأن فيه وأيا كانت طبيعة الأعمال التي أنشأ من أجلها.

اختلاف السند لأمر عن الكمبيالة:

يختلف السند لأمر عن الكمبيالة من ناحية أطرافه، حيث تتضمن الكمبيالة عند إنشائها ثلاثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. أما السند لأمر فهو يتضمن عند إنشائه شخصين فقط هما المحرر والمستفيد.





القسم الثاني
(عمليات البنوك)



الصفحة	السؤال
ص ٥	س ١ : اكتب في تعريف وديعة النقود وما هي الطبيعة القانونية لها وانواعها ؟
ص ٧	س ٢ : اكتب في اثار عقد وديعة النقود ؟
ص ١٠	س ٣ : اكتب في اثار عقد وديعة الصكوك ؟
ص ١١	س ٤ : اكتب في تعريف عقد تأجير الخزائن الحديدية والطبيعة القانونية له ؟
ص ١٣	س ٥ : اكتب في اثار عقد تأجير الخزائن الحديدية ؟
ص ١٥	س ٦ : اكتب في تعريف النقل المصرفي ومزاياه وصوره ؟
ص ١٨	س ٧ : اكتب في اثار عقد فتح الاعتماد العادي ؟
ص ١٩	س ٨ : اكتب في عقد فتح الاعتماد المستندي ؟

نشأة البنوك في مصر:

تم إنشاء أول بنك في مصر عام ١٨٥٦ برأس مال أجنبي. وفي عام ١٩٢١ تمت تصفية هذا البنك وإنشاء فروع لبنوك أجنبية لإدارة رؤوس الأموال الأجنبية. ثم أنشئ البنك الأهلي عام ١٨٩٨ برأس مال أجنبي أيضاً ومنحه المشرع حق إصدار أوراق البنكنوت. وفي عام ١٩٢٠ أسس طلعت حرب أول بنك وطني برأس مال مصري وإدارة مصرية وهو بنك مصر لتولي القيام بأعمال البنوك. وقد لعب بنك مصر دوراً هاماً في الاقتصاد المصري حيث ساهم في تأسيس العديد من الشركات الصناعية والتجارية والتي أصبحت بعد ذلك أساس الاقتصاد المصري المعاصر.

عمليات البنوك:

تتنوع وتتعدد أعمال البنوك بحسب رأس مال البنك والغايات التي يستهدف تحقيقها. **مثال ذلك** ← تأجير الخزائن الحديدية، وقبول الودائع، ومنح الائتمان طويل الأجل وقصير الأجل، وإصدار خطابات الضمان، والإعتمادات المستندية، وفتح الحسابات المصرفية...إلخ.

أنواع البنوك:

تتعدد أنواع البنوك وذلك على النحو التالي:

١. **البنوك التجارية** ← ويقصد بها البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خدمة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي وتبشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية .

٢. **البنوك المتخصصة** ← فيقصد بها البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعاً محدداً من النشاط الاقتصادي كالنشاط الزراعي أو الصناعي أو العقاري وفقاً للقرارات الصادرة بتأسيسها، والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية (م/١٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥).

٣. **بنوك الاستثمار والأعمال** ← ويقصد بها تلك البنوك التي تبشر عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقاً لخطط التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومي .

٤. **بنوك الإصدار (البنوك المركزية)** ← ويقصد بها تلك البنوك التي يعهد إليها بإصدار أوراق النقد والإشراف على نظام الائتمان المصرفي والرقابة على المؤسسات المصرفية ووضع السياسة النقدية للدولة.

وقد أناط المشرع بالبنك المركزي مهمة الإشراف والرقابة على البنوك الأخرى وذلك من خلال التحقق من الأمور الآتية:

١. مدى سلامة المركز المالي لكل بنك ومدى قدرته على الوفاء بما يطلبه المودعون.
٢. مدى التزام البنك بأحكام قانون البنوك والائتمان والتعديلات التي طرأت عليه.
٣. مدى سلامة الأسلوب الذي يسلكه البنك في تقديم الخدمات المصرفية.
٤. مدى سلامة أنظمة العمل وأساليب الضبط والرقابة الداخلية التي يتبعها البنك.
٥. مدى سلامة السياسة الائتمانية والإشراف على تنفيذها بما يتفق والخطط الاقتصادية للدولة.
٦. تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية.

مصادر قانون البنوك:

تمثل مصادر قانون البنوك في المصادر الملزمة هي أحكام التشريع والأعراف المصرفية والعادات المصرفية. والمصادر غير الملزمة وهي القضاء والفقه.

١- المصادر الرسمية

أ- التشريع:

صدرت بعض التشريعات التي تنظم النشاط المصرفي. ومن ذلك القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي. والقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩١ بشأن سرية الحسابات المصرفية. والقانون رقم لسنة ١٩٩٢ بشأن تعديل أحكام قانون البنوك والائتمان المصرفي وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

أخيراً صدر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وتشمل أعمال البنوك طبقاً لهذا القانون وديعة النقود، ووديعة الصكوك، وتأجير الخزائن الحديدية ورهن الأوراق المالية، والنقل المصرفي، والاعتماد العادي، والاعتماد المستندي، والخصم، وخطاب الضمان، والحساب الجاري.

ب- الأعراف المصرفية:

يعد العرف المصرفي أهم مصدر قانون البنك (القانون المصرفي) وذلك بالنظر إلى النشأة العرفية لهذا الأخير.

المقصود بالعرف المصرفي ← اضطراد وتواتر كل من البنوك والعملاء على إتباع حلول معينة مع شعورهم بضرورة الإلتزام بهذه الحلول فيما يتعلق بالعمليات المصرفية.

وعلى ذلك فإن أساس إلزام العرف المصرفي هو التواتر والاضطراد مع شعور الأطراف بالتزامهم بقاعدة معينة. ومن ثم فإن العرف المصرفي يتكون من عنصرين الأول وهو **عنصر مادي** يتمثل في اضطراد وتكرار القاعدة العرفية، والثاني وهو **عنصر معنوي** يتمثل في شعور كل من البنوك والعملاء بإلزام هذه القاعدة العرفية.

ج- العادات المصرفية:

المقصود بالعادات المصرفية ← القواعد التي استقر عليها العمل في مجال المعاملات المصرفية وارتضاها كل من البنك والعميل. وهي تستمد قوتها الإلزامية من عدم اتفاق الأطراف على مخالفتها.

وعلى ذلك يلتزم كل من البنك والعميل بالعادة المصرفية التي استقر العمل على تطبيقها على مسألة معينة ما لم يكن هناك اتفاق بين البنك والعميل على استبعاد هذه العادة. ومن ثم فإن أساس التزام الأطراف بحكم العادة المصرفية هو الرضا الضمني أو الرضا المفترض لكل من البنك والعميل بتطبيق حكم هذه العادة على المشكلة المثارة بينهما.

٢- المصادر التفسيرية

أ- القضاء:

تعتبر أحكام القضاء الصادرة في المنازعات المتعلقة بالعمليات المصرفية مصدراً هاماً من مصادر القانون المصرفي. وذلك نظراً لقلّة التشريعات المكتوبة التي تحكم المنازعات المصرفية. حيث كانت الأعراف والعادات المصرفية هي التي تحكم تلك المنازعات. وقد ظهر الدور الخلاق للقاضي في البحث عن الحلول المناسبة والملاءمة التي تتفق وطبيعة النشاط المصرفي.

ب- الفقه:

يقصد بالفقه مؤلفات فقهاء القانون وتعليقاتهم على الأحكام القضائية ونظرياتهم العلمية التي ناولت قواعد القانون المصرفي بالشرح والتأصيل.

س ١ : اكتب في تعريف وديعة النقود وما هي الطبيعة القانونية لها وانواعها ؟

وديعة النقود

تعريف وديعة النقود:

- ❖ "وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد".
- ❖ **قد ذهب البعض إلى تعريف الوديعة النقدية بأنها** ← عقد بمقتضاه يودع أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بعض النقود لدى البنك على أن يتعهد هذا الأخير برد هذه المبالغ عند الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد فتح حساب الوديعة.
- ❖ **قد ذهب البعض الآخر إلى تعريف الوديعة النقدية بأنها** ← عقد بمقتضاه يودع أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بعض النقود لدى البنك على أن يتعهد هذا الأخير برد هذه المبالغ عند الطلب.

الطبيعة القانونية لعقد وديعة النقود:

- ❖ اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد وديعة النقود.
- ❖ **ذهب البعض** ← إلى القول بأنها **وديعة ناقصة** بالنظر إلى أن البنك وهو المودع لديه لا يلتزم برد ذات النقود المودعة وإنما يلتزم برد مثلها فقط. وبذلك تتميز الوديعة الناقصة عن القرض **ويترتب على ذلك عدة نتائج منها**، أنه لا تجوز المقاصة بين المبالغ المودعة لدى البنك والمبالغ المستحقة له قبل العميل. ولا تقوم جريمة التبديد إذا كان العقد قرض بينما يكون لها محل إذا كان العقد وديعة "**وديعة ناقصة**". ولا تسري الفوائد في القرض إلا من تاريخ المطالبة القضائية وتسري من وقت الإعذار في الوديعة. وأخيراً لا يسأل المودع لديه عن هلاك الشيء المودع إذا هلك بقوة قاهرة، في حين أن البنك ملتزم بالرد دائماً ولا يمكنه التنصل من إلتزامه حتى ولو تعلق الأمر بقوة قاهرة.
- ❖ **الرأي الراجح في الفقه المصري** ← النقود أقرب إلى عقد القرض منه إلى أي عقد آخر خاصة إذا كانت الوديعة تعطى فائدة عند الإيداع (الوديعة لأجل). ذلك لأن البنك يملك المبالغ المودعة لديه وله الحق في التصرف فيها واستخدامها في نشاطه المصرفي - عن طريق منح ائتمان في شكل قروض أو فتح اعتمادات - ويلتزم برد مثلها في أجل معين. حتى في الحالة التي تكون فيها الوديعة لدى الطلب فإن هذا لا يحول دون اعتبارها قرض لأن العائد وإن كان من طبيعة عقد القرض إلا أنه ليس من مستلزماته. فلس هناك ما يمنع أن يكون القرض مستحق الرد لدى الطلب.
- ❖ وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها إلى البنك الذي يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لدى البنك هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدني قرضاً".
- ❖ **رأي الدكتور** ← نرى مع البعض أن عقد وديعة النقود عقد مستقل بذاته سواء من حيث النشأة أو الآثار ابتكره الفن المصرفي ليتناسب ومتطلبات البيئة المصرفية التي تختلف تماماً عن البيئة المدنية.

أنواع الودائع النقدية:

أولاً: أنواع الودائع النقدية بالنظر إلى موعد استردادها:

١- ودائع لدى الطلب:

هي الودائع التي يجوز فيها للمودع طلب استردادها في أي وقت، وتسمى بالودائع الجارية. ونظراً لأن البنك لا يستطيع استعمال النقود المودعة في شكل "وديعة جارية" حيث يحتفظ في خزائنه بجزء كبير منها لمواجهة طلبات العملاء فإن هذه الوديعة لا يتقرر عنها فائدة في معظم الأحوال.

٢- ودائع لأجل:

هي الودائع التي لا يجوز فيها للمودع طلب استردادها قبل حلول الأجل المتفق عليه بمقتضى عقد فتح حساب الوديعة. وتشكل هذه الوديعة الجزء الغالب من موارد البنوك حيث تستطيع استخدامها في مباشرة وظيفتها الأساسية وهي منح الائتمان وهي مطمئنة إلى أن أصحابها لن يطلبوها قبل حلول الأجل المتفق عليه. ونتيجة لذلك تقرر البنوك على هذه الودائع فائدة مرتفعة نسبياً.

٣- ودائع بشرط الإخطار السابق:

هي الودائع التي لا يجوز فيها للمودع طلب استردادها إلا بعد مرور فترة زمنية معينة من يوم إخطار البنك برغبته في الاسترداد كيومين أو ثلاثة أيام... إلخ. والهدف من التزام العميل بإخطار البنك هو منح هذا الأخير مهلة يتدبر فيها موارده المالية للوفاء بها النوع من الودائع. وغالباً ما تقرر البنوك على هذه الودائع فائدة منخفضة عن تلك التي تقررها للودائع لأجل.

تكوين عقد وديعة النقود وإثباته:

عقد فتح حساب وديعة النقود بين البنك والعميل من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي. فالبنك له مطلق الحرية في قبول طلب العميل فتح الحساب أو رفضه في ضوء المركز المالي للعميل وخبرة البنك في تحمل المخاطر.

يتم عقد الإيداع بتوقيع العميل على النموذج المكتوب والذي يعده البنك قبل ذلك.

يخضع عقد وديعة النقود للقواعد العامة التي تحكم إبرام العقد وشروط صحته وإثباته مع الأخذ في الاعتبار ما يتعين إعماله من قواعد تتوافق والطبيعة التجارية لعقد وديعة النقود.

بناء على ذلك يجب أن يتوافر رضا العميل والبنك وأن ينصب هذا الرضاء على كل شروط العقد فضلاً عن توافر الأهلية اللازمة لعقد وديعة النقود وأن يكون محل العقد وسببه مشروعاً.

بالنسبة للأهلية التي يجب توافرها في العميل فهي أهلية التصرف والتي تستلزم في العميل أن يكون كامل الأهلية أي بالغ من العمر إحدى وعشرين عاماً ولم يصبه عارض أو مانع من موانع الأهلية. ويشترط في القاصر البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً أن يكون مأذون له بالتجارة أو إدارة الأموال حتى يحق له القيام بفتح حساب وديعة النقود. وللولي أو الوصي أو القيم فتح الحساب إذا كان الشخص غير كامل الأهلية بسبب صغر السن أو سفه أو عته.

فضلاً عن ذلك يجوز للشخص الاعتباري كالشركات فتح حساب وديعة النقود ويمثله في ذلك من ينوب عنه قانوناً كمدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بشرط أن يكون اشخص الاعتباري متمتعاً بالشخصية القانونية.

١- الودائع المخصصة لغرض معين:

- هي الودائع التي يخصصها العميل بهدف تحقيق غرض معين.
- قد يكون التخصيص لمصلحة العميل كتخصيص الوديعة للوفاء بقيمة شيك، أو لشراء أوراق مالية كالأسهم والسندات. وقد يكون التخصيص لمصلحة البنك ذاته كما لو خصصت الوديعة لضمان حساب آخر. وأخيراً قد يكون التخصيص لمصلحة الغير كما لو كانت الوديعة للوفاء بقيمة الكمبيالات التي يسحبها العميل على البنك.

٢- الودائع الادخارية:

- هي الودائع التي تستهدف الادخار والحصول على الفائدة. وتتم عمليات السحب والإيداع من خلال القيد في دفتر خاص يسمى بـ دفتر التوفير يسلمه البنك لعميله. ولا يجوز استعماله إلا من العميل نفسه أو من وكيله أو ورثته.
- يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر، ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع في هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون.
- بالنسبة للعميل فيكون عقد وديعة النقود تجارياً أو مدنياً بحسب الغرض من الوديعة.
- ترتيباً على ذلك إذا كان العميل تاجر وكان حساب وديعة النقود متعلقاً بشئون تجارية أصبح العقد تجارياً بالنسبة لكل من البنك والعميل. أما إذا كان العميل غير تاجر فالعقد يعتبر تجارياً بالنسبة للبنك فقط ومدنياً بالنسبة للعميل. وعلى ذلك يتعين على البنك إثبات عقد وديعة النقود وفقاً لقواعد الإثبات المدنية.

س ٢: اكتب في اثار عقد وديعة النقود ؟

آثار عقد وديعة النقود:

أولاً: حقوق والتزامات البنك:

١- حقوق البنك:

- سبق وأن أوضحنا أن لفقه المصري قد أجاز إلى تكليف عقد وديعة النقود بأنها قرض. وتأسيساً على ذلك فإن البنك يمتلك النقود المودعة وله حق التصرف فيها واستخدامها في نشاطه المصرفي وبصفة خاصة منح الائتمان في شكل قروض أو فتح اعتمادات.

٢- التزامات البنك (حقوق العميل): وتتمثل التزامات البنك فيما يلي:

أ- الالتزام برد مبالغ مسددة للمبالغ المودعة لديه:

- يلتزم البنك باعتباره مقترضاً برد ذات العدد من المبالغ بغض النظر عن قيمتها. فالبنك يلتزم برد مثل ما تسلمه من العميل وليس قيم ما تسلمه.
- والالتزام البنك برد عدد المبالغ المودعة لديه يتم في الميعاد والمكان المتفق عليهما طبقاً لشروط العقد. فإذا تم الاتفاق على أن يسترد العميل وديعته من البنك الذي تم به الإيداع فلا يجوز له أن يطالب باسترداد وديعته من فرع آخر من فروع البنك. وإذا أغفل عقد الوديعة تحديد المكان الذي يجوز للعميل استرداد وديعته فيه فإن الاسترداد يتم في الفرع الذي تم به الإيداع. وإذا كان محل عقد الوديعة عملة أجنبية يلتزم البنك برد ذات العملة وذات العدد الذي تسلمه من العميل. وفضلاً عن ذلك يلتزم البنك برد المبالغ المودعة لديه في الميعاد المتفق عليه في عقد الوديعة. فإذا كانت وديعة لدى الطلب فيتعين على البنك ردها فور طلب العميل لها ما لم تكن بشروط الإخطار السابق وفي هذه الحالة يلتزم البنك بردها للعميل بعد مرور الفترة الزمنية المتفق عليها محسوب من تاريخ الإخطار. وإذا كان الوديعة لأجل، يلزم البنك بردها عند حلول هذا الأجل.

عند وفاة المودع يلتزم البنك باستمرار الوديعة وفقاً لشروطها مالم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.

ب- التزام البنك برد الوديعة إلى صاحب الحق فيها أو من يحدده:

يلتزم البنك برد الوديعة إلى العميل المودع باعتباره صاحب الحق فيها أو من يعينه. ويتعين على البنك التحقق من شخصية العميل قبل تسليمه الوديعة. وتلجأ البنوك في سبيل تحقيق ذلك إلى الحصول على عدة توقيعات للعميل لمضاهاتها عند التوقيع بالاستلام الوديعة.

ج- التزام البنك بدفع عائد عن وديعة النقود:

يلتزم البنك بدفع عائد عن المبالغ المودعة لديه وذلك طبقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد الوديعة. الأصل أن الودائع لدى الطلب لا تنتج عائد بالنظر إلى أن البنك لا يستطيع استخدامها في مباشرة نشاطه المصرفي فهو يحتفظ بجزء كبير منها في خزائنه لمواجهة طلبات العملاء. بالنسبة للوديعة لأجل تقرر لها البنوك عائد مرتفع تأسيساً على أن البنوك تستطيع الإفادة منها واستخدامها في منح الائتمان. بناء على ذلك فالقاعدة أن البنك يستقل بتحديد العائد الذي يدفعه عن الودائع النقدية مراعيًا في هذا الخصوص أسعار العائد الذي يتعامل به البنك المركزي والنسب التي تمنحها البنوك المنافسة لعملائها على الودائع النقدية.

ثانياً: حساب وديعة النقود:

الأصل ← هو أن يكون لكل عميل حساب واحد لدى البنك، ومع ذلك يجوز أن يكون للعميل أكثر من حساب لدى بنك واحد أو لدى فروع مختلفة. وإذا كان الأصل أيضاً أن يكون الحساب باسم عميل واحد إلا أنه يجوز أن يكون الحساب مشترك بين عدة أشخاص.

١- تعدد الحسابات:

الرغم من أن الأصل أن يكون للعميل حساب واحد لا أنه قد تتنوع المبررات والأهداف التي يسعى العميل لتحقيقها من خلال فتح الحسابات. فإذا كان العميل تاجراً فقد يترأى فتح حسابات متعددة لمختلف أوجه نشاطه التجاري. وأيضاً إذا كان العميل غير تاجر يستطيع أن يفتح أكثر من حساب، فقد يقوم بفتح حساب وديعة أو حساب جاري أو حساب توفير. لا يثير تعدد الحسابات أي مشاكل قانونية إذا تم فتح هذه الحسابات في بنوك مختلفة إذ يخضع كل حساب لأحكام العقد الذي تم إبرامه بين العميل والبنك. أما إذا تعددت الحسابات لعميل واحد في ذات البنك فقد نصت المادة ٣٠٧ من قانون التجارة على أنه: "إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخرى". ويترتب على مبدأ استقلال الحسابات أنه لا تجوز المقاصة بين حسابات العميل المختلفة، كما لا يجوز للبنك أن يمتنع عن وفاء شيك سحبه العميل على حساب دائن بحجة أن أرصده في الحسابات الأخرى مدينة.

ب- الحساب المشترك

إذا كان الأصل أن يكون الحساب المصرفي باسم عميل واحد، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل ويجوز أن يضم الحساب الواحد أكثر من عميل وهو ما يسمى **بالحساب المشترك**. يتم فتح الحساب المشترك عادة بين أشخاص يثق كل منهم في الآخر كالأزواج أو الأشقاء. ويتميز الحساب المشترك بالتضامن سلباً وإيجاباً بين أطرافه. **ويقصد بالتضامن الإيجابي** أن يكون من حق كل طرف أن يقوم بالسحب والإيداع من الحساب بتوقيعه المنفرد، كما أن وفاة أحد أطراف الحساب لا يمنع الآخرين الأحياء من القيام بكافة العمليات في الحساب سواء أكان سحباً أو إيداعاً. وقد حكم بأنه في حالة علم البنك بوفاة أحد الحساب المشترك وكان له ورثة عليه إرسال ذات كشوف الحساب إليهم التي يرسلها إلى باقي أطراف الحساب. وقد يكون التضامن سلباً إذا كان من حق البنك الرجوع بكل ماله من دين على أي من أطراف الحساب.

✍ إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقيين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية، وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية .

وديعة الصكوك

✍ يلجأ الأشخاص - أحياناً - فضلاً عن إيداع النقود لدى البنك إيداع صكوك كالأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو أوراق تجارية، أو شهادات استثمار أو صكوك تمويل، أو أوراق أخرى ذات أهمية خاصة للمودع كالمراسلات أو مذكرات، أو مستندات ملكية عقار أو منقول. ويستهدف المودع من ذلك إما المحافظة على هذه الصكوك من خطر السرقة أو الضياع أو اطلاع الغير عليها وما قيام البنك بتحصيل ما تحققه هذه الأوراق من أرباح وفوائد أو بتجديدها عند انتهاء مدتها.

تعريف وديعة الصكوك:

✍ هو عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء على أن يردده عيناً .
✍ ويُعرف البعض عقد وديعة الصكوك بأنه ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه البنك بالمحافظة على الصكوك التي أودعها العميل لديه بكافة الخدمات اللازمة لحفظ ما يترتب على هذه الصكوك من أرباح أو فوائد أو ما تستلزمه من إجراءات التحصيل.

نكوبن عقد وديعة الصكوك وتجارينه وإثباته:

✍ عقد وديعة الصكوك عقد رضائي ينعقد بتلاقي الإيجاب والقبول دون التوقف على أي إجراء آخر.
✍ ويتم العقد بتوقيع العميل على النموذج المعد مسبقاً من قبل البنك، ويستقل هذا الأخير بتحديد شروطه دون أن يكون للعميل أدنى حرية في مناقشة هذه الشروط فيما أن يقبلها برمتها وإما أن يرفضها برمتها.
✍ الأمر الذي حدا بالبعض إلى القول بأن عقد إيداع الصكوك عقد إنعادي.
✍ الحقيقة أن عقد إيداع الصكوك ليس عقد إنعادي ذلك أن موضوعه لا ينصب على استخدام مرفق حيوي لا يمكن الاستغناء عنه. فضلاً عن أن نشاط إيداع الصكوك ليس حكراً على البنوك.
✍ يتعين أن يكون الرضا صحيحاً حالياً من عيوب الإرادة، وأن يكون المودع كامل الأهلية، لأن الأمر يتعلق بوديعة مأجورة. ومع ذلك يجوز أن يبرم عقد وديعة الصكوك من بلغ السادسة عشر من عمره وكان يعمل وله دخل من عمله. ويجوز للقاصر البالغ من العمر الثامنة عشر أن يبرم عقد وديعة الصكوك متى كان مأذوناً له بالتجارة. وأخيراً يجوز للولي أو الوصي برام عقد الوديعة نيابة عن القاصر.
✍ فضلاً عن ذلك يتعين أن يكن محل عقد وديعة الصكوك وسببه مشروعين.
✍ يعتبر عقد إيداع الصكوك عملاً تجارياً بالنسبة للبنك على اعتبار أنه أحد أعمال البنوك التجارية إذا تمت مزاولتها على وجه الاحتراف. وعلى ذلك يجوز للمودع إثبات عقد وديعة الصكوك في مواجهة البنك بكافة طرق الإثبات .

✍ بالنسبة للعميل فلا يكون عقد وديعة الصكوك تجارياً إلا إذا كان العميل تاجراً وتعلق العقد بشئون تجارته. وعلى ذلك يجوز للبنك أن يثبت عقد وديعة الصكوك في مواجهة العميل بكافة طرق الإثبات. أما إذا كان عقد وديعة الصكوك مدنياً بالنسبة للعميل فيلتزم البنك لإثبات العقد باتباع طرق الإثبات المدنية والتي تقضي بوجود الإثبات بالكتابة إذا تجاوزت قيمة الدين ألف جنيه .

س ٣: اكتب في اثار عقد ودیعة الصكوك ؟

آثار عقد ودیعة الصكوك:

أولاً: التزامات البنك:

١- الإلتزام بالمحافظة على الصكوك المودعة:

- ✍ يلتزم البنك باعتباره مودعاً لديه بأجر بالمحافظة على الصكوك التي تسلمها من العميل. ويبذل البنك في المحافظة على هذه الصكوك عناية الرجل المعتاد. ولا يتعلق الأمر في هذا الصدد بأي شخص عادي وإنما يتعلق ببنك يحترف مهنة تلقي الودائع. وقد أكدت هذا المعنى المادة ١/٣١١ من قانون التجارة فنصت على أنه: "على البنك أن يبذل في المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك".
 - ✍ يستلزم حفظ الصكوك المودعة أن يبذل البنك العناية اللازمة لتأمين الصكوك وعدم تعرضها للسرقة أو الضياع أو التلف أو إطلاع الغير عليها.
 - ✍ يتفرع من التزام البنك بحفظ الصكوك التزامه بالامتناع عن استعمال الصكوك أو التصرف فيها بالبيع أو الرهن. كما يتعين عليه أن يقوم بحفظ الصكوك المودعة لديه بنفسه ولا يحل غيره محله في تنفيذ هذا الإلتزام ما لم يأذن له المودع بذلك صراحة أو يكون هناك ضرورة ملحة أو عاجلة.
 - ✍ تنعقد مسؤولية البنك في مواجهة العميل إذا هلك الصكوك أو فقدت وكان هذا الهلاك أو الفقد بسبب خطئه. وتنتفي هذه المسؤولية إذا كان الهلاك أو التلف مرده القوة القاهرة.
 - ✍ كما يلتزم البنك بالمحافظة على الصكوك حفظاً مادياً أي تأمينها من خطر الضياع أو السرقة فهو يلتزم أيضاً بالمحافظة على حقوق المودع المرتبطة بالصكوك المودعة.
 - ✍ وفي ذلك تنص المادة ١٢٢ من قانون التجارة على أنه:
١. يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمه إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك وتقييد تلك المبالغ في حساب المودع.
 ٢. وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التي يتقرر منحها له دن مقابل كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه".
- ✍ ويجب على البنك - فضلاً عن ذلك - أن يباشر جميع الأعمال اللازمة لرعاية حقوق المودع الناشئة عن الصك كتقديمه للاستبدال كما لو كان سند وتحول إلى سهم، أو تقديم الصك لوضع الختم عليه كما في حالة إيداع قسائم أو كوبونات يلزم ختمها من جهة إصدارها، أو الحصول على قسائم الأرباح الجديدة الصادرة لصالح المودع.
 - ✍ بالإضافة إلى ذلك يتعين على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع. ويتحمل المودع المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.

٢- الإلتزام برد الصكوك المودعة:

- ✍ يلتزم البنك بالرد في المكان الذي تم فيه الإيداع. ومع ذلك يجوز الاتفاق على رد الصكوك المودعة في أحد فروع البنك رغم أن الإيداع قد تم في المركز الرئيسي. ويلتزم البنك برد الصكوك ذاتها ما لم يتفق أو يقضي القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.
- ✍ يلتزم البنك برد الصكوك المودعة لديه للمودع نفسه أو لخلفائه أو لمن يعنيه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير. ويتعين على البنك التحقق من شخصية من يطالبه باسترداد الصكوك المودعة وأهليته وصحة توقيعاته وسند نيابته في حالة إنابة شخص آخر غير المودع.

✍ كما أنه يجوز للبنك وفقاً للقواعد العامة أن يمتنع عن رد الصكوك المودعة لديه في الحالات الآتية:

١. إذا تم الحجز على الصكوك تحت يد البنك أو ادعى شخص ملكيتها ورفع دعواه خلال المدة القانونية.
 ٢. حبس الصكوك حتى يستوفي البنك حقه قبل المودع.
 ٣. إذا قام البنك بتوقيع الحجز عليها تحت يد نفسه.
 ٤. إذا زال عقد الوديعة وحل محله عقد جديد لا يفرض على البنك رد الصكوك.
 ٥. إذا تمسك البنك بامتياز حفظ المنقول على الصكوك المودعة لديه.
 ٦. إذا هلك الصكوك بقوة قاهرة، كالحرقيق أو استيلاء العدو.
- ✍ يتعين على البنك بوصفه مهني محترف أن يتأكد من المطالب بالرد ومدى حقه في استرداد الوديعة.
- ✍ إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهي النزاع بشأنه رضاً أو قضاءً، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الادعاء، وإلا اعتبر الادعاء كأن لم يكن .

ثانياً: التزامات المودع:

١- الإلتزام بتسليم الصكوك إلى البنك:

✍ يرتب عقد الوديعة على عاتق المودع الإلتزام بتسليم الصكوك محل عقد الإيداع إلى البنك. وذلك حتى يتسنى للبنك حفظ هذه الصكوك ومن ثم الحصول على العمولة المتفق عليها والمستحقة عن هذا الإيداع.

٢- الإلتزام بدفع الأجر والعمولة:

✍ يلتزم المودع بأن يدفع للبنك المودع لديه الأجر المتفق عليه في عقد الإيداع. وذلك مقابل قيام البنك بحفظ الصكوك محل العقد، ويسمى بأجر الحفظ. كما يلتزم المودع بدفع عمولة مقابل الخدمات التي يقوم بها البنك لصالح المودع والمتعلقة بالصكوك التي ترتب حقوق أو خيارات للمودع كألسهم والسندات.

٣- الإلتزام بدفع المصروفات:

✍ يلتزم المودع بدفع المصروفات التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذ أوامر العميل المتعلقة بالصكوك محل الإيداع. ويجوز للبنك- وفقاً للقواعد العامة- حبس الصكوك محل عقد الإيداع لضمان استيفاء حقه في الأجر والعمولة والمصاريف .

س ٤ : اكتب في تعريف عقد تأجير الخزائن الحديدية والطبيعة القانونية له ؟

تأجير الخزائن الحديدية

تعريف عقد تأجير الخزينة الحديدية:

✍ تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة .

✍ يحقق تأجير الخزينة فوائد لكل من البنك والعميل. فبالنسبة للعميل يستطيع أن يحفظ أوراقه ومستنداته الهامة وأشياءه الثمينة في الخزينة لتأمينها ضد السرقة أو إطلاع الغير عليها. وبالنسبة للبنك فهو يحصل على أجر يتحدد طبقاً لحجم الخزينة ومدة الانتفاع بها. كما أن هذا التأجير للخزائن يعد وسيلة لجذب العملاء وزيادة تعامله مع البنوك.

تكوين عقد تأجير لخزينة وإثباته:

- عقد تأجير الخزائن الحديدية عقد رضائي ينعقد بتلاقي الإيجاب والقبول. ويتم العقد بتوقيع العميل على النموذج المعد سلفاً من قبل البنك ويستقل هذا الأخير بتحديد شروطه دون أن يكون للعميل أدنى حرية في مناقشة هذه الشروط فيما أن يقبلها برمتها أو يرفضها برمتها. الأمر الذي هذا البعض إلى القول بأن عقد تأجير الخزائن الحديدية عقد إنذعان.
- يتعين أيضاً أن يكون الرضا صحيح خال من عيوب الإرادة، وأن يكون العميل مستأجر الخزينة كامل الأهلية. ومع ذلك يجوز أن يبرم عقد إيجار الخزائن الحديدية من بلغ السادسة عشر من عمره وكان يعمل وله دخل من عمله. ويجوز للقاصر البالغ من العمر الثامنة عشر أن يبرم العقد متى كان مأذوناً له بالاتجار.
- يعتبر عقد إيجار الخزائن الحديدية عملاً تجارياً بالنسبة للبنك بالنظر إلى أنه أحد أعمال البنوك التي تعتبرها المادة المذكورة تجارة إذا تمت مزاولتها على وجه الاحتراف. وعلى ذلك يجوز للعميل مستأجر الخزينة إثبات عقد التأجير في مواجهة البنك بكافة طرق الإثبات .
- بالنسبة للعميل المستأجر فلا يكون عقد تأجير الخزينة تجارياً إلا إذا كان العميل تاجر وتعلق العقد بشئون تجارته ويجوز للبنك أن يثبت عقد تأجير الخزينة في مواجهة العميل بكافة طرق الإثبات. أما إذا كان عقد تأجير الخزينة مدنياً بالنسبة للعميل فيلتزم البنك لإثبات العقد باتباع طرق الإثبات المدنية والتي تقضي بوجود الإثبات بالكتابة إذا تجاوزت قيمة الدين ألف جنيه .

الطبيعة القانونية لعقد تأجير الخزينة الحديدية:

- اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لعقد تأجير الخزائن الحديدية، ومرجع هذا الخلاف أن عقد تأجير الخزائن يجمع بين خصائص كل من عقد الوديعة وعقد الإيجار. فالعميل وإن كان يستأجر خزينة معين يلتزم بالبنك بوضعها تحت تصرفه مقابل أجره يتم الاتفاق عليها وينفرد العميل وحده بمعرفة الصكوك والمستندات التي يضعها في الخزينة مما يجعله قريباً من عقد الإيجار، إلا أن القصد الرئيسي للعميل من تأجير الخزينة ليس مجرد إيداع هذه الصكوك والمستندات في الخزينة طرف البنك وإنما يأخذ في اعتباره أن البنك يقوم بحراسة هذه الخزينة وهو الأمر الذي دفع البعض إلى اعتبار أن عقد إيجار الخزائن من **عقود الحراسة**. فالأمر ليس في تأجير الخزينة، وإنما في "المكان الذي توجد فيه الخزينة ما يحيط بهذا المكان من احتياطات غير عادية تحقق أماناً شبه كامل، إذ لا يعفى البنك من المسؤولية سوى القوة القاهرة.
- يرى البعض الآخر أن عقد تأجير الخزائن هو **عقد وديعة** وذلك تأسيساً على أن العميل يقوم بإيداع الصكوك والمستندات في خزانة يؤجرها له البنك بهدف حفظها من السرقة أو التلف أو الهلاك. ويعد الإلتزام بالحفظ أهم التزامات البنك في مواجهة العميل. فجوهر عقد تأجير الخزينة هو الحفظ وهذا فضلاً عن أن انتفاع العميل بالخزانة يتوقف على تدخل البنك حيث يحدد هذا الأخير له أوقات محددة مما يجعل العقد قريباً من الوديعة.
- أخيراً يرى فريق ثالث أن عقد تأجير الخزائن هو **عقد إيجار** وذلك استناداً إلى أن البنك وإن كان يلتزم - بمقتضى العقد - بأن يضع تحت تصرف العميل خزينة مقابل أجر معين إلا أنه لا يعلم محتوياتها بل يتعين عليه ألا يحاول كشف ما يضعه العميل داخل الخزينة. وللعميل وحده حق حيازة مفتاحها وهو الذي يعلم ما بداخلها.

✍ **الرأي الراجح فقهاً وقضاً** ← يرى أن عقد تأجير الخزائن هو **عقد إيجار**، ولكنه ليس إيجاراً عادياً للأشياء أو المنقولات وإنما إيجار موضوعه خزانة لدى بنك أي في مكان آمن ويلتزم البنك بحفظ محتويات الخزانة ضد الهلاك والسرقعة. ولا ينال من هذا أن المستأجر لا يستطيع الانتفاع بالخزانة إلا بتدخل البنك ذلك لأن تدخل هذا الأخير لازم وضروري لتنفيذ الناشئ عن عقد الإيجار وهو المحافظة على الخزانة ومحتوياتها.

الحجز على محتويات الخزانة:

✍ النسبة للفريق الذي يعتبر أن العقد إيجار يرى أنه يجوز توقيع الحجز التنفيذي على محتويات خزانة العميل وإن كان هذا الحجز لا جدوى منه من الناحية العملية حيث يستلزم إعلان المدين مباشرة بإجراءات الحجز الأمر الذي يدفع العميل المدين مستأجر الخزانة تفريغها من محتوياتها.

✍ بالنسبة للفريق الذي يرى أن العقد وديعة يرى أن الحجز على محتويات الخزانة يتم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير. ويلتزم البنك - بمجرد علمه بتوقيع الحجز - بمنع العميل المدين مستأجر الخزانة من الدخول إلى صالة الخزائن لحين الفصل في النزاع القائم.

✍ قد حسم قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الجدل الفقهي حول جواز الحجز على محتويات الخزانة وكيفية القيام به. حيث أجاز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الخزانة ويوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذي يتم الحجز بموجبه، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يوجد خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة. وإذا كان الحجز تحفظياً، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له في سحب بعض محتويات الخزانة في حضور من يندبه القاضي لذلك. وإذا كان الحجز تنفيذياً التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضي لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذي حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضي التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر. فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق في عرض الأمر على قاضي الأمور الوقفية ليقرر بشأنها ما يراه.

س ٥ : اكتب في اثار عقد تأجير الخزائن الحديدية ؟

آثار عقد تأجير الخزانة الحديدية:

أولاً: التزامات البنك وحقوقه:

أ- التزامات البنك:

✍ تتمثل التزامات البنك التي يرتبها في ذمته عقد تأجير الخزائن في تمكين المستأجر من الانتفاع بالخزانة، والمحافظة على الخزانة المؤجرة.

١- تمكين المستأجر من الانتفاع بالخزانة:

✍ إن الهدف الرئيسي للعميل من تأجير الخزانة هو الانتفاع بها عن طريق وضع الصكوك والمستندات الهامة. ويستلزم هذا الانتفاع أن يسلم البنك إلى العميل المستأجر مفتاح الخزانة ويحدد له المواعيد التي يتعين فيها الدخول إلى صالة الخزائن. كما يحتفظ البنك بمفتاح آخر للخزانة لمجابهة أي ظروف تستلزم تدخل البنك واستعماله هذه النسخة. ولا يجوز تسليم نسخة من المفتاح أي شخص آخر سوى العميل. ويلتزم البنك بالتحقق من شخصية العميل في كل مرة يرغب فيها هذا الأخير الدخول إلى صالة الخزائن والانتفاع بخزنته.

✍ إذا كان للعميل أن ينتفع بخزينته بنفسه فله أن ينيب عنه شخص آخر. وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يخطر البنك باسم الوكيل وصورة من التوكيل. وتحصر البنوك على أن تأخذ توقيع الوكيل ليضاهيه بتوقيعه عند الانتفاع بالخزانة. وإذا انتهت الوكالة لأي سبب من الأسباب يتعين على العميل أن يخطر البنك بذلك وإلا انتفت مسؤوليته عن انتفاع الوكيل بالخزانة.

✍ التزام البنك بتمكين العميل من الانتفاع بالخزينة لا يقتصر على مجرد تمكينه من الانتفاع ولكن يتعين أن يحاط هذا الانتفاع بسرية تامة. فلا يجوز لموظف البنك أن يتواجد أثناء عمليات السحب والإيداع التي يقوم بها العميل في الخزينة.

✍ يقتضي تنفيذ البنك لالتزامه بتمكين العميل من الانتفاع بالخزينة أنه يمتنع على البنك وضع العراقيل المادية أو القانونية التي تحول دون انتفاع العميل بالخزينة المستأجرة. كأن يعترض على عمليات السحب والإيداع من الخزينة عدة مرات في اليوم الواحد، أو يعترض على إيداع بعض الأشياء في الخزينة ما لم تكن من الأشياء المحظور إيداعها طبقاً لشروط العقد أو للقانون.

٢- المحافظة على الخزينة المؤجرة:

✍ يلتزم البنك بالمحافظة على الخزينة المؤجرة حتى يتسنى للعميل المستأجر الانتفاع بها، بل أن جوهر عقد تأجير الخزينة يقوم على أساس التزام البنك بحفظ الأشياء المودعة في الخزينة. ويستلزم ذلك أن يقوم البنك بحراستها للحيلولة دون سرقة محتوياتها أو ضياعها أو تلفها وألتزامه في هذا الصدد هو التزام بتحقيق نتيجة. بمعنى أنه يكفي أن يثبت العميل أن هناك ضرر ما قد حدث ووجود علاقة سببية تربط بين الضرر الحادث وخطأ البنك المتمثل في إهمال حراسة الخزينة أو عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الخزينة المؤجرة ومحتوياتها. ولا يعفى البنك من هذه المسؤولية سوى إثبات القوة القاهرة. ولا تعد الحرب بذاتها قوة القاهرة إذا كانت متوقعة، كما لا يعد طفح المياه والفيضانات داخلية في مفهوم القوة القاهرة.

✍ وتحصر البنوك عادة على إدراج شرط عدم المسؤولية في حالة سرقة أو ضياع محتويات الخزينة بقصد التأجير. ويثور التساؤل عن مدى صحة إدراج مثل هذا الشرط.

✍ يذهب البعض إلى أن اشتراط إعفاء البنك من المسؤولية عن حفظ وحراسة الخزينة المؤجرة ومحتوياتها شرط باطل على اعتبار أنه يتنافى مع مضمون العقد والهدف منه. فضلاً عن أن الخزينة تكون في حوزة البنك وهو المسئول عن حراستها.

✍ ويرى الرأي الراجح أن مثل هذا الشرط لا يترتب عليه إعفاء البنك من المسؤولية على حراسة وحفظ الخزينة في حالة سرقة محتوياتها أو ضياعها أو تلفها، وإنما يقتصر أثر الشرط على تغيير طبيعة التزام البنك من التزام بتحقيق نتيجة إلى التزام بوسيلة. ويترتب على ذلك التزام العميل بإثبات خطأ البنك الذي كان سبباً في سرقة أو هلاك أو تلك محتويات الخزينة.

ب- حقوق البنك:

✍ تتمثل حقوق البنك في دفع الأجرة المتفق عليها في عقد تأجير الخزينة. وإذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.

✍ وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له في فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضي أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك. وللبنك حق حبس محتويات الخزانة، وله امتياز عن الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.

ثانياً: التزامات العميل وحقوقه:

التزامات العميل:

١. **الالتزام بدفع الأجرة المتفق عليه** ← يتعين على العميل دفع الأجر المتفق عليه في عقد تأجير الخزينة وذلك مقابل الانتفاع بهذه الأخيرة. فإذا خلا العقد من تحديد الأجرة التزم العميل بدفع الأجرة التي استقر عليها العرف المصرفي.

- قد جرى العمل على أن تكون الأجرة سنوية تدفع مقدماً وحينئذ يلتزم العميل بدفع الأجر المتفق عليه.
٢. **الانتفاع بالخزينة طبقاً لشروط العقد** ← يلتزم العميل بالانتفاع بالخزينة المؤجرة طبقاً لشروط عقد التأجير وبما يتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ العقد. وترتيباً على ذلك يتعين على العميل الانتفاع بالخزينة في الأوقات التي يحددها له البنك وأن ينتفع بها إما بنفسه وحينئذ يتعين أن يثبت شخصيته للبنك، أو عن طريق وكيل ويجب أن تكون هناك وكالة صريحة تسمح لهذا الأخير بالانتفاع بالخزينة لحساب العميل. كما يجب على العميل ألا يقوم بتأجير الخزينة المؤجرة من الباطن. وأن ينتفع بها في الغرض لمخصص له الخزينة وهو إيداع الصكوك والمستندات الهامة والأشياء التي يخشى عليها العميل من الفقد أو الهلاك أو السرقة.
٣. **الالتزام برد الخزينة عند انتهاء العقد** ← يلتزم العميل برد الخزينة المؤجرة عند انتهاء العقد سليمة وبالحالة التي تسلمها بها من البنك وقت التعاقد. ويتم ذلك بتفريغها من المحتويات الموجودة بها ورد المفتاح الذي تسلمه العميل إلى البنك.

س ٦: اكتب في تعريف النقل المصرفي ومزاياه وصوره؟

النقل المصرفي

تعريف النقل المصرفي:

- النقل المصرفي** ← هو عبارة عن عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب لدائن من حساب آخر. وقد يكون الحساب المحول إليه باسم ذات الشخص الآخر أو باسم شخص آخر يسمى المستفيد، كما قد يتم النقل دخل ذات البنك أو من خلال بنك آخر.
- قد عرف البعض النقل المصرفي بأنه** ← "قيد مالي ومحاسبي يترتب عليه انتقال النقود بين الحسابات التي تم بها القيد. أي نقل مبلغ معين من حساب إلى حساب آخر بمجرد إتمام القيد في كل من الحسابين، بحيث يقيد المبلغ مرة في الجانب المدين من حساب العميل الذي أصدر الأمر بالتحويل إلى البنك ثم يقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن للحساب الآخر".
- قد عرف البعض الآخر النقل المصرفي بأنه** ← "العملية التي تلخص في تفريغ حساب يسمى الأمر، وبناء على طلبه من مبلغ نقدي معين وقيد هذا المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر قد يكون باسم الأمر نفسه أو باسم شخص آخر يسمى المستفيد".

مزايا النقل المصرفي:

- يترتب على عملية النقل المصرفي الوفاء بالديون دون حاجة إلى استعمال النقود. ويسمى النقل بين حسابين في نفس البنك بالتحويل المباشر، أما إذا كان حساب العميل الأمر بالنقل في بنك معين غير بنك الشخص الذي صدر لصالحه الأمر (المستفيد) فيسمى بالنقل غير المباشر.
- فضلاً عن ذلك يعد النقل المصرفي من أبسط عمليات البنوك وأقلها تكلفة. إذ أن نقل النقود يتم بمجرد القيد في الحسابين، حساب العميل الأمر بالنقل وحساب المستفيد.
- أخيراً فإن صدور أمر النقل المصرفي لا يشترط وجود رصيد عند صدوره حيث يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب العميل الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها في حسابه خلال مدة معينة. وفي هذا يختلف النقل المصرفي عن الشيك الذي يشكل إصداره بدون رصيد جريمة جنائية.

إصدار شيك ليس له مقابل وفاء للعرف.

- كما أن ذمة الأمر بالنقل تبرأ بمجرد إضافة قيمة أمر النقل إلى رصيد المستفيد بينما لا تبرأ ذمة صاحب الشيك إلا بقبض قيمته. وفضلاً عن ذلك فإن المستفيد من أمر النقل لا يملك المبلغ محل أمر النقل بمجرد صدور هذا الأخير، بينما تنتقل إلى المستفيد من الشيك ملكية مقابل الوفاء من تاريخ سحب الشيك. ولذلك فإن إصدار شيك لصالح العميل يعد أكثر ضماناً من إصدار أمر النقل المصرفي خاصة في حالة صدور حكم بفسخ الأمر بالتحويل.

✍ في الغالب يصدر أمر النقل المصرفي على مطبوعات خاصة للبنك بسند اسمي يحمل اسم شخص المحول إليه. ويجوز أن يصدر أمر النقل المصرفي لإذن شخص أو لحامله.
✍ يلتزم البنك ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة أمر النقل المصرفي وذلك بالتحقق من شخصية العميل وتوقيعه عن طريق مضاياهات بالنموذج لديه وإلا انعقد مسؤوليته التقصيرية.

صور النقل المصرفي:

١. **النقل المصرفي من حسابين لذات العميل في ذات البنك** ← وفي ذلك تنص المادة ٣٢٩/ب على أنه: " ويجوز بهذه العملية "أي النقل المصرفي" إجراء ما يأتي: (ب) نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم العميل الأمر بالنقل لدى البنك ذاته". كأن ينقل شخص مبلغ من حسابه المخصص لحساباته الشخصية إلى حساب آخر مخصص لمعاملاته المهنية وذلك في نفس البنك. ويتم النقل المصرفي في هذه الحالة بخصم المبلغ محل أمر النقل من الحساب الأول وقيده بالحساب الثاني".
٢. **النقل المصرفي بين حسابين مختلفين في ذات البنك** ← ويتم النقل في هذه الحالة بخصم مبلغ من حساب العميل الأمر وقيده في الجانب المدين منه ثم قيد نفس المبلغ في الجانب الدائن من حساب المستفيد من الأمر.
٣. **النقل المصرفي بين حسابين مختلفين في بنكين مختلفين لذات العميل أو لعميلتين مختلفتين** ← ويتم النقل في هذه الحالة بخصم مبلغ من حساب العميل الأمر وقيده في الجانب المدين منه ثم قيد نفس المبلغ في الجانب الدائن من حساب بنك المستفيد، ويقوم بنك العميل الأمر بالتحويل إخطار بنك المستفيد بوضع ائتمان تحت تصرفه في حدود المبلغ الذي صدر بأنه أمر التحويل. وأخيراً يقيد بنك المستفيد المبلغ المحول في الجانب الدائن من حساب المستفيد ويتم تسوية عملية النقل المصرفي بين البنكين بطريق المقاصة.

✍ هذا وقد نظمت المدة ٣٢٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تنفيذ أمر النقل المصرفي بقولها:

١. إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة في هذا الأمر وكان الأمر موجهاً من الأمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون إبطاء.
٢. إذا كان أمر النقل مقدماً من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
٣. يبقى للأمر بالنقل حق التصرف في المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد القيد المقابل الناقص لحسابه".

آثار عملية النقل المصرفي:

١. نقص رصيد العميل الأمر بالنقل وذلك بقدر المبلغ الذي أمر بنقله لحساب المحول إليه والذي يقيد في الجانب المدين من حساب العميل الأمر. ولا يتأكد حق المستفيد على هذا المبلغ إلا منذ قيده في الجانب الدائن من حسابه.
٢. براءة ذمة العميل الأمر في مواجهة المستفيد بقدر المبلغ الذي تم تحويله إلى هذا الأخير. بحيث يعد النقل المصرفي بمثابة وفاء نقدي للمستفيد والذي ينشأ له في مواجهة البنك حق في تلقي قيمة المبلغ المحول إليه بمجرد إتمام القيد في حسابه. أما في المرحلة التالية لصدور الأمر بالنقل المصرفي وحتى تنفيذه، فيظل الأمر مديناً، ويحق للمستفيدين الرجوع عليه، كما يجوز للأمر أن يعدل عن الأمر بالنقل.
٣. تملك المستفيد لمبلغ النقل المصرفي بمجرد قيد المبلغ محل أمر النقل في الجانب الدائن من حساب المستفيد وعلى ذلك يجوز للمستفيد باعتباره مالكا لهذا المبلغ أن يتصرف فيه بكافة أوجه التصرف.

٤. يكون للمستفيد حق مباشر في مواجهة البنك ليس له أية صلة بعلاقة العميل الأمر بالنقل بالبنك. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة العميل الأمر بالدفع والمتعلقة بدين المستفيد في مواجهة الأمر بالدفع، كما لا يجوز له التمسك في مواجهة المستفيد بالمقاصة التي كان له التمسك بها في مواجهة الأمر بالنقل لأن قيامه بتنفيذ عملية النقل المصرفي معناه تنازل البنك عن حقه في التمسك بالمقاصة.

الطبيعة القانونية للنقل المصرفي:

✍️ اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للنقل المصرفي فذهب البعض إلى تكييف عملية التحويل المصرفي بأنها بمثابة حالة **إنابة كاملة** يكون فيها العميل الأمر بالتحويل هو المنيب والمستفيد هو المناب لديه والمصرف هو المناب. **وذهب البعض الآخر** إلى القول بفكرة **الوكالة**. فبنك المستفيد وكيل عن بنك العميل الأمر في تنفيذ أمر النقل المصرفي.

✍️ الواقع أن عملية النقل المصرفي لا يمكن ردها على أي من القوالب القانونية التقليدية بل هي وسيلة من الوسائل التي ابتكرها الفن المصرفي لنقل النقود من ذمة إلى أخرى عن طريق قيود محاسبية يترتب عليها نفس من رصيد العميل الأمر وتزيد في رصيد المستفيد.

عقد فتح الاعتماد

تعريف عقد الاعتماد:

✍️ عقد فتح الاعتماد هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه البنك بأن يضع تحت تصرف العميل أو شخص آخر يحدده هذا الأخير مبلغ نقدي أو وسائل دفع خلال مدة معينة. وذلك مقابل تعهد العميل برد المبلغ المتفق عليه ودفع العمولة والعائد المتفق عليه.

عقد فتح الاعتماد العادي

تعريف العقد:

✍️ **عرفت المادة ٢٣٨ من قانون التجارة عقد فتح الاعتماد العادي أو البسيط بأنه:**

١. عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين.
 ٢. يفتح الاعتماد لمدة معين أو غير معينة".
- ✍️ يتبين من هذا النص أن عقد فتح الاعتماد البسيط ينشئ علاقة مباشرة بين العميل والبنك يتعهد فيها هذا الأخير بأن يضع تحت تصرف العميل خلال فترة زمنية محددة أو غير محددة مبلغ نقدي معين أو وسائل دفع في حدود هذا المبلغ. ويلتزم العميل برد هذا المبلغ مضافاً إليه العائد المتفق عليه والعمولة. وبذلك يستفيد العميل مباشرة من هذه المبالغ للوفاء بالتزاماته قبل دائيته دون أن تقوم أية علاقة مباشرة بني هؤلاء الدائنين والبنك.
- ✍️ يعتبر الاعتماد بالقرض من أكثر صور الاعتماد البسيط انتشاراً في الواقع العملي. ويتميز عن عقد القرض بأنه يجوز للمستفيد منه أن يتسلم المبلغ دفعة واحدة أو عدة دفعات، كما يجوز له أن يتسلم مبلغ الاعتماد بالقرض كله أو جزء منه فقط. بينما يلتزم المقرض في عقد القرض بأن يتسلم كل مبلغ القرض من البنك. وبذلك يعد عقد الاعتماد بالقرض أكثر مرونة وملاءمة للمستفيد من عقد القرض.
- ✍️ قد يقترن عقد فتح الاعتماد بفتح حساب جار للمستفيد لدى البنك ففتح الاعتماد، وفي هذه الحالة يقيد البنك مبلغ الاعتماد في الجانب الدائن للمستفيد من الاعتماد ويجوز لهذا الأخير سحب كل المبلغ أو جزء منه ورده ثم إعادة سحبه كل ذلك خلال مدة الاعتماد دون أن يعتبر الرد وفاء من قبل المستفيد لحين الاعتماد وذلك على أساس أن فتح الاعتماد يتجدد دون توقف.
- ✍️ إذا لم يقترن عقد فتح الاعتماد بحساب جار فإن العميل لا يستطيع سحب مبلغ الاعتماد إلا مرة واحدة خلال مدة الاعتماد، وإذا قام برد المبلغ أو جزء منه فإن ذلك يعد وفاء لدين الاعتماد.

ذهب البعض إلى القول بأن فتح الاعتماد هو **وعد بالقرض**، يعد فيه البنك العميل بإقراضه المبلغ المتفق عليه في العقد ويتحول هذا الوعد إلى قرض عند استخدام العميل لمبلغ الاعتماد ويذهب البعض الآخر إلى القول بأن عقد فتح الاعتماد **قرض معلق على شرط** هو استفادة العميل من مبلغ الاعتماد، وذلك تأسيساً على أن البنك يلتزم من جانب وأن يوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل ويحتفظ هذا الأخير بحرية كاملة في الاستفادة من هذا المبلغ. الأمر الذي دفع البعض إلى رفض هذا التصور وذلك استناداً إلى طلب العميل الاستفادة من القرض ليس شرطاً وإنما هو يدخل في موضوع الاتفاق فالتزام البنك قائماً سواء شاء العميل أن يستفيد من مبلغ الاعتماد أم لم يشأ.

رأي الدكتور ← نرى أن عقد فتح الاعتماد هو عقد مصرفي قائم بذاته يجد سببه في البحث المشترك من جانب البنك عن الربح والتمثل في التزام العميل بدفع العمولة والعائد المتفق عليه سواء استخدم مبلغ الاعتماد أم لم يستخدمه، وبحث العميل من جانب آخر عن الأمان لدى شخص يثق بملاءته المالية وهو البنك الذي يلتزم بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل خلال مدة معينة يتم الاتفاق عليها.

تكوين عقد فتح الاعتماد وإثباته:

يعتبر عقد فتح الاعتماد البسيط عقد رضائي ينعقد بمجرد تلاقي القبول والإيجاب دون حاجة إلى إفراغهما في شكل معين. ويتعين أن ينصب الرضا على كل شروط العقد فضلاً عن ضرورة توافر الأهلية اللازمة لطرفي العقد وأن يكون محل العقد وسببه مشروعين.

يعد عقد فتح الاعتماد البسيط من العقود المستمرة الذي يلعب الزمن فيها دوراً أساسياً بغض النظر عن مدة الاعتماد أي سواء كان مفتوحاً لمدة معينة أو غير معينة أو مفتوحاً لعملية واحدة أو عدة عمليات. ويؤسس العقد كذلك على الاعتبار الشخصي حيث تكون الثقة هي جوهر جميع العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك في مجال الائتمان الأمر الذي يستتبع تمتع البنك بسلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد.

تعتبر جميع عمليات البنوك أعمالاً تجارية إذا تمت مزاوتها على وجه الاحتراف. وعلى ذلك يجوز للعميل أن يثبت عقد فتح الاعتماد البسيط في مواجهة البنك بكافة طرق الإثبات.

بالنسبة للعميل فيكون عقد فتح الاعتماد البسيط تجارياً أو مدنياً حسب الغرض منه.

ترتيباً على ذلك إذا كان العميل تاجر وكان عقد فتح الاعتماد متعلقاً بشئون تجارية أصبح العقد تجارياً بالنسبة لكل من البنك والعميل. أما إذا كان العميل غير تاجر فالعقد يعتبر تجارياً بالنسبة للبنك فقط ومدنياً بالنسبة للعميل. ويتعين حينئذ على البنك إثبات عقد الاعتماد وفقاً لقواعد الإثبات المدنية.

س ٧: اكتب في أثار عقد فتح الاعتماد العادي؟

آثار عقد فتح الاعتماد العادي:

أولاً: التزامات البنك:

إذا كان عقد فتح الاعتماد محدد المدة فإن البنك يلتزم بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل المستفيد من الاعتماد خلال هذه المدة. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انقضاء هذه المدة ما لم يكن يخول العقد للبنك هذا الحق.

والأصل هو عدم جواز إلغاء الاعتماد محدد المدة من قبل البنك خلال المدة المحددة بالعقد، إلا أنه إذا جدت عوامل تخل بالأسس التي كانت سبباً في موافقة البنك على عقد الاعتماد فنه يجوز للبنك إلغاء الاعتماد بإرادته المنفردة.

مثال هذه الحالات ← وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع حتى ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ جسيم من العميل في استعمال الاعتماد. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد محدد المدة في غير الحالات المذكورة وذلك لمنع تعنت البنوك وتهديدها لعملائها بوقف الاعتماد بعد الموافقة عليه خلال مدة معينة.

بالنسبة لعقد فتح الاعتماد غير محدد المدة فإنه يجوز - طبقاً للقواعد العامة لكل طرف - إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار الطرف الآخر. ويتعين على البنك مراعاة الحيطة وعدم التعسف في استعمال حقه.

يلتزم البنك بتنفيذ الاعتماد على النحو المتفق عليه في العقد. وقد استقر العرف المصرفي على تحديد نطاق الإلتزام بتحديد الحد الأقصى لتنفيذ هذا الاعتماد وكيفية استخدامه والمدة الزمنية التي يعمل بها. وفي حالة عدم تنفيذ البنك لالتزامه بحق العميل المطالبة بالتنفيذ العيني إذا كان ممكناً وإلا فليس أمامه من سبيل سوى المطالبة بالتعويض.

ثانياً: التزامات العميل:

يترتب على عقد فتح الاعتماد التزام العميل بدفع العمولة والعائد المتفق عليهما بالعقد. والعمولة هي المقابل الذي يلتزم العميل بدفعه للبنك نظير موافقته على فتح الاعتماد سواء استخدم العميل الاعتماد أم لم يستخدمه أما العائد فلا يلتزم العميل بدفعه إلا إذا قام بالاستفادة من الاعتماد واستعمله بالفعل. ويسري العائد على المبالغ التي يقوم العميل بسحبها فقط دون المبالغ المتبقية له والتي لم يقم باستعمالها. يلتزم العميل فضلاً عن دفع العمولة والعائد المتفق عليه برد المبالغ التي تم سحبها فعلاً خلال مدة الاعتماد. وأخيراً يلتزم العميل ألا ينقل حق استعمال الاعتماد إلى شخص آخر بدون موافقة البنك وذلك بالنظر إلى أن عقد فتح الاعتماد من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي.

س ٨: اكتب في عقد فتح الاعتماد المستندي؟

عقد فتح الاعتماد المستندي

نشأة الاعتماد وأهميته:

نشأ الاعتماد المستندي أول ما نشأ في البلاد الأنجلوسكسونية كأداة لتسوية البيوع البحرية ثم انتشر بعد ذلك في كافة الدول في أواخر القرن التاسع عشر. تبدو أهمية الاعتمادات المستندية واضحة في عقود التجارة الدولية. فهي أداة لتوفير الثقة والطمأنينة لدى كل من طرفي عقد البيع الدولي. فالبايع يطمئن إلى أنه سيحصل على ثمن البضاعة المرسله إلى المشتري، وهذا الأخير يطمئن إلى أنه سيستلم البضاعة المرسله إليه من البائع طبقاً للمواصفات المتفق عليها في عقد البيع. هذه الثقة بين البائع والمشتري يوفرها البنك فاتح الاعتماد والذي لن يقوم بتسليم الثمن إلى البائع إلا إذا تأكد من أن البضاعة المرسله مطابقة للأوصاف المحددة بعقد البيع وذلك من خلال المستندات التي تمثل البضاعة والتي يلتزم بفحصها والتحقق منها. كما أن البنك لن يقوم بتسليم البضاعة إلى المشتري إلا إذا تسلم الثمن وجميع المصاريف الأخرى المتمثلة في العمولة التي يتقاضها البنك من عميله الأمر بفتح الاعتماد، فضلاً عن العائد المستحق على المبالغ التي يضعها البنك تحت تصرف عميله على سبيل الائتمان.

تعريف عقد الاعتماد المستندي:

عقد فتح الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الأمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

على ذلك فعقد الاعتماد المستندي هو عقد يتم بين البنك والعميل بمقتضاه يلتزم البنك بأن يضع مبلغ معين من المال تحت تصرف شخص ثالث يعينه العميل يسمى المستفيد ولا يحصل هذا الأخير على المبلغ إلا إذا قدم للبنك المستندات التي تمثل البضاعة والمستندات التي تثبت علاقته بالعميل الأمر والتي يتعين على البنك - قبل تنفيذ التزامه بالاعتماد - التحقق من مطابقة هذه المستندات لشروط خطاب الاعتماد.

وفقاً لنص المادة الأولى من القواعد الموحدة للاعتماد المستندية فإن هذه القواعد تطبق على أي اعتماد مستندي في حالة اتفاق الطرفين على ذلك صراحة. ومع ذلك يجوز للطرفين استبعادها وعندئذ يسري على الاعتماد المستندي قواعد التشريعات الوطنية التي تحددها قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص.

قد نظم قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الاعتمادات المستندية في المواد من ٣٤١-٣٥٠ حيث تطبق القواعد التي تتضمنها هذه المواد على الاعتمادات المستندية وفي حالة عدم كفايتها يتم تطبيق القواعد والأعراف الموحدة التي وضعتها غرفة التجارة الدولية. وفي ذلك تنص المادة ٣/٣٤١ من قانون التجارة على أنه: "تسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية".

أنواع الاعتمادات المستندية:

الاعتمادات المستندية إلى عدة أنواع على النحو التالي:

١- الاعتماد المستندي القابل للإلغاء وغير القابل للإلغاء:

وفقاً لنص المادة ٣٤٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩: "لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على عاتق البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ". يتبين من النص السابق أن الاعتماد القابل للإلغاء يجوز فيه للبنك أن يلغيه أو يعدله في أي وقت دون أدنى مسؤولية عليه في مواجهة المستفيد. وكل ما يقع على عاتق البنك في هذا الصدد هو التزامه بإخطار المستفيد بالإلغاء.

لما كان هذا النوع من الاعتمادات لا يوفر الطمأنينة الكافية للبائع فإنه لا يتم اللجوء إليه إلا إذا توفرت الثقة بين العميل الأمر والمستفيد بدرجة لا تحتاج إلى تدخل البنك وإنما يكون القصد من فتح الاعتماد هو تنظيم طريقة الدفع بين البائع والمشتري فقط لا غير.

لا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه .

يكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته للإلغاء .

٢- الاعتماد المؤبد:

يقصد به الاعتماد الذي يتعهد فيه بنك في دولة البائع (المستفيد) المستورد بدفع قيمة الاعتماد لهذا الأخير وذلك حتى يزيد من طمأنينته بأن المشتري سيقوم بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن. وعلى ذلك يصبح البنك المؤبد مسئول مباشرة في مواجهة المستفيد مباشرة وفي حدود خطاب الاعتماد.

لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً من هذا البنك للاعتماد. ويسمى البنك في هذه الحالة بالبنك المراسل ولا يقع على عاتقه أي التزام بتأييد الاعتماد. ويجوز أن يصبح البنك لمراسل مؤيد للاعتماد الأصلي وفي هذه الحالة يلتزم مباشرة في مواجهة المستفيد. ويصبح لهذا الأخير بنكين مسئولين مسؤولية مباشرة في مواجهته في وقت واحد كل منهما مستقل ومباشر.

٣- الاعتماد المستندي القابل للتحويل:

يقصد به الاعتماد الذي يتفق في عقده على حق المستفيد في تحويل كل مبلغ الاعتماد أو جزء منه لصالح مستفيد آخر أو أكثر.

ونظراً لأن الاعتماد المستندي يقوم على الاعتبار الشخصي فلا يجوز تحويله ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذوناً في تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك .

٤- اعتماد الدفعة الواحدة والاعتماد المتجدد:

يقصد باعتماد الدفعة الواحدة الاعتماد الذي تدفع قيمته مرة واحدة خلال تاريخ معين وذلك بمجرد تقديم المستندات المحددة بخطاب الاعتماد. أما إذا اتفق البائع والمشتري على تجديد ذات الاعتماد المتفق عليه على عمليات متتالية ليغطيها هذا الاعتماد على مراحل فيطلق عليه اسم الاعتماد المتجدد.

أولاً: العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والعميل الأمر:

- ينظم هذه العلاقة عقد فتح الاعتماد الذي تم إبرامه بين البنك والعميل الأمر. ويحدد العقد التزامات البنك في مواجهة العميل الأمر بفتح الاعتماد والتزامات هذا الأخير في مواجهة البنك وحق البنك في رد مبلغ الاعتماد والعمولة والعائد المتفق عليه كما يتضمن العقد الإشارة إلى عقد البيع الذي فتح الاعتماد بسببه، وشروط الاعتماد وحجمه.
- وتتمثل التزامات البنك في مواجهة العميل في تنفيذ شروط عقد فتح الاعتماد والتي تستلزم إخطار المستفيد بشروط الاعتماد ذلك عن طريق خطاب يسمى بخطاب الاعتماد. متضمناً شروط فتح الاعتماد سواء من حيث تحديد حقوق المستفيد أو مبلغ الاعتماد أو مدته. كما يلتزم البنك بتسلم المستندات المطلوبة من البائع والمحددة في عقد فتح الاعتماد وفحص هذه المستندات والتحقق من مدى مطابقتها لتعليمات العميل الأمر.
- يعد التزام البنك بفحص المستندات من أهم التزامات البنك في مواجهة العميل الأمر.
- التزام البنك بفحص المستندات هو التزام بالفحص الشكلي والحرفي للمستندات. أي أنه ينصب على التحقق من توافر هذه المستندات ومطابقتها للشروط الواردة بخطاب الاعتماد. وتقف سلطة البنك في فحص المستندات عند هذا الحد دون أن تمتد إلى التحقق من خلوها من التزوير إذا كان ظاهرها لا يدعو إلى الشك في صحتها ولم يكن في مقدور البنك كشف تزويرها.
- كان ظاهر المستندات يدعو إلى التشكك تعين على البنك رفضها وإلا كان مسئولاً عن خطئه في مواجهة العميل. وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.
- التزام البنك بفحص المستندات لا يمتد إلى فحص البضاعة محل عقد البيع من حيث كميتها أو نوعها أو تغليفها. فالبنك لا يتعامل على البضاعة وإنما يقتصر التزامه على مجرد استلام المستندات ومطابقتها لشروط عقد فتح الاعتماد المتفق عليها وبين العميل.

ثانياً: العلاقة بين العميل الأمر والمستفيد:

- يولد عقد البيع التزامات في ذمة كل من البائع والمشتري. وتتمثل التزامات المشتري في فتح عقد الاعتماد المستندي للوفاء بثمن البضاعة وذلك طبقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع. ويتعين لتنفيذ البائع لالتزامه أن يقوم البنك فاتح الاعتماد بإخطاره بفتح اعتماد لحسابه وذلك عن طريق إرسال خطاب اعتماد والذي يتضمن تحديد حقوق والتزامات البائع المترتبة على عقد فتح الاعتماد.
- النسبة لالتزامات البائع فتتمثل في شحن البضاعة وتقديم المستندات التي تمثل البضاعة والمتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إلى لبنك في الميعاد المحدد.
- إذا أخل البائع بتنفيذ التزامه جاز للمشتري فسخ عقد البيع والمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار من جراء هذا الفسخ.

ثالثاً: العلاقة بين البنك والمستفيد:

- ينشأ للمستفيد حق مباشر ونهائي ومستقل في مواجهة البنك فاتح الاعتماد بمجرد فتح اعتماد مستندي لصالحه.
- يلتزم البنك في مواجهة المستفيد ويصبح لهذا الأخير حق في اقتضاء مبلغ الاعتماد بمجرد إخطار البنك له بخطاب الاعتماد وينظم هذا الخطاب العلاقة بين البنك والمستفيد حتى ولو كانت شروطه مختلفة عن شروط عقد فتح الاعتماد.
- أن التزام البنك في مواجهة المستفيد التزام بات ونهائي بتنفيذ هذا الاعتماد لا يملك البنك الرجوع فيه.
- على ذلك يلتزم البنك بدفع مبلغ الاعتماد بمجرد تقديم البائع المستندات التي تمثل البضاعة والمطابقة للمستندات المحددة بعقد فتح الاعتماد. بغض النظر عن تلقي البنك تعليمات من العميل الأمر بعدم تنفيذ الاعتماد بسبب عدم تنفيذ المستفيد لعقد البيع المبرم بينه وبين العميل.
- مع ذلك يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ التزاماته في مواجهة المستفيد إذا صدر غش من المستفيد لأن الغش يفسد كل شيء.